

論「民主審議」作為一項生命倫理原則 及其規範意涵*

張兆恬**

摘要

美國歐巴馬總統任內之總統生命倫理議題研究委員會在其所作出的各報告中，將「民主審議」持續列為一項指引原則，並廣泛運用於各項生命倫理的議題上，有鑒於此趨勢，本文主張以民主審議作為一項新興的生命倫理原則，並檢視此原則如何能補充現行各原則。此原則的加入，在規範層面也具有重要意義：由於現有生命倫理原則已經廣泛內化於法律和管制架構中，故民主審議的原則化，將使民主審議不再只是政治學上理想的決策程序，而成為法定義務。民主審議亦有其規範依據，不僅是憲法所肯認的價值，且生命倫理議題涉及人民基本權利，應符合正當法律程序的要求，故民主審議應於管制架構中加以落實，而生命倫理原則正提供了適切的落實管道。本文也透過人體研究倫理審查委員會的制度設計、生命倫理議題的司法審查兩個例子，來說明民主審議原則在制度面如何落實。

* 投稿日：2016年10月17日；接受刊登日：2018年6月6日。[責任校對：鄧婉伶]。

本文之部分內容為作者以英文寫作之博士論文一部所改編，本主題的發想，感謝博士論文指導教授Anita L. Allen博士之啟發。本文亦蒙黃昭元大法官以及兩位匿名審查人惠予諸多建議，在此深表感謝。惟文責仍由作者自負。在中文寫作及我國法的討論上，亦為科技部補助專題計畫105-2410-H-009-002之研究成果。

** 國立交通大學科技法律學院助理教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/70535181.pdf>。



關鍵詞：民主審議、生命倫理、生命倫理原則、原則主義、審議民主、正當法律程序。

目次

- | | |
|-----------------|----------------|
| 壹、引言：生命科學的憲法時刻 | 肆、民主審議「倫理原則化」的 |
| 貳、生命倫理之起源、架構及挑戰 | 必要性：以規範意涵為中心 |
| 一、起源 | 一、「倫理原則化」的幾個理由 |
| 二、生命倫理原則的提出 | 二、透過「倫理原則化」取得 |
| 三、改革方向：民主審議的納入 | 規範效力 |
| 參、民主審議作為一項生命倫理 | 三、問題及回應 |
| 原則 | 伍、民主審議原則的運用：以 |
| 一、何謂「民主審議」 | IRB及司法審查為例 |
| 二、民主審議逐漸確立其原則 | 一、以民主審議改革IRB的組 |
| 性的地位——美國總統生 | 織與程序 |
| 命倫理議題研究委員會報 | 二、民主審議運用於司法審查 |
| 告顯示之趨勢 | 陸、結論 |
| 三、民主審議符合成為生命倫 | |
| 理原則之要件 | |

壹、引言：生命科學的憲法時刻

有鑑於20世紀末以來迄今生命科學與技術的發展，科技與社會（Science, Technology and Social Studies, STS）學者Sheila Jasanoff形容我們正在經歷「生命的憲法時刻」（bioconstitutional moment）¹。這樣的比喻得益於憲法學者Bruce Ackerman的「憲法時刻」，指的

¹ Sheila Jasanoff, *Introduction: Rewriting Life, Reframing Rights, in* REFRAMING RIGHTS: BIOCONSTITUTIONALISM IN THE GENETIC AGE 1, 2-4 (Sheila Jasanoff ed., 2011).

是美國歷史上歷經重大憲法變遷的時期，這些時期的憲法變遷不一定是透過美國憲法上修憲程序為之，也可能是透過政治程序的運作，或者是透過司法解釋和公民運動發起²。Jasanoff認為近來生命科學與技術發展造成的國家與社會改變，不下於過去各個憲法時刻，生命科學與生物科技重構我們對於生命的理解，而對於生命的理解涉及一切權利、社會關係的核心，勢必是憲法層級的議題³。

若我們正處於憲法時刻中，則不得不關注憲法時刻的一項重要特徵：這個時期熱絡的公共討論。在常態政治中，人民通常並非直接參與政治，而是透過投票來確保代議政府的責信。然而憲法時刻處於特別狀態，憲法變遷必須訴諸更高的民主正當性，也因此必須進行大規模的政治動員，透過公民參與和審議的過程，來取得公民的支持⁴。這樣大規模的公民審議活動，也被Ackerman稱之為「更高法的制定」(higher lawmaking)，有別於常態政治的代議作成，此時法的正當性是直接來自於人民主權⁵。同樣的，在生命的憲法時刻中，面對各種生命科學與技術發展所帶來的挑戰，勢必應該在決策過程中訴諸公民審議，以取得更高法制定所需之民主正當性。

與前述生命科學憲法時刻的概念相呼應，美國歐巴馬總統任命之總統生命倫理議題研究委員會(Presidential Commission for Study of Bioethical Issues, PCSBI)⁶自2010年以來，在該委員會關於生命

2 除了立憲時期以外，至少還有三個美國歷史上的憲法時刻：(一)南北戰爭後憲法增修條文第13至15條的批准；(二)新政時期，公民透過支持小羅斯福總統連任，形同事實上批准國會有權介入國家經濟事項；以及(三)民權運動時期透過公民運動、司法判決所引領的法律變遷。See generally BRUCE ACKERMAN, WE THE PEOPLE VOLUME 2: TRANSFORMATIONS 15-20 (2000). 我國關於憲法時刻的討論，可參考：葉俊榮，消散中的「憲法時刻」，收於：民主轉型與憲法變遷，頁61-110（2003年）；楊皓清，憲法變遷與修憲政治——民主轉型國家的因應策略及其侷限，月旦法學雜誌，48期，頁136-146（1995年）。

3 Jasanoff, *supra* note 1, at 3.

4 BRUCE ACKERMAN, WE THE PEOPLE VOLUME 1: FOUNDATIONS 6-7 (1991).

5 *Id.*

6 本文中會提到美國多個國家層級的生命倫理委員會，並且將以「國家生命倫理

倫理議題所做成的報告中，一再將「民主審議」(**democratic deliberation**)列為一項指引原則⁷，似乎正與憲法時刻中公民審議的重要性相呼應。生命倫理(bioethics)是一新興學門，主要在於探討醫學、生命科學及一切與生命有關之倫理議題，而自1970年代

委員會」來統稱之。然而各時期的倫理委員會法源依據不盡相同，彼此間也並非具有同一性的機關。最初作成貝爾蒙特報告(Belmont Report)的國家生醫與行為研究倫理委員會(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, the "National Commission," 1974-1978)是依據國會立法授權設立，詳參後「貳、二、(一)」所述；其後的總統醫藥及生醫與行為研究倫理議題研究倫理委員會(President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, 1978-1983，以下簡稱：President's Comm'n)也是由國會特別立法授權設立。而在此後的國家倫理委員會，則並非是透過國會特別立法，而是根據Federal Advisory Committee Act (FACA)授權行政機關成立專家委員會的權限所設立，故歷任總統有依據FACA任命生命倫理委員會者，如柯林頓總統任命之國家生命倫理諮詢委員會(National Bioethics Advisory Commission, NBAC, 1995-2001)，小布希總統任命之總統生命倫理委員會(President's Council on Bioethics, 2001-2009)，以及歐巴馬總統任命之總統生命倫理議題研究委員會(PCSBI)；另有針對特定議題作成之委員會，例如柯林頓總統時期組成之人體輻射事件諮詢委員會(Advisory Committee on Human Radiation Experiments, 1994-1995)。前述關於歷任倫理委員會之概述，可參照：*Former Bioethics Commissions*, THE PRESIDENT'S COUNCIL ON BIOETHICS [hereinafter President's Council], https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/past_commissions/ (last visited Jan. 28, 2018); *History of Bioethics Commissions*, PRESIDENTIAL COMM'N FOR THE STUDY OF BIOETHICAL ISSUES [hereinafter PCSBI], <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/history.html> (last visited Jan. 28, 2018)。川普總統於2017年上任後，迄今並未任命國家級的生命倫理委員會。

然而，各委員會的報告中，不乏援引過去委員會之論理或結論者，其中最顯著者為貝爾蒙特報告廣為其後各委員會之各報告所引述，或如總統生命倫理議題研究委員會在關於人體研究相關規範回顧檢視的報告中，開頭即回顧歷來各倫理委員會對此議題之見解，*see* PCSBI, MORAL SCIENCE: PROTECTING PARTICIPANTS IN HUMAN SUBJECTS RESEARCH 15 (2011), <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/Moral%20Science%20June%202012.pdf> [hereinafter PCSBI, MORAL SCIENCE]；或者是任期最後的報告中，也對於未來的倫理委員會的運作提出建議，*see* PCSBI, BIOETHICS FOR EVERY GENERATION: DELIBERATION AND EDUCATION IN HEALTH, SCIENCE AND TECHNOLOGY 85 (2016), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/PCSBI_Bioethics-Deliberation_0.pdf [hereinafter PCSBI, EVERY GENERATION]。再者，前述引用的各國家倫理委員會官方網頁上，也都對於過去國家倫理委員會之歷史進行回顧，足見各委員會間縱使在組織上雖非同一，亦有一定承襲關係。

⁷ 該委員各報告關於民主審議之內容，詳見後「參、二」所述。

以來確立的生命倫理原則⁸——尊重自主、為善、不傷害、正義，一直作為生命科學領域中倫理論述的指導原則，引領著政策制定者、醫事人員、研究者和倫理委員於此領域中的決策。民主審議從來不在既有的生命倫理原則之列，然而另一方面，民主審議的概念對於生命倫理並不陌生，審議向來被認為是解釋生命倫理原則內容不可或缺的方法與程序；而生命倫理議題上所廣泛運用的治理機制——各種的倫理委員會，也是具有審議性質的組織。本文認為總統生命倫理議題研究委員會的報告中，可反映一項趨勢，即認為民主審議不再僅是方法或程序，而應該提升至原則的層次，故本文主張民主審議應提升為一生命倫理原則。究竟民主審議的內涵為何、是否具備作為一項生命倫理原則的適格性，又將民主審議「升格」為倫理原則的意義何在，將是本文探討之焦點。同時，本文也試圖從規範層面加以分析，由於生命倫理原則已經深入生醫事項的管制架構中，而增加此一新原則，是否有規範層面的依據能夠加以支持，又對於管制產生如何的影響，亦是本文所欲探究之議題。

接續引言，以下第貳部分將先行探究生命倫理原則之起源、架構及其挑戰，目前生命倫理最廣為採用的生命倫理原則及其方法論「原則主義」(principlism)確立於1970年代，各原則訴諸共通的道德價值，以跨越不同道德觀間的歧見。然而此架構的不足在於，抽象的原則有賴具體解釋適用，但現有各原則及原則主義架構卻對於方法或程序較少著墨；再者，生命倫理原則立基於個人主義，容易忽視個體間的差異、結構的不平等，以及個人與群體間的關係。有

⁸ 關於現有的生命倫理原則究竟有哪些，本文將介紹最廣為人知的兩種：一為貝爾蒙特報告(Belmont Report)中的三原則——尊重自主、為善、正義，一為Tom L. Beauchamp與James F. Childress所提出的四原則，將「為善」進一步區分為「為善」和「不傷害」，但三原則與四原則的內涵大致相似，詳見後述「貳、二」。本文在行文中前述各原則皆泛稱為「生命倫理原則」，僅在特別討論貝爾蒙特報告或Beauchamp與Childress的理論時，才特別以三原則或四原則加以指稱。

鑒於現行生命倫理原則的不足，第參部份則探究民主審議是否得以作為一生命倫理原則，又其內涵為何，本文借重審議民主（deliberative democracy）理論來理解民主審議，審議民主認為好的決策須要具備提出受影響者可接受的理由以及適度的公民參與；而民主審議作為一項生命倫理原則，不僅在程序面為倫理委員會所應該踐行的程序，也有諸多於實體面的政策建議，且非為現行各生命倫理原則所得涵蓋；本文也檢視生命倫理的三要件：歷史性、普世性、重要性，證明民主審議符合此三要件。第肆部分則進一步論述民主審議「倫理原則化」的必要性，除了民主審議能夠補足現行生命倫理原則所缺乏之面向以外，以及反應生命倫理原則普遍認為公民參與不足的現況以外，本文更認為「倫理原則化」的優勢，在於能使民主審議透過生命倫理原則現有的規範效力，更進一步深化於決策中。民主審議本身具有憲法依據，但抽象的憲法規範有賴具體的規範形成，而生命倫理原則已廣泛內化於法律和管制架構中，故「倫理原則化」將使民主審議取得直接或間接的規範效力，而不再僅止於政治學上理想的決策程序。第伍部分本文則以兩個例子：倫理委員會的制度設計、涉及生命倫理案件的司法審查，來說明民主審議原則如何在制度面落實。第陸部分為結論。

貳、生命倫理之起源、架構及挑戰⁹

一、起源

「生命倫理」此一領域的起源於，在美國可溯自1960年代，當時由於係因新興生醫科技的興起產生倫理生意，以及社會大眾對於

⁹ 國內文獻中關於生命倫理原則起源之介紹，可參考：蔡甫昌、李明濱，當代生命倫理學，醫學教育，6卷4期，頁381-395（2002年）；蔡甫昌，生命倫理四原則方法，醫學教育，4卷2期，頁140-154（2000年）。

醫師與科學家在決策上權威地位的質疑，逐漸意識到生醫相關的決策並非價值中立，而是帶有價值判斷的，因而引發對於醫療與生醫研究倫理議題的高度關注¹⁰。其實討論醫療領域倫理議題的醫學倫理（medical ethics），早已有悠久歷史¹¹，然而醫學倫理聚焦於醫師的觀點，探討在宗教與文化脈絡下醫師的職業道德與傳統，主要是為醫師的行為提供誠命，而非在為醫師面臨道德衝突時提供倫理判斷的指引¹²。在第二次世界大戰之後，由於醫療與科技的進步及科技發展的風險不確定，對病人有利或不利間的界線益趨模糊，公眾開始認為醫療決定帶有價值判斷，並且對於醫療與科技的專業權威產生質疑，使得醫學倫理繫於專業倫理的觀點面臨挑戰¹³。相較於傳統醫學倫理，生命倫理的特點在於除醫學與科學的專業觀點以外，也納入哲學、神學以及一般公眾的觀點，以探討生命科學與醫學所引發的社會與倫理議題，並且認為這些議題並非僅依賴科學與技術的進步就能解決，而需要進行深入的倫理思辨¹⁴。生命倫理學家Albert R. Jonsen指出，生命倫理的最大特徵是提供一種前所未有的論述（discourse）方式，也就是打開了持續且具有目的性的對話平台，使得不同領域的觀點能夠相互討論、理解¹⁵。生命倫理是一個更廣於醫學倫理的領域，試圖對於醫學、生命科學及技術所涉及的倫理與政策議題，尤其是在面臨複雜的道德爭議時，提供更為廣泛且多元的思考。

10 Helga Kuhse & Peter Singer, *What is Bioethics? A Historical Introduction*, in *A COMPANION TO BIOETHICS* 3, 3 (Helga Kuhse & Peter Singer eds., 1998); ALBERT R. JONSEN, *THE BIRTH OF BIOETHICS* 13 (1998).

11 例如醫師誓詞Hippocratic Oath寫於西元前5世紀，Kuhse & Singer, *supra* note 10, at 4.

12 生命倫理學家Albert R. Jonsen就形容醫學倫理是禁令（有時是制裁）多於解釋，且極少討論在道德衝突前的困難處境。JONSEN, *supra* note 10, at 11.

13 *Id.*

14 *Id.* at 19.

15 *Id.* at 19, 353.

二、生命倫理原則的提出

生命倫理的起源主要可以溯自兩項重要文件：貝爾蒙特報告（*Belmont Report*）以及「生醫倫理原則」一書（*Principles of Biomedical Ethics*）。這兩項文件確立了現行以生命倫理原則為中心的分析架構——也就是在進行生命倫理議題的討論時，根據幾項主要的倫理原則來進行檢視。若生命倫理的特徵是開啟整合不同觀點的論述平台，而原則主義則扮演著論述架構的重要角色。

（一）貝爾蒙特報告確立人體研究倫理原則

貝爾蒙特報告是美國國家生醫與行為研究倫理委員會（National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, the “National Commission”）於1979年作成¹⁶，該報告是用於回應當時所爆發的重大研究倫理爭議。雖然在二次大戰間不人道的人體研究已於戰後受到檢討，1949年國際上即有「紐倫堡宣言」（Nuremberg Code）的訂立¹⁷，或者其後1964年國際醫學會也提出了人體研究應該遵守的赫爾辛基宣言（Declaration of Helsinki）¹⁸，但在美國法上缺乏有力之規範。1960年代美國政府對於生醫研究挹注大量資金，人體研究的數量也大幅成長，然而研究倫理的架構並未確立，根據1966年哈佛醫學院教授Henry K. Beecher在*New England Journal of Medicine*發表文章，發現當時許多人體研究所採取的研究方式是不符合倫理的，並歸納出22

16 See NAT'L COMM'N FOR THE PROT. OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL & BEHAVIORAL RESEARCH [hereinafter NAT'L COMM'N], THE BELMONT REPORT: ETHICAL PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF RESEARCH (1979), <http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html#xethical>.

17 *The Nuremberg Code (1949)*, HHS.GOV (Sept. 23, 2015), <http://www.stat.ncsu.edu/people/tsiatis/courses/st520/references/nuremberg-code.pdf>.

18 *Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*, WORLD MED. ASS'N (Oct. 2013), <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>.

種常見違反研究倫理的態樣¹⁹，使研究倫理的議題逐漸受到社會關注。其後在1972年，經媒體揭露Tuskegee梅毒研究弊案，發現美國政府竟然以阿拉巴馬州小鎮Tuskegee當地的非裔黑人男性為梅毒研究對象，對於許多受試者明知其染有梅毒卻故意不告知、不予以治療，且持續這樣的試驗長達40年，公眾譁然²⁰。為了回應當時公眾對於人體研究倫理性的質疑與改革期待，國會於1973年通過國家研究法（the National Research Act）、次年生效，該法創設了國家生醫與行為研究倫理委員會，並授權該委員會進行調查、研究，找出「人體生醫與行為研究所應該遵循的基本倫理原則」，以及「為這些實行這些基本原則制定指引」²¹。基於此授權國家生醫與行為研究倫理委員會，因此作成貝爾蒙特報告。

在貝爾蒙特報告，國家生醫與行為研究倫理委員會列出三項人體研究應該遵守的原則——尊重個人、為善、正義²²。尊重個人包括兩個概念：個人應該被當作獨立自主的個體來對待，以及若個人的自主意思不完整時應該受到保護。為善是應該確保個人的福祉，具體而言為不傷害、最大化可能利益以及最小化可能損害。正義則是處理誰應負擔研究風險或享有研究利益的問題，該報告回顧了歷史上的人體研究弊案，並且認為將正義與科學研究進行連結，具有重大意義²³。該報告同時也指出三原則如何在人體研究上具體落實

19 Beecher指出當時人體試驗不符合研究倫理的情況十分常見。氏找出17個不符合研究倫理的案例，但後來發現其實可以衍生為至少51個案例，因為每個案件裡面至少有3個以上不合倫理的點；又或者在對100項於1964年間曾在一流醫學期刊上發表的研究中，氏發現裡面至少有12項是有不合倫理之處的。See Henry K. Beecher, *Ethics and Clinical Research*, 274 NEW ENG. J. MED. 1354 (1966), reprinted in 79(4) BULL. WORLD HEALTH ORG. 367 (2001).

20 *U.S. Public Health Service Syphilis Study at Tuskegee*, CTR. FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION, <http://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm> (last updated Aug. 30, 2017).

21 National Research Act, Pub. L. No. 93-348, §§ 201(b)(1), 202(a)(1)(A) (1974). (粗體字為本文所加)。

22 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

23 *Id.*

的規則 (rules): 告知同意實現尊重個人原則, 損益評估實現為善原則, 受試者選擇實現正義原則²⁴。這些原則以及具體落實規則, 至今仍在生命倫理領域中被廣為援引。

然而, 究竟這三原則的性質為何, 國家生醫與行為研究倫理委員會又是怎麼推演出這三原則的? 從發展歷史脈絡看來, 原則主義並非國家生醫與行為研究倫理委員會所原創, 而是國會授權的內容。再者, 原則主義在人體研究倫理中並非無前例, 相關的國際宣言如紐倫堡公約, 也是採取條列原則的方式²⁵。根據該委員會中幾位成員事後回憶指出, 委員會達成共識的過程很漫長, 一度達成的初步共識有七原則跟五指引, 但委員中有認為這個清單不夠精簡, 最後才產生目前的三原則²⁶。在最後的貝爾蒙特報告中, 則重申之國會授權作成此報告之意旨, 在於為人體研究所引發的倫理問題提供解決的分析架構, 並且形容三原則是「具有一定的共通性 (generalization), 以能夠幫助科學家、受試者、審查委員、利害關係的公民瞭解人體研究本質上所涉及得倫理議題」; 這些原則不但具有對於人體研究具有重要性, 且是從「廣為吾人文化傳統所接受」的倫理原則中所選出²⁷。由前述的描述, 可以看出三原則其實並不是一個窮盡的清單, 三原則之所以被選出, 是因為國家生醫與行為研究倫理委員認為這三原則是當時最為重要、最廣為接受的共識。

貝爾蒙特報告不僅為人體研究的倫理審查提供指引, 其所揭示的架構也進一步被融入規範之中。人體研究的主管機關Department of Health, Education, and Welfare (後改組為現今的Department of

24 *Id.*

25 Albert R. Jonsen, *On the Origins and Future of the Belmont Report*, in BELMONT REVISITED: ETHICAL PRINCIPLES FOR RESEARCH WITH HUMAN SUBJECTS 3, 3 (James F. Childress et al. eds., 2005).

26 *Id.* at 4.

27 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

Health and Human Services，下稱HHS）在貝爾蒙特報告作成之同時，也制定了受聯邦補助之實驗應遵守之受試者保護規範，於1974年正式納入聯想法規²⁸。其後HHS和Food and Drug Administration等其他機關，也共同以貝爾蒙特報告為基礎，修改其所主管法規中與人體研究相關者並加以統合，於1991年制定出「聯邦受試者保護政策」，通稱Common Rule，並且為15個聯邦機關所採用²⁹，是為現今美國法上人體研究之最主要規範依據。

（二）「生醫倫理原則」一書確立生命倫理分析架構—— 原則主義

1. 原則主義的內涵

而另一確立原則主義的來源則是1977年由Tom L. Beauchamp與James F. Childress所著之「生醫倫理原則」一書³⁰。在該書中對於醫療與生命科學所面臨的倫理議題，提出以四大原則為基礎的分析架構，一般也被認為是確立生命倫理的「原則主義」典範。

該書的作者Beauchamp本身，也是撰寫貝爾蒙特報告的國家生醫與行為研究倫理委員的工作成員之一，於1976年加入該委員會協助撰寫報告，雖然氏主張該書的寫作是與報告並進的，並不承認該書的產生後於貝爾蒙特報告，但也不否認該書與貝爾蒙特報告的撰寫之間有相互影響³¹。然而，Beauchamp認為兩者之間有相當的差

28 45 CFR 46 FAQ, HHS.GOV, <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/guidance/faq/45-cfr-46/index.html> (last visited Aug. 1, 2016).

29 Federal Policy for the Protection of Human Subjects ('Common Rule'), HHS.GOV, <http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/commonrule/> (last updated Mar. 18, 2016).

30 TOM L. BEAUCHAMP & JAMES F. CHILDRESS, PRINCIPLES OF BIOMEDICAL ETHICS, at vii (7th ed. 2013).

31 從該書所揭示的四原則，與貝爾蒙特報告三原則在名稱上有所相似，即可見一斑。Tom L. Beauchamp, *The Origins and Evolution of the Belmont Report*, in BELMONT REVISITED: ETHICAL PRINCIPLES FOR RESEARCH WITH HUMAN SUBJECTS 12, 12-15 (James F. Childress et al. eds., 2005).

異，其中最顯著者，在於該書有別於貝爾蒙特報告聚焦於人體研究，企圖建立一個更廣泛適用的框架，範圍不僅限於人體研究，更及於所有的生命倫理議題³²。亦即，該書中所提出的架構，並不以適用於人體研究為限，而能夠廣泛適用於任何生命倫理的議題。

兩位作者在該書中提出生命倫理的四原則：尊重自主、不傷害、為善、正義。相較於貝爾蒙特報告三原則，最明顯的不同是將為善原則進一步區分為不傷害和為善兩個面向，兩位作者認為，不傷害不包括積極提供利益的行為，例如積極的救治³³。不傷害和有利之間仍不免有衝突，例如在安寧緩和醫療的決定中，不傷害即為不施予或撤除維生設施提供正當性的基礎³⁴。為善則不僅包括積極給予個人利益，也賦予決定者進行利益衡量、追求最大效用（utility）的義務，但效用的追求不得與尊重自主與正義相違³⁵。在正義的部分，兩位作者討論的範圍亦不限於生醫研究上的受試者分配，而是更廣泛討論醫療資源不平等的各種面向³⁶。

在生命倫理原則的定性上，兩位作者認為：原則主義提供了一套分析架構，且該架構是根植於「共同道德」（common morality）的基礎上，適於作為生醫倫理分析的起點³⁷。此處所謂「共同道德」，指的是所有同意遵守道德者所共同接受的規範，這些規範是人類經驗與歷史的產物，並且是跨越文化與個人差異而具有普世性³⁸。兩位作者認識到在原則之上，還有更上位的道德理論（moral theories）³⁹，但該書所提出的各原則具有共通性，不論採取哪一種

32 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 302.

33 *Id.* at 149.

34 *Id.* at 150, 168-69.

35 *Id.* at 202, 241.

36 *Id.* at 249.

37 *Id.* at 1-2.

38 *Id.* at 3-4.

39 在該書中，兩位作者檢視了四種道德理論：功利主義、康德主義（Kantianism）、權利理論（right theory）和德行理論（virtue theory），認為這四種理論雖然代表

道德理論，皆能夠同意這些基於「共同道德」的原則⁴⁰。在解決實際的問題時，人們其實並不須要達成道德理論的共識，只要在原則層次達成共識即可，而背後所依據的道德論證不一定相同⁴¹。兩位作者認為，實際的決策以原則為指引，依據原則可以形成更下位的規則（rule），為決策提供更具體的依據⁴²。此種肯認背後道德差異而訴諸背後道德共識的架構，與貝爾蒙特報告三原則訴諸社會與歷史文化共通性的定性，亦有相似之處。

原則主義在實際運用上的挑戰，在於如何解釋適用這些原則，以及如何處理原則間的衝突。對此，貝爾蒙特報告提供的線索有限，而Beauchamp與Childress雖然對於四原則的內容有較為詳盡的闡釋，但也體認到其闡釋仍有侷限性，因此提出方法論的主張，來處理原則的解釋與衝突。其中一最重要的方法是證成（justification），也就是於原則的解釋適用（specification）、衝突權衡（balancing）的處理，必須提出足夠的論證為依據，這也是生命倫理所肩負的主要任務——為決策提供支持的理由⁴³。在證成的方法上，兩位作者藉用了John Rawls政治哲學理論中的反思均衡（reflective equilibrium），融合由抽象理論演繹至具體個案、由具體個案歸納出抽象理論的兩種不同方法，不斷檢證抽象的道德信念、原則乃至於具體判斷，並儘可能信念、原則與具體判斷間具有一致性⁴⁴。兩位作者認為反思均衡應該從深思熟慮的判斷（considered judgments）⁴⁵出發，以反思均衡的方式，來檢證、調整深思熟慮的

不同的道德觀，但是常會做出相同的判斷，即便背後所依據的道德論證有顯著的差異，*id.* at 351, 354-84.

40 *Id.* at 383-84.

41 *Id.* at 384.

42 *Id.* at 13.

43 *Id.* at 390. 兩位作者也把原則的解釋適用、權衡衝突分別視為獨立的方法，但認為這兩種方法仍須訴諸證成，必須有經過證成的理由為依據。

44 *Id.* at 404-05.

45 「深思熟慮的判斷」指的是以一般人的道德能力，最不可能出錯的判斷，像是認為是種族歧視、宗教打壓跟政治迫害是錯誤的。*Id.* at 405.

判斷及其於具體個案中的適用，以使其與一般的道德標準相符合⁴⁶。此處的反思均衡是一個持續進行且永無終點的過程，因為實際上要讓所有的理念與判斷都具有 consistency 且互相調和的情形幾乎無法達成，但仍舊須要儘可能的不斷反思、修正我們的信念，以回應不斷出現的新挑戰⁴⁷。

但值得注意的是，縱使證成的過程在原則主義的分析架構中扮演要角，原則的運用，須要仰賴證成的過程進行解釋適用，然而證成的方法是屬於二階問題（second-ordered problem），有別於四原則是為一階的（first-ordered）倫理問題⁴⁸。Beauchamp與Childress似乎認為，四原則代表具有普世性道德價值的實體面向，而證成所代表的是解釋適用方法的程序面向。然而，此種區分似乎低估了證成在該架構中重要性，以及證成方法本身也代表著某種實體價值。

Beauchamp和Childress在該書中所揭示的原則及分析架構，相較於貝爾蒙特報告，提供了更為完整且具有體系性的架構，至今仍指引著各生命倫理議題的論述。

2. 對原則主義的批評

原則主義雖居於生命倫理論述的主流地位，但仍有其他的觀點存在，並且對於原則主義提出批評。批評的觀點主要有二：一是方法論的。批評者有認為此架構的層次不夠高，缺乏背後更高的道德原則，對於如何解釋適用於個案也缺乏明確指引，對於進行道德判斷沒有幫助⁴⁹。另一種批評則認為，原則主義的層次不夠低，原則

46 *Id.*

47 *Id.* at 406.

48 *Id.* at 368.

49 BERNARD GERT ET AL., *BIOETHICS: A RETURN TO FUNDAMENTALS* 75 (1997); Ezekiel J. Emanuel, *The Beginning of the End of Principlism*, 25(4) HASTINGS CTR. REP. 37, 37 (1995); John Harris, *In Praise of Unprincipled Ethics*, 29 J. MED. ETHICS 303, 303 (2003).

太過抽象而不夠具體，應該要改為由下而上，以具體個案分析為出發點⁵⁰。對此類方法論的批評，Beauchamp與Childress仍維持原則主義作為中間理論（middle-ground theory），認為原則主義的優勢在於其立基於共同道德，在多元社會中尋求不同道德理論間的共識，並且認為透過「反思均衡」的證成方法，能夠融合演繹法與歸納法⁵¹。

另一對原則主義的批評，則集中在原則主義理論面的不足。除原則主義之外，也有其他不同倫理觀，歸納其批評，有幾個共通點：其一是針對原則主義所主張立基於共同道德的普世性，但批評者認為，原則主義預設個體的共通性，不考量實際上的個體差異。而且將個體抽象化的過程，常會流於宰制者的觀點，而未能考量弱勢者的處境⁵²，同時也無法掌握個體所處的情境與人際互動，忽略除了道德義務以外的愛、關懷、照護、德行、感情或社群價值⁵³。亦有論者從文化的觀點出發，認為原則主義的出發點是西方（美國）價值，非必然可以適用於其他文化⁵⁴。其二是針對原則主義所預設的個人自主性，批評者認為此預設係基於自由個人主義下原子式的自我（atomic selfhood），然而對於自主的理解不應該是去脈絡化的，而應該考量個人所處的社群、其人際網絡中之關係與權力結構⁵⁵。再者，過於強調個人自主性，也使得分析觀點過於集中於個人之間

50 John D. Arras, *A Case Approach*, in *A COMPANION TO BIOETHICS* 106, 106 (Helga Kuhse & Peter Singer eds., 1998).

51 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 375-78, 381.

52 Anne Donchin & Jackie Leach Scully, *Feminist Bioethics*, *STAN. ENCYCLOPEDIA PHIL.* (2012), <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/feminist-bioethics/>; Jan Crosthwaite, *Gender and Bioethics*, in *A COMPANION TO BIOETHICS* 32, 37 (Helga Kuhse & Peter Singer eds., 1998).

53 Anne Donchin, *The Expanding Landscape: Recent Directions in Feminist Bioethics*, in *FEMINIST BIOETHICS: AT THE CENTER, ON THE MARGINS* 11, 15 (Jackie Leach Scully et al. eds., 2010).

54 Soren Holm, *Not Just Autonomy: The Principles of American Biomedical Ethics*, 21(6) *J. MED. ETHICS* 332, 333 (1995).

55 Donchin, *supra* note 53, at 18.

點對點的關係，較少納入群體的思維⁵⁶，也較無法深入處理結構不平等的問題。原則主義預設且強調個人自主性的觀點，無法體察弱勢群體所處之不利益地位，也無法達成賦權（empower）並改善其地位的效果⁵⁷。

然而，前述批評聲音其實也非全盤否定原則主義，而是指出主義的不足之處，並且提出修正或補強。Beauchamp與Childress的回應認為，這些質疑與原則主義的架構並不相衝突，並主張原則主義也能夠融合前述質疑所採的觀點⁵⁸。但Beauchamp與Childress所主張之融合方式，並無意修改既有的四原則，認為德行、道德與四原則屬於不同領域⁵⁹，而人際關係也無法抽象化為一般原則⁶⁰，故他們提出的融合管道主要發生於證成的過程中，例如認為德行與感情具有補充功能，能幫助人們對於道德有更全面性的瞭解並做出道德判斷，或是認為德行理論最能夠貼切為臨床上醫療決定的實況提供建議⁶¹，這些都理應發生在證成的過程之中。但若進一步觀察Beauchamp與Childress對於如何將批評觀點融入證成的過程，其實他們並沒有提出更為詳細的依據，只有提到兩個面向：一個是認為決策者若是醫療專業人士時，應該依據專業倫理為判斷⁶²；另一則是認為，公共討論（public deliberation）應該是解釋適用各原則所循的程序⁶³，但對於誰應該為德行、照護、關係或社區價值發聲，又如何將這些觀點那入決策，原則主義並未提供足夠的線索。

56 Susan M. Wolf, *Introduction: Gender and Feminism in Bioethics*, in FEMINISM AND BIOETHICS: BEYOND REPRODUCTION 3, 17 (Susan M. Wolf ed., 1996).

57 Susan Sherwin, *Feminism and Bioethics*, in FEMINISM AND BIOETHICS: BEYOND REPRODUCTION 47, 53 (Susan M. Wolf ed., 1996).

58 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 37, 79, 64.

59 *Id.* at 57.

60 *Id.* at 37.

61 *Id.* at 373-74.

62 *Id.* at 33-35.

63 *Id.* at 19, 23, 140, 189, 260, 270, 285.

三、改革方向：民主審議的納入

由前述關於生命倫理原則及原則主義架構的發展及批評，可知現行架構有若干不足處。其一，程序面較缺乏明確指引，對於如何將抽象原則解釋適用於具體個案，又如何調和原則間衝突，除了抽象的反思均衡之外，並未能提供更為詳盡可實際運作之方法。再者，生命倫理原則及原則主義的預設立基於個人的理性自決能力，群體面向較未被強調，也較缺乏對個體差異以及多元性的關懷。

對此，女性主義者實已有類似的批評，認為原則主義雖然訴諸共同道德並且追求達成理性共識，但是對於達成共識的社群、達成的方式，卻未能提供任何線索⁶⁴。女性主義論者其實已有提出將生命倫理民主化的觀點，主張參與生命倫理對話的社群應該更具多元性，尤其是須將素人（lay people）的觀點納入考慮，以及強化那些過去代表性不足者的聲音⁶⁵。女性主義強調包容性（inclusiveness）的重要，在追求共識達成的過程，應該儘可能納入不同觀點⁶⁶。又或者如對話論者（conversationalist）認為，倫理的形成，應該是透過對話的方式為之，而非依賴專業判斷。而對話之所以有力，不僅是因為如此能夠適當的解釋原則，更在於促成不同觀點之間的共識，或者在無法達成共識時，至少讓不同的觀點引進討論⁶⁷。比起達成共識，對話論者更強調涵蓋多元觀點，甚至認為保存某些差異或衝突有其必要性⁶⁸。

⁶⁴ Wolf, *supra* note 56, at 25. 女性主義者指出，某些族群或觀點長期被排除於共識形成的程序以外，例如病人或受試者權利是生命倫理的核心議題，但是他們在決策過程中多半是被討論的對象，而很少成為參與討論的一員，Wolf, *supra*, at 25.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.* at 25-26.

⁶⁷ Rosemarie Tong, *Feminist Approaches to Bioethics*, in *FEMINISM AND BIOETHICS: BEYOND REPRODUCTION* 67, 70 (Susan M. Wolf ed., 1996).

⁶⁸ Michael Parker, *Deliberative Bioethics*, in *PRINCIPLES OF HEALTH CARE ETHICS* 185, 190 (Richard E. Ashcroft et al. eds., 2d ed. 2007).

從前述女性主義與對話論者的看法，對於生命倫理原則及原則主義架構提供了一項共通的看法，即對於達成共識的程序予以重視，且應該以更為具有包容性的方式為之，將傳統架構下比較不重視的觀點納入。此種看法其實與生命倫理這個領域的傳統相符合。如同生命倫理學家Jonsen所述，生命倫理是一個持續且具目的性、向大眾開放的政治論述，讓非科學家能夠參與涉及醫療、生命科學與技術所引發道德爭議的討論⁶⁹。另一位生命倫理學家Michael Park也指出生命倫理是政治的，用以對於人類生命有關的制度、社會關係和運作進行規範分析，而生命倫理學家也必須謹記此政治性，並且將民主審議的概念引入生命倫理中⁷⁰。鑑於生命倫理這樣政治性的本質，民主審議的重要性不言而喻，亦是現行生命倫理原則及原則主義分析架構中尚未被正視之部分。而Beauchamp與Childress並非完全沒有提到民主審議，然而在其原則主義的架構下，向來認為證成的過程是一個二階問題（second-ordered problem），有別各生命倫理原則的形成與內涵為一階（first-ordered）問題，並不屬於同一層次⁷¹。

本文以下將提出「民主審議」被視為新興原則之趨勢，並且支持這樣的觀點，主張民主審議也應該列為一項生命倫理原則，與現行的各生命倫理原則並列。民主審議對於目前架構所欠缺的共識形成或決策程序，提供程序指引；再者，民主審議也被運用於實體，據以提出政策建議。因此，民主審議的地位不僅止於二階層次的論證方法，也在一階層次指引實體決策⁷²。另須附帶說明的是，目前

69 JONSEN, *supra* note 10, at 11, 13, 353.

70 Parker, *supra* note 68, at 185.

71 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 390.

72 提出民主審議原則的歐巴馬總統任命之總統生命倫理議題研究委員會，不僅認為民主審議是該委員會決策應該踐行的程序，也運用此原則提出了許多實體的建議，詳見後述「伍、二」。是以，「民主審議」同時有一階和二階的面向，本文認為不論哪一階，重要性皆足以使其與現行各倫理原則並列。

的生命倫理原則的清單並非窮盡而無增加之空間；從貝爾蒙特報告作成的過程中，可知本來有更長的清單⁷³。多數見解都能同意，生命倫理清單應該是開放的，且應該不斷受到公眾的辯證、與時俱進。

參、民主審議作為一項生命倫理原則

鑑於現有生命倫理原則之不足，而主張民主審議應作為新興生命倫理原則，並非是本文所獨創之見解，而是有美國國家級之生命倫理委員會過去的各项報告，以及其他國際實踐為佐證⁷⁴。在美國國家級生命倫理委員會多項報告中，便有明示及暗示的引用民主審議作為指引原則，並實際運用於個別議題的政策建言中⁷⁵。而在歐巴馬總統任命之總統生命倫理議題研究委員會於2010年開始，以及其後的每項報告中，皆以明示或暗示之方式，將民主審議列為作為指引該委員會進行新興科技政策評估的倫理原則；而在該委員會2016年卸任前之總結報告，更是明確提到民主審議應作為生命倫理領域政策決定指引，以及民主審議應該廣泛實施於從國家到私人機構的各領域中⁷⁶。實則民主審議被列為倫理原則，與此屆委員會主

73 貝爾蒙特報告中也提到，三原則是「從那些（among those）我們文化傳統中所廣為接受」的人體研究倫理原則之中，被選出來最具重要性的，顯示還有其他也被廣為接受之倫理原則，see NAT'L COMM'N, *supra* note 16（粗體字為本文所加）。研究也發現學者與不同文件中的生命倫理清單其實版本眾，從單一到數十不等，Robert M. Veatch, *How Many Principles for Bioethics?*, in PRINCIPLES OF HEALTH CARE ETHICS 43, 44-49 (Richard E. Ashcroft et al. eds., 2d ed. 2007).

74 詳參後「參、三、(一)」2及3所述。

75 詳參後「參、三、(一)」2所述。

76 各報告提及民主審議之部分，詳參後「參、二」所述。國內相關文獻亦可參考：張兆恬，民主審議作為一項生醫研究倫理原則——國際人權、美國法及台灣經驗之考察，中華國際法與超國界法評論，8卷2期，頁269-298（2012年），惟該文討論範圍，主要係論證民主審議在生醫研究倫理上之運用；相較之下，本文主張民主審議得提升為一項生命倫理原則，並且廣泛適用於生命倫理領

席為著名的審議民主論者Amy Gutmann，或許有相當的關聯。早在1997年，Gutmann及其諸多審議民主論著的合著者Dennis Thompson即曾為文主張，審議民主能夠為生命倫理的論述，提供最好的論壇⁷⁷。然而，這樣的趨勢究竟是歷史的偶然，或者是其來有自？本文深究民主審議原則之內涵，發現此原則兼具程序及實體之面向，為現有各原則之內容所無法完全涵蓋；再者，此原則也符合成為生命倫理原則的要件：歷史性、普世性及重要性，尤其可以補足現有架構缺乏對於程序之指引，以及提供現有原則所欠缺關注的社群觀點及脈絡化的觀點。是以，該新原則之興起並非歷史偶然，而是同樣具有來自共同道德的根基，且是為因應生命科學之複雜科學與倫理問題所必要。

一、何謂「民主審議」

（一）Gutmann與Thompson的審議民主理論

在討論此一趨勢之前，為釐清何謂「民主審議」，本文援引審議民主（deliberative democracy）理論加以說明，即便兩者概念略有差異。又若考量提出民主審議原則的總統生命倫理議題研究委員會之主席為Gutmann，或可經由其審議民主理論，來理解該原則之內涵。

根據Gutmann與Thompson的見解，審議民主是一種政治哲學理論，專用以處理社會上的道德歧見（moral disagreement）⁷⁸。由於多元民主社會中，充滿各種基本價值的衝突，審議民主為其提供理想政府的模式：也就是自由且平等的公民及其代表，必須透過提出

域，兩者所主張之適用範圍有所不同；且本文另一焦點，在於論證民主審議「倫理原則化」的必要性，而非僅止於主張民主審議是一個較好、較符合倫理的決策模式，詳參後「肆」所述。

77 Amy Gutmann & Dennis Thompson, *Deliberating about Bioethics*, 27(3) HASTINGS CTR. REP. 38, 38 (1997).

78 AMY GUTMANN & DENNIS THOMPSON, *DEMOCRACY AND DISAGREEMENT* 1 (1996).

相互能夠知悉、接受的理由的過程，來正當化其決定，並且以達成目前能拘束所有公民的結論為目標，然而這項結論是開放性的，將來仍可挑戰⁷⁹。這樣相互證成的過程，也是審議民主認為決策正當性的來源。

對Gutmann與Thompson來說，審議民主最重要的特徵是提供理由（reason-giving）⁸⁰。各種決策必須要提供理由，原因在於公民本身是具有自主性的主體，有能力自行或者透過其代表參與其所處社會的治理，而並非被動的客體，是以必須要對其提供理由，且理由必須是自由、平等且願意合作的公民所能接受的⁸¹。理由必須要以對象能夠取得的方式提出，具體來說，也就是審議要以公開、能夠喚起公眾關注的方式為之⁸²。再者，審議民主強調暫時性和動態性，審議的結論在特定期間之內具有拘束力，雖然審議並不排斥達成一個永久性的結論，但必須保留達成結論後繼續對話的空間，以及對於該議題的持續關注⁸³。

Gutmann與Thompson進一步闡述審議民主的內涵，認為審議民主的進行必須符合三項原則：互惠（reciprocity）、公開（publicity）和責信（accountability）⁸⁴，其中又以互惠最為重要，是審議中如何進行說理（reasoning）的指導原則⁸⁵。根據互惠原則，公民應該提供彼此都能接受的理由，以追求共識；即便無法達成共識，公民也應該繼續追求能夠平等合作的方式⁸⁶。面對道德歧見時，基於互惠原則，公民應該追求道德協調（moral accommodation）——除了

79 AMY GUTMANN & DENNIS THOMPSON, WHY DELIBERATIVE DEMOCRACY 7 (2004).

80 *Id.* at 3.

81 *Id.*

82 *Id.* at 4-5.

83 *Id.* at 5-6.

84 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 52; GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 7.

85 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 53.

86 *Id.*

消極對於歧見寬容以外，亦應積極尋求將來的解決之道，尤其應該追求「道德歧見簡約」(economy of moral disagreement)，也就是公民應該追求合理的最小化與反對者之間的差異，也就是在即便無法完全消除歧見時，也追求相互能夠接受的解決方式⁸⁷。再者，審議應該以公開為原則，即理由應該公開，並提供相關資訊⁸⁸；審議亦應該以符合責信的方式為之，也就是對於那些受到決策影響者，負有提出理由的義務⁸⁹。Gutmann與Thompson也認為，審議民主不僅是程序性的，也具有實體面向，並且提出基本自由、基本機會、機會平等，作為審議的主要內容，同時也是審議內容所不能逾越的界限⁹⁰。

至於審議民主有哪些優勢，Gutmann與Thompson則指出，可以從審議民主如何處理道德歧見的四大來源，來論證其優勢。首先，審議民主有助於提升決策的正當性，解決因為資源稀少所帶來的歧見，因為審議的過程中不同意見能夠被適當的考慮，使得結果較能為利害關係者所接受⁹¹。其二，審議民主有助於促進公共精神(public-spirited)的觀點，解決因為缺乏寬容所帶來的歧見，透過審議提供公民於平等地位下相互瞭解的機會⁹²。其三，審議民主也有助於相互尊重，降低因為道德價值無法調和所帶來的歧見，透過審議的過程，公民能夠瞭解到不同意見主張的可取之處，因而即便不同意，也能相互尊重⁹³。其四，審議民主有助於除錯，減少因為

87 *Id.* at 79-85.

88 *Id.* at 95. 然而，在Gutmann與Thompson的理論中，也承認有時必須容許審議以非公開之方式為之，但必須要給予公眾辯論非公開是否合理，以及非公開是否對於公共政策的作成有利，*id.* at 117.

89 *Id.* at 128.

90 *Id.* at 12, 199-201, 348.

91 *Id.* at 41-42; GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 10.

92 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 42; GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 11.

93 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 11.

瞭解不完全所造成的歧見，因審議是一個不斷檢證的互動過程，在此過程中公民能夠進行自我校正，並且也能夠察覺什麼是最有助於整體利益的⁹⁴。簡言之，Gutmann與Thompson認為審議民主的優勢在於處理道德歧見，提供有品質的決策；並藉由審議的過程提升公民德行（civic virtue），而能夠在歧見中尋求共識、相互尊重。

綜上，或可歸納出Gutmann與Thompson審議民主理論的核心，在於說理和求取共識，也就是應該對於任何決定，應該附加利害關係者間得以接受之理由加以證明，並且追求道德歧見中的共識。再者，審議民主另一要素為公民參與，即便在Gutmann與Thompson的理論中未明文強調，然而若從互惠、公開及責信的角度觀之，若無法提供具有足夠包容性（inclusiveness）的程序，將利害關係者納入審議的程序，審酌其觀點並提供其可接受之理由，顯然無法符合審議的要件⁹⁵。審議民主預設公民具有自治的能力，以及在審議的過程中養成公民的公共精神，亦意味著公民參與在審議民主中的重要性。

（二）「民主審議」與「審議民主」之異同

由於總統生命倫理議題研究委員會是以「民主審議」作為生命倫理原則，而非使用「審議民主」，故需探討兩者之差異何在。

94 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 43; GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 11.

95 其實在代議政治中不乏審議元素，國會被視為進行審議的重要論壇，且審議以背景知識及具備表達、回應的能力為基礎，亦被批評為具有菁英色彩。然而若考察審議民主之發展歷史，部分係承襲1970年代參與民主對於代議民主的批判，可知審議民主並非推崇菁英政治。參與式民主認為公民有能力參與政治，並且唯有透過參與，才能夠使人民成為公民，將個人偏好轉化為公共利益考量，此觀點亦為審議民主所肯認。James Bohman & William Rehg, *Introduction*, in *DELIBERATIVE DEMOCRACY: ESSAYS OF REASON AND POLITICS*, at ix, xi (James Bohman & William Rehg eds., 1997); BENJAMIN R. BARBER, *STRONG DEMOCRACY: PARTICIPATORY POLITICS FOR A NEW AGE* 151, 157 (2003).

一說認為，差別在於兩者關注焦點與背後傳統的不同。「審議民主」通常是哲學性的用語，認為審議必須以達成理性、共同善（common good）的共識為目標，也是民主正當性的唯一來源。這樣的看法，來自於對於當代民主政治決策淪為私利競逐的批判⁹⁶。相較之下，「民主審議」則是政治學的用語，採取較為寬鬆的觀點，認為除了來自追求理性共識的審議程序以外，也不排斥其他民主程序作為正當性來源，例如審議後進行多數決表決，並不會因為採多數決便喪失正當性⁹⁷。

另一個看法則認為，「審議民主」的重點在於程序，而「民主審議」的重點在於結果，兩者之區別在於審議是否與決策相連結⁹⁸。提出此看法的Simone Chambers發現，「民主審議」主要是在指那些由人民聚集起來對於公共議題達成共識的活動，重點是審議與作成某個共同決定相連結⁹⁹。故討論民主審議的文獻，多半是在討論怎樣的組織或設置，能夠讓公民聚集起來決定某些事情，例如透過公民會議的設計，以促進公民參與審議¹⁰⁰。另一方面，「審議民主」關注的範圍較廣，主要在於人民、公民社會與政府之間的關係，除了公民會議這類活動中的審議的以外，也同樣關注公民日常生活中的審議¹⁰¹。Chambers也發現「民主審議」由於與決策的作成相連結，所以使用頻率上升，相較之下「審議民主」則趨於退潮，

96 Jane Mansbridge, "Deliberative Democracy" or "Democratic Deliberation"?, in *DELIBERATION, PARTICIPATION AND DEMOCRACY: CAN THE PEOPLE GOVERN?* 251, 251 (Shawn. W. Rosenberg ed., 2007).

97 *Id.* Mansbridge似乎比較偏向民主審議，認為在民主過程中，除了那些基於理性、共同善所為之主張外，其他主張的存在，像是情緒性表達、討價還價（bargaining）等，也會有益於民主政治，特別是有助於提升弱勢族群參與的程度，*id.* at 255-57.

98 Simone Chambers, *Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy?*, 37(3) *POL. THEORY* 323, 324 (2009).

99 *Id.*

100 *Id.* at 332.

101 *Id.*

並對此趨勢感到憂心¹⁰²。Chambers主張，應該回歸「審議民主」概念對於審議程序的重視，同時也認為審議不應限於在特定小群體中，而應該發生於廣大的公眾領域、人民的日常生活中¹⁰³。

歸納前述論者提出的區別，或可發現「民主審議」與「審議民主」的內涵大致相同，但對於審議本身、審議與決策間之連結，則有不同的關注焦點。「民主審議」指的是實際政治中較好的決策過程，通常在適合的特定論壇中進行，會作出審議的結果並與決策相連結；而「審議民主」指的是理論上理想的決策模式，公民運用理性進行討論，以追求符合共同善的共識為目標。由前述區別，應不難理解為何總統生命倫理議題研究委員會選擇使用「民主審議」為生命倫理原則，以為醫療專業人士、研究者、倫理委員會、政府官員等提供決策作成的指引，並且也容許其他非審議程序的決策。前述Chambers對於「民主審議」侷限於特定論壇的憂心，也足以為鑑，思考若欲達成「民主審議」的落實，除了加強倫理委員會中的審議以外，是否也應該進一步引進公眾。以下分析總統生命倫理議題研究委員會所作成的各報告，亦可發現有引進廣大公眾參與之趨勢。

二、民主審議逐漸確立其原則性的地位——美國總統生命倫理議題研究委員會報告顯示之趨勢

總統生命倫理議題研究委員會係於2009年11月由歐巴馬總統命令成立，成員於2010年春季就任，任期至2016年12月¹⁰⁴，該員會被廣泛授權對於新興科技進行政策建議¹⁰⁵。在該委員會於2010年底做成的第一份報告，針對合成生物學（synthetic biology）及其相關科

¹⁰² *Id.* at 324.

¹⁰³ *Id.* at 323-24.

¹⁰⁴ Executive Order 13521 (Nov. 24, 2009); Executive Order 13591 (Nov. 23, 2011); Executive Order 13652 (Sept. 30, 2013).

¹⁰⁵ Executive Order 13521 § 6(a) (Nov. 24, 2009).

技所衍生的倫理問題進行政策建議時，該委員會在報告中列舉評估新興科技社會效應所應遵循的五原則中，即包括民主審議這一項¹⁰⁶。報告中所列其他原則，雖用語與傳統四原則略有不同，但概念上實與四原則有相對應之處¹⁰⁷，而僅有民主審議是獨立且無法完全由四原則衍生而來的。該報告指出：民主審議原則代表一種合作性的決策程序，透過此程序能夠進行不同意見間的辯論並保持相互尊重，並促進公民積極參與¹⁰⁸；民主審議的目的，在於促進討論風氣，促使決策做成能夠循求共同可接受基礎，以及差異無法化解時促進相互尊重¹⁰⁹；民主審議所追求的，是作成「具包容性、深思熟慮又尊重競爭觀點」的結果¹¹⁰。在該報告中，適用民主審議原則所產生的具體政策建議，包括：促進公眾對話的持續進行、追求科學知識的正確性、提升大眾的科普知識，以及促進草根性的科學參與合作¹¹¹。

此後的報告中，總統生命倫理議題研究委員會又重申民主審議作為指引各項報告的原則性地位。歸納之下，包括下列幾種觀點：

一類出於程序面的觀點，亦即將此原則視為委員會本身組成、任務執行所遵循的方式。例如在2012年隱私與全基因組定序科技的報告中，再次提出前述合成生物學報告所揭示的五項檢視新興科技的原則，作為分析本件全基因組定序科技社會影響的架構，其中自

106 PCSBI, NEW DIRECTIONS: THE ETHICS OF SYNTHETIC BIOLOGY AND EMERGING TECHNOLOGIES 4 (2010), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10_0.pdf.

107 *Id.* at 4-5. 有利公眾 (public beneficence)、正義與公平 (justice and fairness) 與顯然是重申既有原則；負責的管理者 (responsible stewardship) 可來自不傷害原則；智慧自由與責任 (intellectual freedom and responsibility) 則能從不傷害與尊重自主中推演出來。

108 *Id.* at 5.

109 *Id.* at 151.

110 *Id.* at 30.

111 *Id.* at 152-60.

然也包括民主審議原則¹¹²。然而在此報告中，民主審議的定位是後設的（meta），委員會指出其作成本報告的過程是依據民主審議原則，廣納不同意見而為之，而委員會本身的設立也是基於民主審議之精神¹¹³。本報告也援引審議民主的暫時性（provisionality）特徵，認為目前的結論是暫時性的，考量基因科技的進步、更廣泛的臨床運用，應對於目前政策持開放、將來持續修正的態度¹¹⁴。又如2013年關於兒童作為小兒科醫學受試者議題的報告中，該委員會也持類似觀點，指出早在作成貝爾蒙特報告的國家生醫與行為研究倫理委員會於設立之初，即已經依據民主審議原則運作¹¹⁵。

另一類是實體面的討論，亦即依據民主審議原則之適用，作出政策面的建議，以使政府於決策上落實此原則。例如前述2013年兒童作為小兒科醫學受試者議題的報告中，委員會建議在此類醫學研究之審核程序，需落實民主審議。且落實方式，並非僅止於在現行法定之各機構倫理審查委員會（institutional review board, IRB）中，也要求各以兒童為受試者之研究，若有高於最低風險且對健康兒童無直接利益的情況，則應該組成專家會議（expert panel）向其諮詢，並且給予公眾表示意見之機會¹¹⁶。委員會也認為民主審議能夠落實於透明、責信以及廣泛社區參與等面向¹¹⁷。

112 PCSBI, PRIVACY AND PROGRESS IN WHOLE GENOME SEQUENCING 3-4 (2012), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/PrivacyProgress508_1.pdf.

113 *Id.* at 30.

114 *Id.* at 49-50.

115 PCSBI, SAFEGUARDING CHILDREN: PEDIATRIC MEDICAL COUNTERMEASURE RESEARCH 3, 20, 34 (2013), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/PCSBI_Pediatric-MCM508.pdf [hereinafter PCSBI, SAFEGUARDING CHILDREN]. 採取類似程序觀點者，尚有：PCSBI, ANTICIPATE AND COMMUNICATE: ETHICAL MANAGEMENT OF INCIDENTAL AND SECONDARY FINDINGS IN THE CLINICAL, RESEARCH, AND DIRECT-TO-CONSUMER CONTEXTS 31-32 (2013), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/FINALAnticipateCommunicate_PCSBI_0.pdf.

116 PCSBI, SAFEGUARDING CHILDREN, *supra* note 115, at 3.

117 *Id.* at 9, 35-36.

2014年檢視腦神經科學倫理議題的報告中，則闡述要如何讓倫理的思考納入科技發展架構中，民主審議扮演關鍵角色。面對潛力無限，且有許多未知領域的腦神經科學，本報告的一項重要結論，在於應該及早將倫理的概念融入此新領域¹¹⁸。考量到腦神經科學的潛力，以及此學門的知識將如何影響我們對於自主性的理解，有必要即早檢視其倫理與社會影響力，並將倫理的概念提早納入科學的架構中，而民主審議正能夠扮演此融合的角色¹¹⁹。報告中認為須要及早納入倫理的理由主要有兩個：其一，科學發展具有促進全人類福祉的潛力，使得社會負有支持科學的義務；科學家的專業倫理中，也負有使科學朝促進公益方向發展，以及評估科學發展風險之義務，故科學的公益責任不僅是因為許多研究受到政府補助，也來自於這些倫理上的義務¹²⁰。再者，科學中隱含許多價值決定，包括研究資源分配，以及研究中的各項行為、分析，都有價值決定存在，故在科學領域還在發展之初，即將倫理的分析納入於評估效益、發展新模型等面向，實與科學的本質相符合¹²¹。報告中提到，民主審議對於將倫理融入科學一事，扮演著相當關鍵性的角色：民主審議是一個合作性質、容許公民就不同意見進行討論並保持相互尊重的過程，而在一個開放社會中，社會價值必須要透過這樣的過程來形成¹²²。其後在2015年關於腦神經科學的第二份報告中，也再次重申在面對爭議性的科技與倫理問題時，民主審議之重要性¹²³。

118 PCSBI, GRAY MATTERS: INTEGRATIVE APPROACHES FOR NEUROSCIENCE, ETHICS, AND SOCIETY 2 (2014), <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/709231/Gray%20Matters%20Vol%201.pdf?sequence=1>.

119 *Id.* at 14.

120 *Id.* at 15.

121 *Id.*

122 *Id.*

123 PCSBI, GRAY MATTERS: TOPICS AT THE INTERSECTION OF NEUROSCIENCE, ETHICS, AND SOCIETY 45 (2015), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/GrayMatter_V2_508.pdf.

在2015年關於伊波拉病毒之公衛議題與倫理的報告中，則特別於開宗明義提到：美國政府必須以符合倫理的方式，為將來傳染病爆發所為之公共衛生緊急因應措施做準備，尤其在作出因應的過程，應該實踐刺激公共討論的民主審議（provocative democratic deliberation），以反應在多元社會以及全球化趨勢下的公共價值¹²⁴。報告分析不斷提到民主審議在公衛決策上的重要性，認為公衛政策若僅考量健康安全面向，恐怕無法確切描述人民所受到的痛苦，以致於政策無法與國家利益相符¹²⁵。公共衛生政策須要公民參與，不僅是基於人道的立場，而是民主審議本身就是一種理想的決策方式，適於在作成緊急公衛應變時使用，因為民主審議程序的優勢在於達成共識，尤其是在有無法化解的道德分歧時，仍能夠求取雙方都可暫時接受的共識；並且能夠促進公益的觀點，讓利害相關的族群參與決策，以及將來若有新資訊時得以隨時再檢視¹²⁶。報告中也指出，危機之中或者之後進行民主審議確實較為困難，但委員會仍堅持緊急時必須有一定的公眾參與，原因是透明性有助於公共信賴，使得政策得以順利執行，或者依據對受影響族群的效應進行修正¹²⁷。委員會也認為，歷史上許多公衛政策的成功推行，都有賴於專業社群與公民社會進行緊密的合作，縱使因急迫性不同而採取不同方式，透明且公開之公眾參與確有其必要¹²⁸。本報告雖未明文操作生命倫理各原則，但其所提出之政策建議中，亦企圖將民主審議概念加以落實¹²⁹，足見民主審議對於本報告政策建議之引導性。

124 PCSBI, ETHICS AND EBOLA: PUBLIC HEALTH PLANNING AND RESPONSE 3 (2015), https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/Ethics-and-Ebola_PCSBI_508.pdf.

125 *Id.* at 8.

126 *Id.*

127 *Id.* at 9.

128 *Id.*

129 例如政策建議中提到：政府應該有責任落實傳染病相關的公民教育與公共溝通，作為正當化公衛措施的基礎；政府對於其所採取的限制措施（如隔離

再者，總統生命倫理議題研究委員會少數沒有直接提到民主審議的報告，也以暗示之方式，提出具有民主審議精神之政策建議。2011年底一項檢討美國現行人體研究法規的報告中，委員會發現：現行法對於聯邦政府所補助之科學研究中的自願受試者，已經提供足夠的保障，其實並沒有規範不足的問題，真正的問題，其實在於政府的執法能力不足¹³⁰。是以，委員會作出的建議中，也出現了傳統四原則所無法涵蓋的項目¹³¹：其一為提升研究者責信，本報告呼籲應該要透過加強透聯邦政府所補助研究透明性的方式，使研究者受到公眾監督¹³²；其二為社區參與（community engagement），指的是給予社區民眾瞭解以及辯論研究風險與利益的機會，委員會認為有效的社區參與，形同是對於受試者對一層保護，亦有助於提升研究者責信¹³³。

以上總統生命倫理議題研究委員會的幾項報告，或許運用的範圍仍限於新興科技評估¹³⁴，然而在該委員會卸任前的總結報告，則更進一步揭示將民主審議廣泛適用於所有生命倫理議題之意旨。2016年3月總統生命倫理議題研究委員會在其任內最後所提出的總結性報告，題為「符合每一個世代的生命倫理——健康、科學與技

等），應該負有公眾說明、回覆公眾質疑之義務；傳染病人體研究之研究團隊，於設計試驗時應該與利害關係社群進行溝通，以確定研究設計能夠符合倫理且具備科學價值，*id.* at 19, 31, 42.

130 PCSBI, MORAL SCIENCE, *supra* note 6, at 5.

131 該報告的其他建議都可與傳統四原則相呼應，像是：若他國法域給予受試者相同的保護應予以尊重（尊重自主原則）；建立保護受試者的專業倫理標準、確保試驗對照組的設計符合倫理標準（不傷害、為善原則）；對於因受試而造成的傷害予以治療及補償、正當化試驗據點的選擇（正義原則），*id.* at 6-16.

132 *Id.* at 7, 53-55.

133 *Id.* at 11-12.

134 實則，總統生命倫理議題研究委員會設立時之任務，便是以對於新興科技的倫理評估為其組織任務，Executive Order 13521 § 2(a), (b) (Nov. 24, 2009)。故該委員會使用民主審議為原則時，自然也是用於此類議題的評估上。然而，從該委員會最後一項報告，更進一步明確宣示將民主審議應廣泛用於生命倫理領域中，亦可證實該委員會之真意，並非認為此原則僅限於新興科技評估。

術的審議及教育」¹³⁵。該報告認為，生命倫理議題所涉及者，往往是我們作為民主社會以及全人類一員的問題，歧見無可避免，故須透過理性審議來理解各參與者的價值，並且對於相衝突的價值進行溝通及讓步¹³⁶。值得注意的是，該報告明確指出：民主審議是最適合生命倫理的程序，兩者皆需要合作的決策和包容的觀點¹³⁷，生命倫理的本質在於處理倫理衝突及挑戰，而審議的重要性則是有助於求取共識，並且使倫理上複雜的爭議能夠獲得進展¹³⁸。此報告不僅舉美國和英國過去將審議用於生命倫理決策的經驗為證，也檢視了任內各項報告中的審議元素¹³⁹，並於政策建議的第一項明文提到：應該將民主審議作為生命倫理政策決策的指引，也就是利害關係人應該透過各種民主審議的管道，來參與健康與科技決策，而公共政策制定者、社區、各倫理委員會也應該以民主審議的方式為決策，以提升利害關係人的相互尊重以及決策正當性¹⁴⁰。該報告也提到，國家生命倫理委員應該作為引進公民參與、傾聽公民回覆的論壇，並且應推動倫理教育，使得公民將來都具備參與審議的能力¹⁴¹。同時，由於生命倫理的議題存在於社會各層級，故各層級——不論是全球、全國、州或地方政府，乃至於機構層級皆有民主審議的實踐¹⁴²；而各層級的生命倫理委員會（bioethics advisory bodies）應該扮演中介角色，作為實踐民主審議的論壇¹⁴³。

上述總統生命倫理議題研究委員會之多項報告，皆可佐證民主審議於現今生命倫理決策中，具有原則性、引導性的地位，不僅表

135 See generally PCSBI, EVERY GENERATION, *supra* note 6.

136 *Id.* at 2.

137 *Id.* at 3-4.

138 *Id.* at 4.

139 *Id.* at 14-17, 23-44.

140 *Id.* at 45.

141 *Id.* at 10-11.

142 *Id.* at 30-32.

143 *Id.* at 4.

現於倫理委員會的組成、運作上，更在實體面成為決策應該落實的方向。前述於2010年來的多項報告，一再將民主審議列為一項指引原則，本文認為此足以證實民主審議在生命倫理領域具有原則性的重要地位，並且足以與現有之各生命倫理原則並列。然而2010年來多項報告將民主審議原則化的趨勢，究竟是否僅是歷史的偶然，反應現任主席Gutmann審議民主理論的主張？本文以下將藉由現行生命倫理原則所共同具備之要件，檢視民主審議此一原則，以說明該原則具有其他原則相當之基礎。

三、民主審議符合成為生命倫理原則之要件

現有之生命倫理原則於1970年代確立其地位，即便當時至今一直有其他原則清單，但根據Beauchamp與Childress的主張，生命倫理原則是基於共同道德，而所謂的共同道德，是「人類歷史與經驗的產物，且具有普世性」¹⁴⁴；在貝爾蒙特報告中提到生命倫理原則的選出，是基於這些原則是「在我們文化傳統中所共同接受者」中最顯著的（relevant）¹⁴⁵。歸納現有生命倫理原則被選擇的共通原因，或許可以歸納出三要件：具有悠久傳統的歷史性（垂直面的共通性）、超越文化與國界的普世性（水平面的共通性），以及為道德或實踐上重要的重要性。若檢視此三要件，可發現民主審議皆符合：不論是在研究、醫院或者政策的倫理委員會，美國皆有長久審議的傳統；世界各國亦可發現民主審議於生命倫理議題討論、決策上之實踐；民主審議可以補足現行架構程序面及實體面的不足。經由上述要件之檢驗，亦可證明民主審議得以作為一項生命倫理原則。

144 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 1-4.

145 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

（一）歷史性

1. 倫理委員會的審議傳統

總統生命倫理議題研究委員會報告中多次提到，該倫理委員會本身是依據民主審議的概念組成、運作。實則，在美國法關於生命倫理事項的管制上，倫理委員會是一種很常見的管制組織，而這類的委員會的存在，正可證明民主審議在美國生命倫理領域中，有悠久的歷史傳統。美國管制上常見的倫理委員會，常見的特徵是由一群具備不同領域專長者組成，特別是除了科學與醫學以外，應該包括法律、宗教與社會科學的專家¹⁴⁶。倫理委員會的任務，是對於系爭科技或研究所涉及的社會與倫理問題進行評估。以倫理委員會之形式，邀集不同領域專家之原因，在於期望共識的形成，是經過不同觀點間進行辯論。倫理委員會依其任務又可分為兩大類：一類是對於具體個案進行判斷者，一類是廣泛對於政策進行建議者。

進行具體個案判斷者，最常見的型態是各機構的IRB。聯邦法規對於成員組成的多元性有所規範¹⁴⁷，其任務為審查以及監督人體研究之合法性及合倫理性¹⁴⁸。至於設在各機構中的優勢，則是考量各委員能夠運用其在地優勢，於審查時更能深入實際情況¹⁴⁹。過去國家生醫與行為研究倫理委員會曾在1978年一項關於研究倫理委員的報告中，描述IRB的決策過程為「審議」(deliberation)，因為IRB的審查，須考慮多元背景成員所代表的不同觀點，且以追求受試者（特別是易受傷害族群）福祉為目的¹⁵⁰。該報告也指出，IRB應該

146 See Susan Cartier Poland, *Scope Note 34: Bioethics Commissions: Town Meetings with a "Blue, Blue Ribbon"*, 8(1) KENNEDY INST. ETHICS J. 91, 91-109 (1998).

147 45 C.F.R. § 46.107 (2009) (包括至少五人以上成員，具有多元專業背景、包括不同性別、包括科學與非科學成員、包括機構外成員)。

148 Albert R. Jonsen, *The Ethics of Research with Human Subjects: A Short History*, in SOURCE BOOK IN BIOETHICS 5, 8 (Albert R. Jonsen et al. eds., 1998).

149 *Id.* at 54.

150 NAT'L COMM'N, INSTITUTIONAL REVIEW BOARDS 12 (1978), http://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_institutional_review_boards.pdf.

擔任地區資源中心，負擔教育研究社群和公眾研究倫理的任務¹⁵¹。

另一種常見者則是醫療倫理委員會（Healthcare Ethics Committee, HEC），由醫療機構設立，其任務在討論、建議或決定臨床上的倫理問題。HEC的設置目的，是期望能夠透過HEC的討論，促進不同行動者（包括醫護人員、病人本人、家屬、社會大眾）間的相互瞭解，有助於解決複雜的醫學、倫理與法律爭議¹⁵²。HEC的出現在美國始於1960年代，當時主要是用於決定分配洗腎的資源¹⁵³；後來在1976年的*In Re Quinlan*案中，紐澤西州最高法院判決以HEC為撤除維生設施的程序要件¹⁵⁴；而其後在1990年代，許多州法將設立HEC列為醫院受認證的要件¹⁵⁵。至今HEC的設立已經非常普及，除判斷病人的生理狀況以外，也在於進行倫理與社會面向的評估，並藉由其成員多元性與討論程序，處理臨床複雜的醫療倫理問題。

IRB和HEC的設立，不僅在落實受試者或病人保護，也在於形成對科學專業之監督，以及意識到受試、醫病這些私關係的社會面向（如醫療資源分配等）¹⁵⁶。倫理委員會藉由其審議的特質，為困難的倫理問題提供可行的決策模式。

另一類廣泛對於政策進行建議者，在美國最重要者為國家級的生命倫理委員會。1974年國會立法創設最初的委員會（即國家生醫

151 *Id.* at 25.

152 Thaddeus Mason Pope, *Multi-Institutional Healthcare Ethics Committees: The Procedurally Fair Internal Dispute Resolution Mechanism*, 31 CAMPBELL L. REV. 257, 260 (2009).

153 *Id.* at 261.

154 *In re Quinlan*, 70 N.J. 10, 355 A.2d 647, 669 (1976). 本案之討論，詳後「伍、二」所述。

155 Pope, *supra* note 152, at 264-65.

156 JONATHAN D. MORENO, *DECIDING TOGETHER: BIOETHICS AND MORAL CONSENSUS* 35-36 (1995).

與行為研究倫理委員會)，當時的委員經聯邦政府任命有11人，背景包括自然與社會科學、人文科學以及政府官員¹⁵⁷，而該委員會依授權作成的貝爾蒙特報告，也富有審議民主所強調的共識的色彩——成員們即便持有不同的道德觀，仍舊同意這些共通的原則，且同意這些原則的內容是開放的¹⁵⁸。其後的國家倫理委員會，也多以多元背景成員、追求共識之方式做出政策建議¹⁵⁹。國家生命倫理委員會這類倫理委員會的出現，也被視為反應「公共生命倫理」(public bioethics)的趨勢——生命倫理從主要討論專業自治或醫病等私領域關係，逐漸公共化，而由政府高度介入設立委員會進行討論¹⁶⁰。國家生命倫理委員被稱為是「公共生命倫理組織」(public bioethics bodies)，透過多元背景專家委員的組成，對於當下重要的生命倫理議題進行調查並提出政策建議¹⁶¹。公共生命倫理組織直接得到國會或者行政部門的授權，以及調查中踐行公開程序，常會獲得一定程度的公眾關注。不少論者認為：國家生命倫理委員會基於

157 National Research Act of 1974, Pub. L. No. 93-348, §§ 101-215, 201(b)(1) (1974).

158 MORENO, *supra* note 156, at 78. Moreno在該書中，也大力讚揚National Commission的審議精神，稱此委員會為「一個相對互相融合、合作的群體，以相互尊重的態度進行，但其成員又不至於無法提出其不同意見並為之辯護」，MORENO, *supra*, at 78.

159 關於歷代國家生命倫理委員會之簡述，詳參前註6。歷代國家生命倫理委員會大多採取共識決，唯一的例外是小布希任命的總統生命倫理委員會，該委員會採取的是多元主義的觀點，授權成立該委員會的行政命令裡面明文提到：委員會應該對於系爭議題所涉及的複雜及相衝突的道德觀點，盡力給予全面性的論述，而不必然以追求共識為唯一目標。因此此屆委員會不採取共識決，也是歷來唯一容許委員寫不同意見的委員會。但值得注意的是，此屆委員會的設立宗旨中也寫明此委員會是為提供「一個對於能夠進行全國生命倫理討論的論壇」，也是具有審議的特質。關於此屆委員會採取多元主義是否有助於民主審議的落實，可參見：Wenmay Rei & Jiunn-Rong Yeh, *Promises and Pitfalls of Using National Bioethics Commissions as an Institution to Facilitate Deliberative Democracy—Lessons from the Policy Making of Human Embryonic Stem Cell Research*, 4(2) NTU L. REV. 69, 86-88 (2009).

160 O. Carter Snead, *Science, Public Bioethics, and the Problem of Integration*, 43 U.C. DAVIS L. REV. 1529, 1532 n.4, 1535-38 (2010).

161 *Id.*

其審議的特徵，比其他機構更適於處理與科學有關道德議題¹⁶²。長期以來，國家生命倫理委員會對於重要的生命倫理議題進行政策建言，其具有成員多元、進行道德層次的討論、公開透明程序等特質，是為生命倫理中具有民主審議傳統之證據。

2. 過去國家生命倫理委員會報告中的民主審議元素

在歷來國家生命倫理委員會過去所做的報告中，亦常見到許多政策建議中，具有民主審議的精神。現任國家生命倫理委會以民主審議為獨立的原則，然而這樣的觀念並非無前例，而是承襲過去諸多前例之傳統。與現任國家生命倫理委員會相同，這些在歷來報告中的民主審議，亦可分為程序與實體兩面。

在程序面上，有不少報告將民主審議視為必要的決策程序或決策方法。由於歷來國家生命倫理委員會的任務，即在於促進生命倫理議題的公共討論，因此在報告常見倫理委員會以「審議」來描述自己的工作。若干報告提及作成報告過程有進行公眾諮詢，特別是諮詢以具有包容性的方式為之，例如以弱勢族群或者病友團體諮詢對象¹⁶³。亦有報告主張其論理上融入民主審議的精神，像是在幹細胞研究或者複製的議題中，面對這類議題高度的倫理爭議，委員會便援用審議民主理論原則，強調其報告中之建議是在分歧道德觀下尋求共識，且結論具有開放性，容許未來之再檢視¹⁶⁴。

¹⁶² E.g., Rei & Yeh, *supra* note 159, at 76; Alfred Moore, *Public Bioethics and Deliberative Democracy*, 58 POL. STUD. 715, 727-28 (2010).

¹⁶³ E.g., NAT'L COMM'N, PSYCHOSURGERY: REPORT AND RECOMMENDATIONS 59 (1977), <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559371/psychosurgery.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; PRESIDENT'S COMM'N FOR THE STUDY OF ETHICAL PROBLEMS IN MED. & BIOMED. & BEHAVIORAL RESEARCH [hereinafter PRESIDENT'S COMM'N], DECIDING TO FOREGO LIFE-SUSTAINING TREATMENT 54 (1983), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559344/deciding_to_forego_tx.pdf?sequence=1.

¹⁶⁴ National Bioethics Advisory Commission [hereinafter NBAC], ETHICAL ISSUES IN HUMAN STEM CELL RESEARCH: REPORT AND RECOMMENDATIONS VOLUME 1, at 51

在實體面上，過去報告所提出的政策建議中，亦可發現不少民主審議於各層面落實的蹤跡。有認為管制架構中，應該納入民主審議的元素，成立除了現行IRB或者HEC以外具有審議精神的治理組織，處理像是醫療資源分配¹⁶⁵或者監控人體胚胎相關試驗倫理性¹⁶⁶等爭議性事項。許多報告提到提升決策者的公共責任（public accountability），這也是審議民主理論的重要內容之一，具體落實於政策上而言，即是加強與人民之間的溝通，並且落實對於科學技術的監督管理¹⁶⁷；亦有報告提出透過公眾諮詢、社區參與等方式，以強化政府或研究者的責任¹⁶⁸。

再者，有些報告強調公民參與的層面，認為審議不僅是在倫理委員會中為之，更應該以民主之方式進行審議。除了前述認為公民參與有助於提升政府官員與研究者公共責任的理由以外，不少報告更進一步將公民參與，視為決策正當性的來源。例如在1981年一項關於死亡定義的報告中，當時的委員會認為，死亡的判定不能夠全數交由醫生或法官判斷，而必須以立法方式為之，原因是僅依賴醫

(1999), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559364/nbac_stemcell1.pdf?sequence=1&isAllowed=y（引用Gutmann and Dennis Thompson's之審議民主理論作為理論依據）；PRESIDENT'S COUNCIL, HUMAN CLONING AND HUMAN DIGNITY: AN ETHICAL INQUIRY, at xxxv-xxxvi, 207-09 (2002), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559368/pcbe_cloning_report.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

165 NBAC, *supra* note 164 at 74, 76.

166 NAT'L COMM'N, ETHICAL GUIDELINES FOR THE DELIVERY OF HEALTH SERVICES BY DHEW 94 (1978), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559347/ethical_guidelines_health_services_min.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

167 E.g., ADVISORY COMM. ON HUMAN RADIATION EXPERIMENTS, FINAL REPORT 17, 495 (1995), <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/achre/final/report.html>.

168 E.g., NBAC, RESEARCH INVOLVING HUMAN BIOLOGICAL MATERIALS: ETHICAL ISSUES AND POLICY GUIDANCE VOLUME I, at 7, 73 (1999), http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/past_commissions/nbac_biological1.pdf; NBAC, ETHICAL AND POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL RESEARCH: CLINICAL TRIALS IN DEVELOPING COUNTRIES VOLUME I, at 30 (2001), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559362/nbac_international.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

學要件無法回應社會期待，而個案的司法程序在觀點上也有侷限性，若能透過立法過程中的聽證程序，將使社會上不同的觀點能夠被考量¹⁶⁹。另有報告指出，在面對科學與技術的不確定性時，決策的正當性更有賴於公民參與，透過公民參與，能更為全面性的考量系爭科技所涉及的安全性、社會與倫理效應¹⁷⁰。亦有報告的政策建議提及，應提升公民對於特定科技及其倫理議題的瞭解，原因不僅在使公民能夠於其個人決定中落實自決，更在於強化公民參與決策的能力¹⁷¹。

綜上可知，其實民主審議並非由歐巴馬任命之總統生命倫理議題研究委員會所獨創，而是在過去國家生命倫理委員會的報告中即有跡可尋。雖此概念並未如同過去民主審議原則一般受到正視，或被體系性的適用於個別議題中，然而這些過去的軌跡，亦可證明民主審議在生命倫理領域中具有悠久傳統。

（二）普世性

Beauchamp與Childress認為，其所提出的生命倫理原則並不限於美國，而是全世界都接受的普世原則。而在美國以外的世界各

¹⁶⁹ PRESIDENT'S COMM'N, DEFINING DEATH 45, 49-50 (1981), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559345/defining_death.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹⁷⁰ E.g., PRESIDENT'S COMM'N, SECURING ACCESS TO HEALTH CARE 42 (1983), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559375/securing_access.pdf?sequence=1&isAllowed=y; PRESIDENT'S COMM'N, SPLICING LIFE: THE SOCIAL AND ETHICAL ISSUES OF GENETIC ENGINEERING WITH HUMAN BEINGS 14, 17, 19 (1982), <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559376/splicinglife.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁷¹ E.g., PRESIDENT'S COMM'N, SCREENING AND COUNSELING FOR GENETIC CONDITIONS: THE ETHICAL, SOCIAL, AND LEGAL IMPLICATIONS OF GENETIC SCREENING, COUNSELING, AND EDUCATION PROGRAMS 63, 65 (1983), <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559349/geneticscreening.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; NBAC, CLONING HUMAN BEINGS VOLUME 1: REPORT AND RECOMMENDATIONS, at v (1997), https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559358/nbac_cloning.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

國，確實也能找到許多民主審議落實於生命倫理的治理或決策上之案例，以下僅試舉兩個較為廣為人知之事證：國家生命倫理委員會於各國及國際層次的廣泛設置，以及各國決策中常見之公民審議。

1. 生命倫理委員會的廣泛設置

與美國國家生命倫理委員會類似的組織，在世界各國也頗為常見，根據世界衛生組織2006年的統計，世界上至少有89個國家級的生命倫理委員會¹⁷²。且由於屬於國家層級，可想見在其國家應具有相當的能見度與影響力。根據論者Susan Dodd與Colin Thompson一項對於世界上國家生命倫理委員會的研究，歸納出這類委員會的責任主要有三：刺激、貢獻公眾討論；依其專業特定須要交付公眾審議的重要議題；以及形成新的公共政策¹⁷³。這三項功能皆反應某些民主審議的精神。再者，國際組織中，也不乏為處理生命倫理議題所成立的委員會，例如聯合國教科文組織下的國際生命倫理委員會（International Committee of Bioethics of UNESCO）或者歐盟高峰會下之生命倫理委員會（Committee on Bioethics of the Council of Europe）。跨國層級的生命倫理委員會，本身即有審議的意涵：全球化社會中，單憑內國法往往不足以處理新興醫學或生命科學與技術所帶來的挑戰，而這些委員會透過整合不同領域的知識和不同倫理觀點，試圖創造一個國際上所能接受的最低倫理標準，同時也保留各國依其國情之政策形成空間¹⁷⁴。

2. 決策中常見之公民審議

又從各國內部的實踐觀之，亦可發現處理新興生命科學與技術之決策中，常可見到公民審議之活動。其中一常見型態為「微型公

172 Susan Dodds & Colin Thomson, *Bioethics and Democracy: Competing Roles of National Bioethics Organizations*, 20(6) BIOETHICS 326, 326 (2006).

173 *Id.* at 327.

174 Angela Aparisi Miralles, *The Globalization of Bioethics: The Task of International Commissions*, 37 GEO. J. INT'L L. 141, 147-49 (2005).

眾」(mini-publics)廣泛運用。所謂的「微型公眾」,是若干審議民主論者提出的一種制度設計,由具有人口組成代表性的公民小群體,對於複雜且有爭議政治議題進行審議,審議的結果能某程度反應廣大公眾若在經過瞭解、相互辯論之後的想法¹⁷⁵。相較於倫理委員會著重於不同領域專家的審議,微型公眾提供一個不同的觀點——公民參與審議。其中於決策上最為常見者,為「公民會議」(consensus conference)。

公民審議實踐的最為制度化、歷史悠久的是丹麥。丹麥科技部設有獨立委員會之科技委員會(Board of Technology),目的是在促進公眾對於科技的潛力、可能產生之效應,進行參與及辯論¹⁷⁶。科技委員會更認為良好的科技決策,除了各領域專家以外,必須納入一般公民之意見,原因是公民為「社會的專家」,且能夠進行無利害關係之中立判斷,且其參與更有助於決策之正當性¹⁷⁷。自1987年開始,科技委員會開始就具有爭議性的科技政策議題,進行公民會議:隨機選出25位公民,提供其瞭解相關事實的講習,並給予其專

¹⁷⁵ James S. Fishkin & Robert C. Luskin, *The Quest for Deliberative Democracy*, 9(1) GOOD SOC'Y 1, 3, 4 (1999). 提出「微型公眾」的審議民主論者認為,審議民主與大規模公民參與具有內在衝突:理想的審議須要小群體面對面討論,每位參與的公民須要對議題進行充分瞭解,並且能夠相互提出討論、提出並回應他人的意見,此為大規模公民參與所難以達成者。而微型公眾的設計,是在使具有代表性的公民小群體進行審議,企圖調和大規模公民參與和審議民主之間的衝突。「微型公眾」雖然不能直接讓所有公民參與,但審議民主論者認為,微型公眾的討論能夠刺激公共討論,並強化政府責信, Fishkin & Luskin, *supra*, at 4. 「微型公眾」依據設置的細節又有很多不同類型,除公民會議(consensus conference)以外,其他論者曾提出的模式包括:公民陪審團(Citizens Jury)、審議式民調(Deliberative Poll)、政策策劃公民小組(Planning Cell)、21世紀市集會議(21 Century Town Meeting)、加拿大2004年與2006年選舉制度改革曾實施的國民大會(Citizens' Assembly)等。

¹⁷⁶ Services, THE DANISH BOARD OF TECHNOLOGY, <http://www.tekno.dk/services/?lang=en> (last visited Aug. 24, 2018).

¹⁷⁷ Lars Kluver, *Biotechnology-Related Consensus Conference in Denmark*, in BIOTECHNOLOGY, PATENTS AND MORALITY 158, 160 (Sigrid Sterckx ed., 2d ed. 2000).

家及相互間辯論之機會，討論結果將公開發表¹⁷⁸。科技委員會同時扮演中介角色，將公民會議之討論結果融入政策中¹⁷⁹。

公民會議的模式在1990年代以後廣為其他國家所採用，主要是用於討論基因改造（Genetically Modified Organism）之議題¹⁸⁰。論者分析公民會議在基因改造上的廣泛運用，主要原因在於基改產品能夠在市場上販賣並取得消費者信賴，有必要直接引進公眾於決策過程中¹⁸¹。然而，參與基改議題討論所需的背景知識，實在高於一般公民的科學常識，故公民會議提供一個能夠使公民參與成為可能的機制，使決策不至於皆為科學專業所把持，而公民又能夠在參與的過程中有足夠的時間及資訊充實背景知識，以促成其有效參與，兼顧決策之品質¹⁸²。

在如同基改這類具有爭議之生命科學與技術的議題上，也可常見公民會議以外的公眾諮詢程序。例如英國政府在1999年決定發產基改產品之產業時，即考慮到公眾對於基改產品的疑慮，因此主管機關於2003年間即針對基改作物，進行全國性的公眾討論，題為「基改之國？公眾辯論」（“GM Nation? The Public Debate”），總計進行了為期6週、全國大小規模不一675場的公聽會¹⁸³。又如英國政府於籌備建置全國性人體生物資料庫UK Biobank，計畫要蒐集全國45

178 Carolyn M. Hendriks, *Consensus Conferences and Planning Cells*, in THE DELIBERATIVE DEMOCRACY HANDBOOK: STRATEGIES FOR EFFECTIVE CIVIC ENGAGEMENT IN THE 21ST CENTURY 80, 83-84 (John Gastil & Peter Levine eds., 2005).

179 *Id.* at 91.

180 Ulrike Felt et al., *Visions and Versions of Governing Biomedicine: Narratives on Power Structures, Decision-Making and Public Participation in the Field of Biomedical Technology in the Austrian Context*, 38(2) SOC. STUD. SCI. 233, 233, 237 (2008).

181 Gary E. Marchant & Andrew Askland, *GM Foods: Potential Public Consultation and Participation Mechanism*, 44(1) JURIMETRICS 99, 100 (2003).

182 *Id.*

183 *Id.* at 129. 其後英國政府認為全國性公聽會的參與者，多半是與議題相關的利害關係人，討論容易觀點偏頗，故後來又針對基改作物議題，實施另一波公眾討論，題為「窄而深」（“Narrow-but-Deep”），以微型公眾的方式，尋求立場中立的公民參與，進行對特定議題進行較深入的討論，*id.*

到69歲500,000名國民的檢體時，即意識到大型生物資料庫必然須要公眾的支持與參與計畫，故在2003年籌備階段，便舉行一系列的公眾諮詢，且將公眾諮詢的結果，作為制訂該資料庫倫理架構（Ethics and Governance Framework）之依據¹⁸⁴。在UK Biobank正式成立以後，組織架構中進行倫理監控的倫理委員會（Ethics and Governance Committee），負有積極促使利害關係人及全社會參與之任務，不僅每年須對於資料庫營運是否符合設倫理架構提出公開報告¹⁸⁵，於2005至2010年間，亦每年舉辦公聽會，其中包括互動式的問答時間，並且將公聽會內容公布於地方媒體和官方網站上¹⁸⁶。

由前述國際上實踐可知，民主審議於生命倫理議題上之應用，並非僅為美國特有，在國際上亦有不少案例可循。而在我國多次公民會議的實踐中，亦不乏關於生命倫理的議題，例如在2002-2008年間的公民會議中，就可見涵括全民健保給付與制度改革（2次）、代理孕母、產前篩檢與檢測、護理倫理規範、基因改造食品等多項生命倫理議題¹⁸⁷。我國經驗亦可佐證民主審議之普世性。

（三）重要性

在貝爾蒙特報告中，有提到這些原則在眾多具有普世性且深植於傳統文化的原則中被選出，是因為這些原則是與人體研究特別相關的（particularly relevant）¹⁸⁸。雖然貝爾蒙特報告中，並沒有進一步說明為何是選出這三原則，但本文欲從程序和實體的兩個面向，

184 *Ethics*, UK BIOBANK, <https://www.ukbiobank.ac.uk/ethics/> (last visited Apr. 20, 2016).

185 UK BIOBANK ETHICS AND GOVERNANCE COUNCIL, <http://www.egcukbiobank.org.uk/> (last visited Apr. 20, 2016).

186 MEDICAL RESEARCH COUNCIL AND WELLCOME TRUST REVIEW OF THE UK BIOBANK ETHICS AND GOVERNANCE COUNCIL 8 (2010), <https://egcukbiobank.org.uk/sites/default/files/meetings/Review%20report.pdf>.

187 2002-2008年間於我國實踐公民會議的列表，可見於：黃東益，審議過後——從行政部門觀點探討公民會議的政策連結，東吳政治學報，26卷4期，頁87-89（2008年）。

188 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

來說明民主審議在生命倫理的原則主義架構中具有重要性，能夠補足現行各原則所未涵蓋之面向。在程序面，其他各原則的具體內容如何形成，有賴於民主審議之解釋方法，解釋方法或程序在原則主義架構中至為重要，足以使民主審議提升為一主要原則。在實體面，原則主義架構仍以個人自由主義為基礎，民主審議可以補足現行架構所欠缺的如社群、德行、照護、人際關係等觀點。

1. 程序面向：民主審議作為方法論的指引

如前「貳、二、(二)、2」所述，原則主義雖對於各原則的解釋適用提出方法，仍面臨原則過於抽象的質疑，但Beauchamp與Childress認為這並非缺陷，而是為維持各原則受到廣泛接受之必要，他們認為應訴諸各原則的解釋適用及衝突權衡，並且進行道德上的證成¹⁸⁹。由此可見，方法論——即如何解釋適用、衝突權衡、證成這些原則，實應為生命倫理原則的核心問題，重要性不下於各倫理原則的內涵¹⁹⁰，但卻並未受到足夠重視。

若探究「生醫倫理原則」一書，可發現民主審議其實是該書關於原則主義所提各種方法論的核心精神。證成所採取的「反思均衡」，用語正援引自Rawls理論中進行道德審議的方法，書中許多關於證成的描述，也都隱含民主審議的精神。例如：證成必須附充足的理由（互惠性）¹⁹¹；反思均衡是一個無止盡的程序，因為即便已經達到了判斷與原則的一致性，仍舊可能有所不足，必須留予繼續檢視修正之空間（暫時性）等¹⁹²。又在其他方法論的描述中，也可見民主審議的精神：如解釋適用必須要有「基於審議程序所為之論

189 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 395.

190 也有生命倫理學家意識到解釋適用、衝突權衡等的重要性，認為這些方法論才是使得原則主義的內涵能夠不斷演進的關鍵，進而主張應該把「解釋適用」、「衝突權衡」也提升為生命倫理原則，足見方法論的重要性。See Holm, *supra* note 54, at 336.

191 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 390.

192 *Id.* at 460.

理」¹⁹³；衝突權衡時則必須要先考量「是否有好的理由為依據，以說明為何要凌駕於其他原則」¹⁹⁴。

又，即便是各生命倫理原則的內涵，也可處處見到Beauchamp與Childress認為須要透過民主審議的方法，來形成各原則的具體內涵。例如提及自主原則更精確的標準其實未定，必須透過解釋適用來加以形成¹⁹⁵，而解釋適用又有賴民主審議程序。在不傷害原則下，兩位作者提及由倫理委員的公開討論，能夠促使不同意見化解歧見、做出有理由可支持的選擇¹⁹⁶。正義原則的討論則是最常提及民主審議的，兩位作者在討論諸多分配正義的議題——像是何謂醫療照護的最低標準¹⁹⁷、在對健康有利之措施中何者應優先¹⁹⁸、器官捐贈如何進行最公平的分配¹⁹⁹等——之際，皆認為公平的公眾審議是不可或缺的。

以上線索皆可證明，各生命倫理原則有賴進一步具體形成，具體形成的方法論至為重要，而民主審議的精神，其實已經存在於原則主義的方法論中，但卻未受到重視。根據原則主義分析架構所為之判斷，及該判斷作成所須進行的解釋適用、衝突權衡、證成，若皆須落實民主審議之精神，則民主審議不啻為該架構的核心，足以與現行各生命倫理原則相提並論。正如生命倫理學家Jonathan Moreno認為：生命倫理原則看似是道德共識，但內容抽象，能提供的道德權威有限，各倫理委員的道德權威，其實部分來自於委員會共識形成的過程²⁰⁰。Moreno並認為在一個自由及多元價值的社會

193 *Id.* at 19.

194 *Id.* at 23.

195 *Id.* at 140.

196 *Id.* at 192.

197 *Id.* at 273.

198 *Id.* at 283.

199 *Id.* at 287.

200 MORENO, *supra* note 156, at 10.

中，透過開放、知情等具備審議特質的程序來形成共識，是較為理想的²⁰¹。民主審議作為生命倫理原則，能夠補足現行原則主義架構在程序面缺乏指引的不足。

2. 實體面向：民主審議補充現行架構之侷限

民主審議作為一新原則也有實體面的意義：提供現行原則主義架構所欠缺的觀點。原則主義預設的是個人自由主義的觀點，不論是在貝爾蒙特報告或者Common Rule中，群體的觀點都相對薄弱。

Ezekiel J. Emanuel與Charles Weijer曾提出以「尊重社群」為新原則，以應對特定族群所為之研究數量日益增加，以及研究所發生的風險逐漸無法僅透過個人損益的觀點加以評估的問題²⁰²。根據氏之看法，針對特定族群之研究所涉倫理議題，是現有各原則所無法處理的：尊重自主、為善及不傷害原則，並不處理個人與其所屬社群之間的衝突；而正義原則雖然保護易受傷害族群，但易受傷害族群和社群往往是不一樣的概念²⁰³。「尊重社群」原則承認社群具有獨立的道德地位，並且給予社群表示意見甚至准否的權利²⁰⁴。雖然本文同意Emanuel與Weijer指摘現行原則主義架構缺乏群體觀點，但認為相較於「尊重社群」，民主審議所涵蓋的面向更廣，作為一個倫理原則也更適格。根據前述「參、二」及「參、三、（一）、2」對於美國國家生命倫理委員會報告的回顧，可見民主審議原則的內涵相當豐富，其中除與「尊重社群」相當的社區參與以外，更包括加強治理機制中的審議組織與程序、強化政府與研究者的公共責

201 *Id.* at 130.

202 Ezekiel J. Emanuel & Charles Weijer, *Protecting Communities in Research: From a New Principle to Rational Protections*, in BELMONT REVISITED: ETHICAL PRINCIPLES FOR RESEARCH WITH HUMAN SUBJECTS 165, 165 (James F. Childress et al. eds., 2005).

203 *Id.* at 166-67.

204 *Id.* at 167-70.

信、公民參與、促進公眾對系爭議題的瞭解等面向，此皆有助於強化群體面向的觀點，以及解決個人與群體間之衝突。

民主審議也有助於回應其他倫理觀點對原則主義的批評²⁰⁵，將那些個人自由主義所忽略的德行、照護、人際關係等觀點納入考量。透過民主審議原則之指引，決策者負有提出各方皆可接受的理由的義務，因此決策過程必須具有包容性，審酌除了權利義務、風險及利益衡量以外的觀點。

再者，民主審議本身的優勢，在處理生命倫理領域的問題時具有優勢。民主審議本身是處理道德歧見的政治哲學，另外民主審議有著於風險溝通、風險管理，正有助於解決生命倫理領域中所面臨的道德歧見、科技的風險不確定性。

又雖然現有各原則，與民主審議內容有所重疊之處，如自主是民主的核心價值；不傷害原則對於民主審議的範疇有所限制，而民主審議則為不傷害原則提供保護；為善與正義則是民主審議所追求的目標。然而，沒有一個現有原則能夠完全包括民主審議之內容。且觀現有的各生命倫理原則，彼此間也有相互交疊之處，但並無礙於每個原則之獨立存在。

肆、民主審議「倫理原則化」的必要性：以規範意涵為中心

一、「倫理原則化」的幾個理由

綜上所述，總統生命倫理議題研究委員會的突破之處，或許在於將民主審議「倫理原則化」，即試圖將民主審議的地位，提升為

²⁰⁵ 詳「貳、二、(二)、2.」所述。

決策時必須審酌之項目，而非僅是決策者可自行選擇的加乘項目。然而若如前所述，民主審議的精神實已隱含於各倫理委員會的設置中；再者，在理論或政策上，其實亦不乏其他科學與技術民主化之主張，且民主審議也廣被當代政治哲學視為好的政策制定方式，自然也包括醫學與生命科學的政策，究竟將民主審議提升為一項倫理原則，其必要性及實益何在？

本文認為，此問題或可從幾個面向來回答：其一，民主審議能夠補足現行架構的不足，不僅作為各原則解釋適用的指引，也能補足現行架構立基於個人主義的缺陷，亦能關注群體、人際關係，以及個體間的差異，詳如前「參、三、(三)重要性」所述。

其二，生命倫理領域至今仍有民主參與不足的問題，提升民主審議為一項倫理原則，能夠回應此問題。縱然各種倫理委員會的設置，背後確有民主審議的傳統，但論者也不約而同提及，各倫理委員會本身有強化民主參與的必要，僅憑各倫理委員會本身的多元組成，並不足以實現民主審議。例如，生命倫理學家、過去曾任小布希任命之總統生命倫理委員會（President's Council on Bioethics）委員的Rebecca Dresser便指出，國家生命倫理委員將來的主要努力方向之一，在於促進生命倫理領域的更大規模、有效的參與。氏認為，國家倫理委員會雖然已有倫理學家，但應進一步讓具有不同政治、倫理觀點者參與，尤其是應該包括有特殊個人經驗者（例如受試者、病友及其家人，Dresser稱之為「經驗專家」），並且創造這些觀點適合發聲的機制，因為這些外部觀點將會為生命倫理帶來活力²⁰⁶。Dresser也認為，既有的會議應公開、公告並給予表示意見機會等程序，尚不足以促進有效的公眾參與，將來的生命倫理委員會

206 Rebecca Dresser, *Inclusion, Access, and Civility in Public Bioethics*, 47(S1) HASTINGS CTR. REP. S46, S48 (2017).

應該將有效公眾參與作為首要任務²⁰⁷。也有論者援引民主審議原則，認為目前IRB仍然有民主參與不足的問題，例如未能給予受試者任何代表或參與倫理審查的機會，故應該更強化受試者參與的機制²⁰⁸。甚而，也有論者提及在目前全球民粹（populism）政治陸續出現的情況下，生命倫理領域應該作出因應，落實民主審議與公民教育，將生命倫理議題引進公共論壇、進行更廣泛的公眾討論，避免讓生命倫理僅限於學術或專家討論²⁰⁹。是以，雖民主審議的傳統隱含於生命倫理領域的治理架構中，但即便時至今日，生命倫理學家們仍認為此領域有民主化不足的問題，甚至認為落實民主審議是今後生命倫理領域應致力的目標，故將民主審議提升為倫理原則，正反應此共識。

其三，則是生命倫理原則在個案決策中的優勢地位。生命倫理作為臨床與研究的專業倫理指引，協助醫事人員或研究者特定倫理議題，提供系統性的分析架構，以及引導其做出符合倫理的決定²¹⁰。雖然各決策並非必然皆訴諸生命倫理原則，但生命倫理原則確實是決策重要的參考依據。Beauchamp與Childress認為生命倫理原則，得以作為政策形成和政策評估的道德依據（moral grounds）²¹¹。社會學家John H. Evans也指出生命倫理原則與治理（governance）有緊密的關聯性，倫理原則的操作模式與西方公共政策的邏輯相符，提供共量（commensuration）的分析架構，透過幾項基礎性原則的提出與操作，來轉譯、精簡化繁複的意見與資訊，不但使得決

207 *Id.* at S48.

208 Govind Persad, *Democratic Deliberation and the Ethical Review of Human Subjects Research*, in *HUMAN SUBJECTS RESEARCH REGULATION: PERSPECTIVES ON THE FUTURE* 157, 157-59 (I. Glenn Cohen & Holly Fernandez Lynch eds., 2014).

209 Mildred Z. Solomon & Bruce Jennings, *Bioethics and Populism: How Should Our Field Respond?*, 47(2) *HASTINGS CTR. REP.* 11, 13 (2017).

210 Daniel Callahan, *Bioethics as a Discipline*, in *BIOETHICS: AN INTRODUCTION TO THE HISTORY, METHODS, AND PRACTICE* 17, 18 (Nancy S. Jecker et al. eds., 2d ed. 2007).

211 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 9.

策的過程得以簡化，也較容易形成共識²¹²，故在治理上具有相當影響力。生命倫理原則對於決策具有指引作用，故相較於僅視民主審議為理想的決策模式，倫理原則化使得民主審議的重要性更為明確，也更有助於其在決策中的落實。

其四，本文認為倫理原則化的實益，在於倫理原則化所創造的規範意涵（legal implication）。民主審議是憲法所肯認的價值，且基於正當法律程序的要求，國家於生命倫理決策中，實有落實民主審議之法定義務。但另一方面，生命倫理原則與管制有許多交互影響之處，如Evans所述，生命倫理原則與治理關係緊密，除了生命倫理原則本身提供一套有助於決策的架構以外，Evans也發現生命倫理原則的盛行，與國家積極介入倫理有關：在重大人體研究弊案爆發以後，公眾期待國家積極對研究倫理進行管制，同時由於官僚體制的擴張、廣設倫理委員會，迫使決策者亟須尋求客觀、透明以及標準化的方式，來向公眾證明政府所支持或容許的生醫研究是合倫理的²¹³。生命倫理原則除作為專業倫理，也被法律化、深入各管制架構中，可見透過倫理原則化，提供了憲法上民主審議價值如何落實的管道，使民主審議在決策、法律解釋上皆更確實被審酌。以下將詳述之。

二、透過「倫理原則化」取得規範效力

（一）民主審議之憲法依據

民主審議向來不僅是一種政治哲學理論，更有規範上的基礎。相較於過去許多科技民主化的主張，民主審議的規範依據來自於憲法，而各領域的決策皆應實現憲法價值，故生命倫理領域有將此原則加以落實之必要。

212 John Evans, *A Sociological Account of the Growth of Principlism*, 30(5) HASTINGS CTR. REP. 31, 34 (2000).

213 *Id.* at 34-35.

自美國憲法的歷史與條文中，可以發現許多審議民主的概念。例如James Madison在Federalist No. 10裡面提到，為免於政治受到來自黨派（faction）出於私利、激情、侵害他人權利之威脅，應授權一群被選出來的公民，站在達成真正國家利益的角度，重新釐清公眾的觀點²¹⁴。Madison在與反聯邦論者之辯論中，也提及理想的政治體制，應是在異質性（heterogeneous）公民組成的大共和中進行審議，才能較精確反應人民的意見²¹⁵。而在憲法本文中，選舉人團的設置也反應此種審議的觀點，原本設定的任務是在一個獨立、有責、組成具有異質性的團體中進行審議，以選出總統²¹⁶。憲法學者Cass R. Sunstein更視審議民主是美國憲法的精神之一，並且賦予審議民主規範上之地位，於憲法解釋時加以落實。Sunstein曾明確指出「美國憲法意在成立一個審議民主的政體」²¹⁷，故最高法院解釋憲法時，也應該遵從此精神。氏亦認為憲法的一項任務，在於解決廣泛、長期的歧見²¹⁸，而審議民主能夠提供解決方法，在異質性團體進行審議，有助於解決族群極化（group polarization）的問題²¹⁹；或是運用「不完全理論化合意」（incompletely theorized agreements），即透過人民僅同意措施或結果，而保持對於基本性問題的歧見或不確定意見的方式，來解決歧見²²⁰。

又或是在我國法上，審議民主亦有其憲法依據。明文提及者，如司法院釋字第613號解釋許玉秀大法官部分協同意見書中，指出

214 THE FEDERALIST No. 10 (James Madison), http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed10.asp.

215 *Id.* See also JAMES S. FISHKIN, WHEN THE PEOPLE SPEAK: DELIBERATIVE DEMOCRACY AND PUBLIC CONSULTATION 15-16 (2009).

216 CASS R. SUNSTEIN, DESIGNING DEMOCRACY: WHAT CONSTITUTIONS DO 38-39 (2001).

217 CASS R. SUNSTEIN, THE PARTIAL CONSTITUTION 19-20 (1993).

218 SUNSTEIN, *supra* note 216, at 8.

219 *Id.* at 15; Cass R. Sunstein, *The Law of Group Polarization*, in DEBATING DELIBERATIVE DEMOCRACY 80, 82 (James S. Fishkin & Peter Laslett eds., 2003).

220 SUNSTEIN, *supra* note 216, at 8-9.

基於審議式民主的概念，獨立機關的正當性，除了代議立法授權以外，更來自於獨立機關賦予公民直接參與的管道；司法院釋字第691號李震山大法官部分協同意見書中也明文以思辯式民主（deliberative democracy，僅翻譯不同）為依據，作為其判斷二元訴訟制合憲性之依據。又如司法院釋字第314號解釋表示修憲機關應該「讓國民預知修憲目的並有表達意見的機會」，亦認為修憲程序應以實現民主審議為要件²²¹。大法官解釋過去對於正當法律程序之演繹，實亦含有審議民主之內涵。對於代議政治的運作，大法官解釋意旨有基於正當法律程序，而進一步導出應該落實審議民主者，如司法院釋字第499號宣告國民大會自行修憲延任違憲，理由之一為系爭修憲以不公開記名投票為之，違反公開透明原則、牴觸正當修憲程序而違憲，而該號解釋理由書提到，公開透明原則旨在實現理性溝通、落實責任政治，實為審議民主之概念；又如司法院釋字第520號解釋審查行政機關停止執行核四預算之合憲性，該號解釋從正當法律程序的觀點出發解釋憲法增修條文第3條，而建構了行政權與立法權間之政治協商義務，亦是在認為權力分立之運作應落實審議的結論。再者，縱使正當法律程序是出現於涉及人民權利保障之脈絡下，大法官也多次提及正當法律程序應該包括給人民參與之機會²²²，以節制國家權力濫用，並透過求取與人民間之共識來強化決策正當性²²³，亦可證實正當法律程序之內涵，亦有包含民

221 張文貞，公民複決修憲在當代憲政主義上的意涵，臺灣民主季刊，3卷2期，頁110（2006年）。

222 如司法院釋字第610號解釋許玉秀等三位大法官部分協同意見理由書提到：「正當法律程序原則的原始意涵是，關涉人民權利的公權力運作，應該設置合理正當的法定程序，俾保障人民有合理、公平參與及異議的權利」；又或如司法院釋字第709號解釋理由書關於都市更新計畫之正當法律程序，亦包括「促使人民積極參與，建立共識，以提高其接受度」之機制，並認為都市更新條例除「主管機關應設置公平、專業及多元之適當組織以行審議」以外，亦應給予人民程序參與的機會，如表示意見的機會等等，皆可見正當法律程序強調人民參與之內涵，含有審議民主之精神（本註釋中之粗體字，均為本文所加）。

223 如論者葉俊榮提及：隨管制事務日趨複雜，管制必須求助於社會部門的協

主審議之意旨，得作為民主審議憲法上之依據。

若再進一步將範圍限縮為科技決策的民主化，則應探查我國憲法中基本國策之相關規定。基本國策中宣告國家應該獎勵科學技術之發展（第166條、增修條文第10條第1項）、保障科學家之生活（第165條），並運用科學技術應於天然資源開發（第146條），然而基本國策也提及應尊重民族意願並保障其政治參與（增修條文第10條第12項），若採體系解釋，可認為以特定族群為研究對象時，應尊重其意願並保障其政治參與。可見即便是科學與技術之民主化，亦不乏憲法上之依據。

再者，若從生命倫理議題中，經常涉及人民基本權利的變更，以及考量生命科學與技術所涉之風險不確定性，基於正當法律程序，亦有將民主審議納入規範體系，使其成為法定要件之必要。Susan Wolf就曾主張，HEC的組織跟程序都應該依據正當法律程序來進行改革²²⁴。氏認為在HEC應該符合正當法律程序，不僅是基於倫理，而是有法律面的依據，原因是HEC所為之醫療決定涉及人民之生命、身體、自由等基本性權利，且HEC的決定對於法院、醫事人員及病患皆有一定的影響力²²⁵。一個能夠作出影響病人基本權利之組織，若是未能遵守正當法律程序，病人之權利將難以受保障²²⁶。同樣的，考量到生命倫理之決策，往往涉及人民基本性權利，甚至會牽涉到生命定義的改變，進而影響憲法之權利主體如何定義，自應以符合正當法律程序之方式為之。民主審議原則的加入，正是補足現行生命倫理決策中對於正當法律程序要求的不足。

助，因此行政程序從節制國家權力之政府與人民對立，觀轉為強調政府與人民之雙向互動，強調人民的共識與參與，參見：葉俊榮，面對行政程序法，2版，頁270-271（2010年）。

224 Susan M. Wolf, *Ethics Committees and Due Process: Nesting Rights in a Community of Caring*, 50 MD. L. REV. 798, 803 (1991).

225 *Id.* at 835.

226 *Id.* at 836-37.

綜上，民主審議是為憲法所肯認之民主原則、正當法律程序原則之一部分，具有憲法層次之依據，政府與下級規範負有落實憲法之義務。然而，如何在法律及決策層面落實民主審議，實為重要的問題，本文認為將民主審議提升為倫理原則，能夠提供一落實的管道。

（二）生命倫理原則的規範效力

生命倫理在本質上即與法律有緊密的關連，這也是民主審議成為一項生命倫理原則的實益，因生命倫理原則能夠影響法律之解釋適用，甚或進一步被法律化，而有別於其他科技民主化的主張。在許多生命倫理議題上，常可以見到倫理與法律的緊密結合與交錯，例如在安寧緩和的案件中，美國法院判決也採取原則主義的分析方式，進行尊重自主原則與為善原則之間的權衡²²⁷。人體研究相關規範也高度受到原則主義的影響，是為更顯著的例子，美國最重要的人體研究聯邦法規Common Rule中，可見到貝爾蒙特報告的倫理架構²²⁸。如Common Rule中規定IRB審查研究通過與否所應審酌的事項——告知同意、風險利益評估、受試者選擇²²⁹，正是貝爾蒙特報告所揭示之將生命倫理原則付諸具體落實的各項規則（rules）²³⁰。

生命倫理與法律之交錯，也可見於許多生命倫理委員會的地位被法律化，而不再僅是倫理組織。例如IRB作為研究倫理治理的組織，其任務兼具倫理與法律層面²³¹，IRB的設置是源自專業自治的概念，由各機構組成倫理委員會依專業倫理及在地情形為倫理之判斷，然而在Common Rule則將此倫理審查法律化，通過IRB審查成為某些研究實施的法定要件，IRB也負有審查系爭研究之合法性，

227 BARRY FURROW ET AL. ED., *BIOETHICS: HEALTH CARE LAW AND ETHICS* 20, 257 (6th ed. 2008).（分析在*Cruzan v. Dir., Mo. Dep't of Health*一案中，法院的論理中進行自主和為善兩者間的權衡，似受到原則主義的影響。）

228 *Id.* at 20.

229 28 C.F.R. § 46.111.

230 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

231 FURROW ET AL. ED., *supra* note 227, at 20.

以及事後追蹤查核等法定義務。又如HEC在紐澤西州最高法院 *Quinlan* 案判決²³²，認為系爭安寧緩和決定之前提事實須經HEC判定，以及之後各州法將HEC設置作為醫院認證要件以後²³³，HEC便不僅是專業倫理諮詢組織，而被賦予法定地位。

許多論者也認為，生命倫理領域之所以能夠興起，與原則主義架構與管制的需求相符合有關。生命倫理學家Robert Baker形容IRB跟其他的倫理委員會是散佈於各機關的「衛星管制者」(satellite regulator)，這些倫理委員會以專業自治的方式來執行國家規範²³⁴。前述John Evans提到原則主義的盛行，在於提供簡易明瞭且具有預測可能性的架構，在管制上具有可行性及可預測性，故廣被為採用²³⁵。這些解讀，也都可證實生命倫理與法律之間的密切結合。

由於生命倫理與法律的結合，生命倫理原則常具有法律層次之效力。生命倫理原則已被法律化，如前述Common Rule含有原則主義架構，或者如我國人體研究法第2條之規定²³⁶，亦是將主要生命倫理原則納入法條之中，法院判決之論理受到原則主義的影響。再者，透過IRB、HEC等具有法律地位的倫理委員會，對於各原則具體適用於個案，也使生命倫理原則被間接法律化。是以，民主審議被列為一項生命倫理原則，顯然不只是作為專業倫理、理想決策之一環，也因此取得法效性，而對於各決策者產生拘束力。

我國法院過去在生命倫理相關的議題上，亦不乏援用生命倫理原則為基礎之判決，足見生命倫理原則不僅作為專業倫理之一部，

232 *In re Quinlan*, 70 N.J. 10, 355 A.2d 647, 669 (1976). 本案討論詳「伍、二」所述。

233 Pope, *supra* note 152, at 264-65.

234 ROBERT BAKER, BEFORE BIOETHICS: A HISTORY OF AMERICAN MEDICAL ETHICS FROM THE COLONIAL PERIOD TO THE BIOETHICS REVOLUTION 280 (2013).

235 Evans, *supra* note 212, at 34-35.

236 人體研究法第2條：「人體研究應尊重研究對象之自主權，確保研究進行之風險與利益相平衡，對研究對象侵害最小，並兼顧研究負擔與成果之公平分配，以保障研究對象之權益。」

更進一步具有規範效力，並為法院判決所援引。例如臺灣高等法院100年度上易字第2197號刑事判決²³⁷中，對於整形醫師非法販賣衛福部所禁止之矽膠義乳並施以整形，針對被告抗辯病人瞭解風險並同意使用，法院援引生命倫理四原則加以駁斥，指出「縱使被告尊重需求者自主，但仍違反不傷害、行善、正義之三原則」，故仍具有可罰違法性。又如在臺灣臺北地方法院104年度聲判字第5號刑事裁定中，法院也援引尊重自主原則、行善原則（即為善原則），以說明被告醫生告知義務之範圍與時點。甚者，法院透過援引生命倫理原則來佐證法定義務的正當性，例如在臺灣臺北地方法院101年度聲判字第165號刑事裁定中，法院不僅援引過去最高法院判決揭示醫師違反說明義務且無正當理由，即難謂已盡注意義務，更特別指出此原則與生命倫理的尊重自主原則相符，來強化前述最高法院判決所揭示之原則²³⁸。由這些判決之推論可知，生命倫理具有規範效力，並且影響法律的解釋適用。

（三）民主審議透過「倫理原則化」落實於規範中

民主審議為憲法所認可的價值，但如何將抽象的憲法價值落實於管制與決策中，實為難解的議題。有鑑於生命倫理法律化的程度，不論是融入規範，或是影響法律解釋、作為各管制機關決策的指引，本文認為將民主審議倫理原則化，有助於民主審議透過規範在生命倫理領域加以落實，而非僅是解釋適用各倫理原則的方法，或僅是一種理想的決策過程。

237 另在本案的下級法院判決臺灣臺北地方法院99年度易字第1658號刑事判決中，亦採同樣見解。

238 該判決以：「換言之，在一般情形下，如說明後，病人有拒絕醫療之可能時，醫師即有說明之義務；於此，醫師若未盡上開說明之義務，除有正當理由外，難謂已盡注意之義務。此為最高法院九十四年度臺上字第二六七六號刑事判決所昭示。此一論述，契合生命倫理四原則中，尊重自主（respect for autonomy）之最高指導原則。」

科技決策民主化的理念實不乏倡議者，且向來有不少制度設計的努力，但皆有兩個重要的問題須面對：一是何時發動民主參與程序，一是民主參與的結果如何轉化為決策。例如參與式科技評估（participatory technology assessment, pTA）認為在面對科技的不確定性與不可預測性時，出於管制之須要，而對科技進行科學面與社會面的效應評估，而良好的科技評估應廣納公眾觀點²³⁹。相較於一般公民參與決策的運動，pTA將公民參與和管制進行更強的連結，提供評估複雜風險以及取得公眾信賴的管道，具體案例如前述1990年代開始全球各地針對基因改造物所舉行的公民會議。然而，對於pTA的常見質疑，一在於pTA的發動與進行，是否能確實以中立的態度引進公民，或淪為以偏頗、傾向為政策背書之方向設計；一則在於pTA的結果是否能被轉化為政策，或者其實無法對決策造成影響²⁴⁰。相較之下，若能將民主參與制度化，則可避免流於決策者的恣意。

綜前所述，生命倫理原則不僅是專業倫理，也廣泛為作為IRB、HEC這類治理機構的指引，以及法院判決時所適用，且亦有被實定法化的狀況。是以，民主審議若被視為一項生命倫理原則，則可因此促使民主審議融入規範，進而促使民主審議成為法定義務，而非僅是好的決策模式。透過生命倫理原則的規範效力，使得民主審議能透過規範加以落實，並且具有以下優勢：其一，雖然民主審議是憲法所肯認的價值，各領域的公共政策也皆有遵循憲法之義務，然而憲法的價值仍有待下位規範的具體落實。而生命倫理原則的架構，能夠提供民主審議於生命倫理決策中落實的有效管道，使得民主審議並非僅是決策者可選擇的理想決策方式，而是具有進行民主審議的法定義務。其二，落實民主審議的方式多元，相較於

239 Albert Lin, *Technology Assessment 2.0: Revamping Our Approach to Emerging Technologies*, 76 BROOK. L. REV. 1309, 1309 (2011).

240 *Id.* at 1331.

在法律中明定特定參與程序，透過生命倫理原則架構，能夠留予決策者裁量採用哪一種程序，但落實民主審議的義務仍相當明確²⁴¹。

三、問題及回應

若將民主審議提升為一項生命倫理原則，必然有許多方法上及實踐上的疑慮，本小節在回應可能的疑慮²⁴²。

（一）方法論的疑問

1. 民主審議是否限於公共政策，或者亦得適用於臨床決定上²⁴³？

民主審議作為一生命倫理原則，是否僅限於公共決策上？本文認為，民主審議原則不僅適用於政府關於生命倫理政策的公共決策上，亦應廣泛適用於政府以外之其他領域的生命倫理決策中，像是

241 一個相近科技民主化融入法律的例子，或許可見於食品安全、環境領域中可見的預警原則（precautionary principle），其內涵包括在涉及科技之不確定性時，應將公民納入決策過程、進行風險溝通，參見：U.N. Conference on Environment and Development, Rio Declaration on Environment and Development, Principle 15, U.N. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), annex I (Aug. 12, 1992), http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF。預警原則已被法律化，例如歐盟規範GMO於環境中刻意流通之指令（Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the Deliberate Release into the Environment of Genetically Modified Organisms and Repealing Council Directive 90/220/EEC, 2001 O.J. L 106）前言第8項、第4條皆有明文，形同透過預警原則，間接使實行公民參與決策及風險溝通成為會員國之義務。

242 感謝兩位匿名審查人、出版委員會對本文主張在方法論上、在實踐上的質疑，本文在此章節試圖逐一回應。

243 審查人一項質疑提到：歷來國家生命倫理委員會與民主審議相關的報告，並未有適用於醫師臨床決策指引者，則是否表示民主審議僅適用於公共政策，而不適用於臨床決定？本文認為此項觀察，其實是因歷來國家生命倫理委員會所賦予之職責，在對於公共政策進行建議，故歷屆各委員會報告所探討的議題自然也是公共政策，但這必不表示民主審議並不適用於臨床決定。而現行各生命倫理原則在貝爾蒙特報告中，也是認為各原則適用於「人體研究」，而是論者Beauchamp與Childress之見解，才使得各原則廣泛適用於所有生命倫理議題上，參見前述「貳、二」。

協助臨床醫療決策的HEC，乃醫師的臨床判斷，以及病人或病人家屬的個人決策。

首先，審議民主論者即認為，審議的場域並不限於在政府的公共決策，而是應該深入市民社會（civil society）中，像是政治與市民結社、公司、工會等，甚至家庭與朋友之間，皆是審議的場域²⁴⁴。市民社會中的審議有助於代議政治的決策，能夠培養公民德性²⁴⁵，並且在自由且較遠離選舉、利益團體的干擾，能夠形成外於政府的力量，迫使政府必須為體制內的缺失做出回應²⁴⁶。然而，審議於市民社會中亦具有獨立的功能，審議能夠解決社群內的紛爭，也能夠改變社群內部的權力結構，像是女性主義運動改變了公民日常生活中性別的關係，或者是環保運動改變人們對於污染的概念、消費的習慣²⁴⁷。但審議民主論者也同意並非任何市民社會內之任何事項皆須審議，而究竟何為審議的標的？論者Jane Mansbridge認為，審議應該用於涉及集體的決定，這些集體決定應該訴諸集體討論，但不一定須要政府介入²⁴⁸；但Mansbridge也特別指出，實則任何個人的決定，都會某程度影響到其所屬的群體，氏並且引用女性主義「個人即政治」（the personal is political）的觀察，認為許多女性的生活經驗看似個人事項，但實則這些經驗具有政治意涵，應該訴諸集體討論²⁴⁹。又如Gutmann與Thompson認為，只要是具有群體拘束力的決定，則應該作為審議的標的，使得該決定能夠提出正當化的理由²⁵⁰；Gutmann與Thompson也特別提及，若是公民的基本自

244 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 32; Jane Mansbridge, *Everyday Talk in the Deliberative System*, in DELIBERATIVE POLITICS: ESSAYS ON DEMOCRACY AND DISAGREEMENT 211, 213 (Stephen Macedo ed., 1999).

245 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 359.

246 JOHN S. DRYZEK, DELIBERATIVE DEMOCRACY AND BEYOND 101-02 (2000).

247 *Id.* at 102-03.

248 Mansbridge, *supra* note 244, at 215.

249 *Id.* at 215-16.

250 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 319.

由與基本機會因為特定制度而受到影響，則公民應該有相應的論壇以辯論相關議題，例如大型公司的決定足以影響公民的基本自由與基本機會，因此贊同公司治理上需要審議²⁵¹。

生命倫理的決策涉及個人的基本自由與基本機會，故依照Gutmann與Thompson之見解，應使受影響者有參與審議、使得決策必須歷經證成的過程。再者，在生命倫理領域中，許多看似個人決定的議題，像是*Quinlan*案中是否撤除維生醫療設施，也是具有相當的政治性，涉及到社會對人性尊嚴的認知，以及對生命的評價。而在臨終醫療決定中常見的「滑坡效應」考量，亦彰顯這些個人決定背後的政治性²⁵²。生命倫理領域的決策——不論是政府的公共政策，或是市民社會中的決策，乃至於個人的醫療決定，不僅涉及涉及家屬、醫療服務提供者及照顧者的權益，以及有限的醫療、社福或研究資源的分配，亦涉及對生命的尊重與評價，故不免有影響他人的效力。現有的各生命倫理原則所受批評處，在於其個人主義原子式的預設，強調每個人自主決定的能力，但卻也較忽略了每個決定的外溢效力，而民主審議正是在補足現有原則不足面向。

與前述審議民主論者相呼應，現今生命倫理中提倡審議的主張，並不僅限於政府決策上的審議，也包括市民社會中的審議。例如在醫病倫理中，也不乏倡導民主審議的主張：敘述性倫理（*narrative ethics*）提倡的醫療決策模式，在於使醫事人員透過病人、病人家屬、社工、其他醫事人員的敘事，對於病人的背景能夠有全貌式的了解，以有助於決策，並對於病人的請求能做出更有意義的回應²⁵³，此概念與民主審議正相呼應，不僅著重相互對話與提

251 *Id.* at 32, 34.

252 例如個人是否選擇醫生協助加工自殺，看似為個人之臨終醫療決定，但事實上也具有政治性，例如反對醫師加工自殺合法化者，便提出滑坡效應的顧慮，即若合法化且越來越多人選擇，是否會使得社會上逐漸認為年老、重病的生命不值得存活。

253 Anne Hudson Jones, *Narrative in Medical Ethics*, 171 *CULTURE & MED.* 50, 52 (1999).

出理由，亦含有包容性的意旨，透過敘事來賦權予病人、家屬及護理人員。又如醫病共享決策（shared decision-making）的理念，亦認為醫療決定必須由醫病共同參與，醫師應該提供各種不同處置之實證資料，病人則提出個人偏好與價值觀，兩方進行意見交換後形成最佳治療的選項²⁵⁴，亦可見具有民主審議的精神。再者，即便醫事人員無法透過外在的溝通對話進行審議，醫療倫理學家也有提及醫事人員得進行個人的審議，即透過內在反思，為醫療決策尋找處在對方立場、情境下所能接受的道德依據，此為審議民主論者所稱之「內在審議」（internal deliberation）²⁵⁵。又如 Gutmann 與 Thompson 說明審議民主實踐的一個例子，是營利性的醫療保險制度如何透過審議，來決定健康保險制度應該給付哪些醫療服務²⁵⁶。如同審議民主論者主張在代議政府外的審議也甚為重要，民主審議作為一生命倫理原則，正有助於審議於市民社會中的深化²⁵⁷。

援引審議民主論者關於市民社會作為審議場域的觀點，民主審議作為一項生命倫理原則，除了指引政府的決策外，亦應適用於市民社會——社區、醫院、實驗室、乃至於家庭內。美國總統生命倫理議題研究委員會在其總結報告提及：民主審議可以適用於不同層次的論壇，除了各層級的政府組織以外，也包括在其他社區層級的組織，像是各級學校、教堂、醫院等²⁵⁸。例如：HEC在醫院中能夠納入機構內專業人士、病人代表乃至於社區代表的聲音，以呈現多

254 參見：醫病共享決策簡介，衛福部病人安全網，<http://www.patientsafety.mohw.gov.tw/Content/Messagess/Contents.aspx?SiteID=1&MmmID=710351317675351145>（最後瀏覽日：2017年9月4日）。

255 Robert E. Goodin, *Democratic Deliberation Within*, in *DEBATING DELIBERATIVE DEMOCRACY* 54, 55 (James S. Fishkin & Peter Laslett eds., 2003).

256 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 139-59.

257 另值得注意的是，審議民主論者如 Mansbridge 也提出，在市民社會中的審議，並非必然必須遵守如同代議政府中審議的嚴格要件，Mansbridge, *supra* note 244, at 221-27. 但此議題涵蓋層面甚廣，期能於日後另為文詳述。

258 PCSBI, *EVERY GENERATION*, *supra* note 6, at 30.

元的觀點，扮演教育與諮詢性的觀點，雖然這些議題最後是私人決定，但HEC的建議有助於機構的處理這類困難的倫理議題²⁵⁹。本文認為，即使是在臨床醫療決定，仍有民主審議實踐之空間，例如在我國安寧緩和醫療條例第7條第3、4項關於不實施心肺復甦或維生醫療的代理決定，雖然該條第4項有明文決定順位，但實務上家屬間的意見分歧頗為常見，此時HEC的建議有助於代理決定，減緩家屬間對於醫事人員處理的判斷，並且釐清倫理爭議；或者家屬間進行審議，也有助於代理決定的正當性，減少日後紛爭。即便最後決定之作成仍回歸個人，但實則審議民主論者也肯認最後決策以審議以外方式做成的可能性²⁶⁰。審議民主的重點，在於審議活動中相互證成的過程，該證成的過程有助於決策的品質，也能強化決策的道德正當性。如前所述，在生命倫理領域中，臨床醫療決定具有外溢效力，不僅影響家屬、醫事人員等關係人，亦涉及社會對於生命價值、資源分配、風險等之判斷，故醫事人員在臨床個案的醫療決定，亦應是能夠以互惠性理由加以證成的決定；而即使是病人或家屬的個人決定，決策的道德正當性亦是須審慎考量的面向。

前述主張是否弱化了審議民主的內涵？本文仍沿用審議民主論者的定義，即受決定影響之公民，應該有機會參與相互證成的過程以尋求共識，且該共識對於參與者產生拘束力，但採取較為寬鬆的解釋，認為此處的「公民」不限於參與公領域中政治決策的公民，也包括私領域中參與治理的人民²⁶¹。而市民社會中的討論，可能是不符合嚴格符合審議要件的言說，像是敘事、帶有利益考量的表

259 *Id.*

260 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 19. (指出審議民主能夠與其他最終決策的方式併存，像是投票或者行政命令。)

261 例如，Gutmann與Thompson也認為審議民主得適用於公司治理中，*id.* at 34，而依渠等對於審議民主的定義中主體為「公民」，則此時股東究竟是公民，還是個人？本文認為並無如此明確的界限，也認為即使在私領域的治理中，個人還是可能作為一個參與治理的「公民」而存在，即使此處的「公民」並非在參與公領域的政治決策。

意、民間的日常討論等，但這也並未為審議民主論者所排斥，甚至認為在公共政策討論時也不應排除這類言說²⁶²；況且在像HEC這樣具有審議精神的組織，恐怕相較於許多公共政策的論壇，更能進行符合審議民主要件的討論。

退萬步言之，縱使採取嚴格定義的審議民主，限定以公共政策為必要，則民主審議原則也至少為個人決策或醫事人員的臨床判斷，提供了「審議」的指引，且審議有助於決策的品質，以及個人自主權的落實。然而即使是僅有「審議」，也並非為現有的尊重自主原則所完全吸收。前述敘述性倫理、醫病共享決策以及其他審議的過程，確實有助於病人或公民自主權的落實，但若僅根據現有的尊重自主原則，恐怕無法突顯審議所強調的平等、相互證成的過程。例如生命倫理學家Ezekiel J. Emanuel及Linda L. Emanuel分析醫病關係，可分為主要四種模式：家父長模式、資訊模式、詮釋模式及審議模式，氏等並指出，這四種模式都能某程度促進病人自主²⁶³，觀

262 See, e.g., IRIS MARION YOUNG, INCLUSION AND DEMOCRACY 53 (2000); Jane Mansbridge et al., *The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy*, 18(1) J. POL. PHIL. 64, 64 (2010); Mansbridge, *supra* note 244, at 211-12.

263 根據Emanuel及Emanuel的見解：「家父長模式」是指醫師運用專業研擬對病人最佳的醫療措施，並且有意識的篩選資訊，促使病人能夠對此最佳方案予以同意，醫師處於權威性的地位；在「資訊模式」(informative model)下，醫病溝通目的在於醫師應該盡可能提供所有相關資訊，使病人能選擇其認為需要的醫療措施，醫師依照病人的意願執行，醫師在此模式中負責提供事實(facts)，而不涉及價值(values)部分；「詮釋模式」(interpretative model)則認為醫病互動的目的，在於釐清病人的價值、理解病人想要的，醫師應該幫助病人選擇最能實現病人價值的醫療措施；至於「審議模式」(deliberative model)則是透過醫病互動，幫助病人特定及選擇在臨床上能實現的最佳的健康相關(health-related)價值，醫師必須提供可能的醫療措施選項，協助病人分析各選項能否實現哪些價值，以及醫師客觀上認為哪些健康相關的價值較值得追求；醫病之間的溝通是一種道德審議過程，醫師不僅提出可行的方案，也提出較佳方案的建議，並且對病人進行道德說服(moral persuasion)；而病人的自主權，則是透過道德審議的過程逐漸形成，省思健康相關的價值以及如何透過醫療措施落實，使得病人不是單純聽從建議，或是單純追求自己未經檢驗的偏好。Ezekiel J. Emanuel & Linda L. Emanuel, *Four Models of the Physician-Patient Relationship*, 267(16) JAMA 2221, 2221-23 (1992).

其推論，可知審議模式並非唯一能實現病人自主的方式²⁶⁴。亦有論者從病人自主程度分析Emanuel及Emanuel的四種模式，認為病人自主程度由高到低依序為資訊模式、詮釋模式，再來才是審議模式、家長模式²⁶⁵，可見審議甚至不是自主的方式，尊重自主原則的內涵也無法突顯審議的重要性。是以，即便認為民主審議在私人間的決策僅有「審議」，但此原則強調多方互相溝通、證成、尋求共識的過程，並非為尊重自主原則所完全吸收。且即便兩個原則有相互重疊之處，在既有各生命倫理原則本有所重疊之情況，亦無損於民主審議作為一獨立原則。

再者，縱使認為民主審議無法用於臨床醫療決定，也並非因此便動搖了民主審議作為一項生命倫理原則的地位，民主審議指引生命倫理相關的公共政策，在機構領域如IRB、HEC、私人保險醫療資源的分配²⁶⁶等，皆有適用，已如前所述。而即使是現有的各原則，也並非在每個決策中都必須被逐一執行。例如現有的正義原則，貝爾蒙特報告是用於檢視受試者招募的倫理性²⁶⁷，而Beauchamp及Childress則著重於此原則在醫療資源的分配²⁶⁸，也並非適用於臨床醫療決定上，但仍無損於正義作為生命倫理原則之地位。

264 *Id.* at 2223. Emanuel及Emanuel提及，在1980年代病人主權（patient sovereignty）高漲的趨勢下，資訊模式取得主流地位，但氏等認為資訊模式的缺點在於弱化了醫師的照顧義務，以及醫學專業中人性、個別化的面向，且似乎預設了病人的價值是一開始就確定且不會變動的，而無法反應病人價值逐漸形成的過程，*id.* at 2226-27. Emanuel及Emanuel在結論中，亦認為審議模式是較理想的模式，*id.* at 2228.

265 Aakash Kumar Agarwal & Beth Brianna Murinson, *New Dimensions in Patient-Physician Interaction: Values, Autonomy, and Medical Information in the Patient-Centered Clinical Encounter*, 3(3) RAMBAM MAIMONIDES MED. J. 1, 4 (2010). 該文也認為，病人價值與病人自主兩者並非同一，而有進一步區分的必要，兩者皆為良善醫病關係中應該考量的價值，而非獨尊自主，例如病人可能有強烈的價值，但不一定有很強的自主，而是選擇依賴家人與朋友參與決策，Agarwal & Murinson, *supra*, at 3-6.

266 See GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 139-59.

267 See NAT'L COMM'N, *supra* note 16.

268 See generally BEUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 262-92.

2. 其他方法論的疑問

民主審議是否將其他原則作為審議的起點，審議的結論必須受到其他各原則的限制？本文認為並無此限制。根據Beauchamp與Childress的看法，既有的各原則之中並無哪一原則處於優位²⁶⁹；至於各原則有相互衝突時，Beauchamp與Childress則認為應該透過衡平（balancing）來加以解決，亦即在多項道德規範中衡量輕重及強度，來決定應該踐行哪項道德義務²⁷⁰。然而值得一提的是，許多審議民主論者不認為審議民主僅是程序性的，而認為審議民主也有必須遵守的實體的核心價值，例如平等、自由的政治權利等²⁷¹。由於審議民主須受到程序與實體原則的指引，因而更能降低民主程序受到操控的機會²⁷²。

在民主審議原則的脈絡下，是否所有決策皆須經過理性審議，直覺在決策中無法發揮功用？實則，審議民主並沒有排除理性審議以外的其他決策方式，例如承認在決策時，累積式民主（aggregative democracy）也有必要，能夠在必須作決定但歧見無法化解時做出確切、爭議較小的決定²⁷³；審議民主也承認理性以外的表達具有重要性，例如認為在政治場域中為弱勢族群發聲時，激情修辭（passionate rhetoric）的表達確有必要性²⁷⁴。再者，民主審議作為一項生命倫理原則，並不代表在每個決策中都必須經過民主審議的程序，正如在其他各原則，也並非在每個生命倫理問題中皆予

269 BEAUCHAMP & CHILDRESS, *supra* note 30, at 140.

270 *Id.* at 20.

271 例如Gutmann與Thompson認為審議民主除了程序原則以外，亦有實體原則，包括基本自由、基本平等、機會平等，*see* GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 12, 199-201, 348。而既有原則中所揭示的尊重自主、正義等原則，或與審議民主的實體原則有所重疊。

272 如生命倫理學家有鑒於近來全球民粹政治的興起，提出強化公民審議與公民教育來加以因應，以擴大公民對公共事務的理解，以及基於公共善（common good）的政治討論，Solomon & Jennings, *supra* note 209, at 11-15.

273 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 79, at 15-16.

274 *Id.* at 51.

適用。在面臨緊急狀況時，直覺有助於有效、及時的決策，也並非民主審議原則所拒斥；然而，除了正確且有效的判斷之外，生命倫理更重視判斷背後的證成，因此直覺的判斷必須受到檢驗，這也正是民主審議重要所在²⁷⁵。

（二）實踐上的疑問

民主審議作為生命倫理原則，是否為Gutmann及其主導的總統生命倫理議題研究委員會的獨有主張，或者在生命倫理學界具有一定共識？本文已陸續提出事證，以證實民主審議被視為一項新原則，具有一定的共識為基礎：其一，除了總統生命倫理議題研究委員會以外，過去歷屆委員會的許多報告中，已可見得民主審議不論是在決策程序上、實體政策建議上，皆具指引性的地位²⁷⁶。其二，生命倫理學家Emanuel與Weijer也曾提出類似的觀點，主張在貝爾蒙特報告的三原則以外，增列「尊重社群」(respect for communities)原則，以補足現行原則過於個人主義、缺乏群體面的關懷²⁷⁷，可謂與民主審議強調包容性、互惠性呼應。其三，在總統生命倫理議題研究委員會提出民主審議為一項倫理原則後，論者便有援引此原則以檢視Common Rule，並且認為即便在有IRB須符合多元性要件情況下，民主參與的程度仍有所不足，故主張應該更強化受試者參與之機制²⁷⁸。

275 審查人詢問在Daniel Kahneman的理論中，將人的思考分成直覺（體系1）與深層思考（體系2），DANIEL KAHNEMAN, THINKING, FAST AND SLOW 20-21 (2011)，民主審議原則是否排斥直覺（體系1）？本文認為從審議民主理論看來，並不排斥依據直覺進行決策的可能性，但民主審議原則更重視如何向公眾或相對人證成此決策。審查人所提的緊急公衛事件的情形，本文認為直覺確實有助於效率、正確的決策，但生命倫理所關注者，在於這樣的緊急決策如何取得正當性，以及如何建立公眾責信，就此也必須訴諸深層思考（體系2）。又，Kahneman認為深層思考也不免受到直覺的影響，而產生偏見，KAHNEMAN, *supra*, at 243，而審議民主則是主張透過相互證成的過程，來調整這些偏見。

276 詳見前「參、三、（一）、2.」所述。

277 Emanuel & Weijer, *supra* note 202, at 165.

278 Persad, *supra* note 208, at 157-59, 167-68.

本文也承認，明文以民主審議作為生命倫理原則者，目前仍是以歐巴馬任命之總統生命倫理議題研究委員會及其個別成員為主。然而，若是觀察貝爾蒙特報告當時如何得出三原則的過程，便會發現三原則也是經歷漫長討論、妥協的結果²⁷⁹，可見當時生命倫理學界對於哪些事項應該作為倫理原則，並非有立即共識，三原則也不見得為當時的生命倫理學家們所共同奉為核心。相較之下，民主審議作為一項原則，現階段雖尚未為其他生命倫理學家所廣泛引用，但該原則不僅在生命倫理領域具有一定的傳統與基礎，在總統生命倫理議題研究委員會中也具有高度共識。例如委員之一Daniel P. Sulmasy指出，原本在最早合成生物學報告中提出民主審議等原則時，並無意特別讓此原則沿用，但其後該委員會面對各項議題時，卻自然而然的再次援引民主審議等合成生物學報告中提到的原則²⁸⁰。現今各倫理原則地位的確立，乃是貝爾蒙特報告作成後被法律化，以及被各決策者、倫理委員會持續實行、檢視後，逐漸確立其地位。同樣的，民主審議被列為一項生命倫理原則以後，其地位也有待於時間的檢證，然而，從近來生命倫理學家不約而同提及民主參與的重要性²⁸¹，可知此原則反應當代生命倫理趨勢，也可預知應有足以面對檢證的基礎。

若加入民主審議原則，是否使得此架構在民主無法落實的國家難以適用，因而不具有普世性？實則，在非採取民主體制的國家也有審議實踐。在中國的地區層級曾有試驗過審議式民調等審議活動²⁸²，甚至是在中央層級的決策如健保改革，也有舉辦公聽會的審

279 Jonsen, *supra* note 25, at 4.

280 Daniel P. Sulmasy, *Ethical Principles, Process, and the Work of Bioethics Commissions*, 47(S1) HASTINGS CTR. REP. S50, S52 (2017).

281 參見前註206-209所相應之本文。

282 Ethan J. Leib & Baogang He, *Editor's Introduction*, in *THE SEARCH FOR DELIBERATIVE DEMOCRACY IN CHINA* 1, 7-8 (Ethan J. Leib & Baogang He eds., 2006).

議活動²⁸³。審議民主論者也確實同意，「審議」的實踐若缺乏對政權的公平選舉、沒有基本的自由與權利，仍難以稱為「民主」²⁸⁴。然而，審議民主論者也不約而同的提到，審議的引進將有助於威權國家的民主轉型，例如Baogang He與Mark E. Warren認為，若審議能更廣泛的被中國政府用於各項決策上，甚而逐漸依賴審議作為其決策正當性的來源，透過這樣治理上對於審議的需要，進而能夠帶動分段式（incremental）的民主賦權（democratic empowerment）²⁸⁵。又如Dryzek也提到，雖然審議在中國目前是以受控制的方式實施，但審議本身是個別公民與公民社會的學習過程，且一旦開始進行，便很難從上而下控制，至少是邁向民主的一步²⁸⁶。由此可見，雖然非民主體制的國家，現階段未必能落實民主審議，但審議本身在決策功能性上的優勢，使得審議程序的實行具有普世性；且將之列為一生命倫理原則，更有積極的意義，尤其是促使審議在國家以外的各場域——公民社會、私人之間——履行，進一步成為國家體制民主化的動能。

283 See generally Yoel Kornreich et al., *Consultation and Deliberation in China: The Making of China's Health-Care Reform*, 66 CHINA J. 176, 176-203 (2012).

284 Leib & He, *supra* note 282, at 15.

285 Baogang He & Mark E. Warren, *Authoritarian Deliberation: The Deliberative Turn in Chinese Political Development*, 9(2) PERSP. ON POL. 269, 283 (2011). He與Warren根據審議在中國的實踐狀況，提出「威權審議」（authoritarian deliberation）的概念，認為「審議」與「民主」之間的關聯性非必然。一般認為，審議與民主賦權之間具有關聯性，即民主賦權能夠確保決策是根據討論或投票來作成，使得審議對決策具有影響力。但He與Warren發現，審議也可能出現在沒有民主賦權的情況下，政治菁英基於功能性的合作或正當性需求，於決策中進行審議，但審議是以政治菁英控制的方式來進行，並且藉此緩和和要求政治體制民主化的聲音，以穩固威權體制的存續，He & Warren, *supra*, at 270。He與Warren認為，現階段在中國，審議以高度控制的方式進行，不必然會帶來政體的民主化，但也認為審議有可能成為從內部重塑威權體制的力量，甚至是帶動民主改革的動力，He & Warren, *supra*, at 282-83。

286 John S. Dryzek, *Deliberative Democracy in Different Places*, in THE SEARCH FOR DELIBERATIVE DEMOCRACY IN CHINA 23, 34 (Ethan J. Leib & Baogang He eds., 2006).

又在臺灣的脈絡下，民主審議是否能成為一項生命倫理原則？本文前述的提出民主審議具有「歷史性」、「普世性」，多是立基於美國及西方國家的生命倫理發展，但臺灣並非外於此趨勢，不僅在各生命倫理議題有諸多公民審議的實踐，在憲法層次也有民主審議的依據²⁸⁷。另值得注意的是，各生命倫理原則在臺灣的實踐，仍有許多未深化之處，例如尊重自主在臺灣的醫療現場其實未被貫徹，即便本人有完全行為能力，由家父長來做成決定的情況仍相當常見²⁸⁸。而總統生命倫理議題研究委員會提出民主審議作為一原則，除了顯現該委員會認為民主審議的重要，也某程度反應了民主審議的實踐在仍有所不足，故有特別將之奉為原則之必要；同樣的，臺灣雖有各項倫理委員會之建置及公民會議等實踐，但在民主審議的落實上或仍有不足之處，故引進此原則的實益，乃在透過生命倫理原則的影響力，以深化民主審議在臺灣的實踐。

伍、民主審議原則的運用：以IRB及司法審查為例

正如總統生命倫理議題研究委員會提到，民主審議應該出現於各層級，而非僅止於國家生命倫理委員會²⁸⁹。以下將提出兩個例子，以說明民主審議作為生命倫理原則，在具體議題上如何應用。第一個例子是IRB，亦即在檢視民主審議如何融入這樣小規模、地區性又兼具倫理與法律性質的機構。IRB的例子著重於程序的觀點，也就是民主審議原則如何有助於生命倫理決策的程序改革。另一個例子則較著重於實體面，將檢視民主審議原則能夠為司法審查的論理帶來哪些啟示。

287 詳見前「肆、二、(一)」及前註187相應之本文。

288 曾建元，病人權利的倫理難題——兼論醫療倫理委員會與倫理諮詢專員在其間的角色，應用倫理研究通訊，25期，頁36-37（2003年）。

289 PCSBI, EVERY GENERATION, *supra* note 6, at 4.

一、以民主審議改革IRB的組織與程序

IRB的設計原理，是透過審議機構的設立，以多元且熟悉系爭議題的成員來決定具有價值爭議性的問題²⁹⁰，但與類似審議組織的不同之處，在於其所被賦予的管制權力。然而，IRB的功能不足已飽受批評，例如無法反應受試者的利益、無法有效監管研究的倫理性及安全性，以及造成研究進度的拖延等²⁹¹。而根據一項美國伊利諾大學做的報告顯示，許多研究者並不信賴IRB具備執行其管制的任務的能力，並且將IRB審查視為對於憲法表意自由的不必要限制²⁹²。有鑑於這些批評，本文認為若適用民主審議原則，或可得出兩個改革IRB之方向，以強化IRB之權能。

（一）提升IRB之多元性

從民主審議的觀點，會認為應提升IRB成員組成之多元性，以更為適切的代表受試者以及社區的利益。具體而言，或可從提升社區成員的比例、提升社區成員的委員的代表性、創造使成員（尤其是社區成員）易於參與審議的加以實施。

在美國法上，目前IRB權能受到批評的來源之一，在於IRB成員欠缺代表性，無法適切的反應受試者甚至社會上的多元觀點。美國Common Rule對於IRB成員的規定，要求應該具有一定性別、種族與文化的多元背景，在五人以上的委員會中，至少要有一位外部委員，以及一位非科技背景委員²⁹³。這兩類委員也被學者稱為「社

290 MORENO, *supra* note 156, at 89.

291 Daniel G. Stoddard, *Note: Falling Short of Fundamental Fairness: Why Institutional Review Board Regulations Fail to Provide Procedural Due Process*, 43 CREIGHTON L. REV. 1275, 1276 (2010).

292 The Ctr. for Advanced Study, *Improving the System for Protecting Human Subjects: Counteracting IRB "Mission Creep"* (U. of Illinois L. & Econ. Res. Paper No. LE06-016, 2006), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902995.

293 45 C.F.R. § 46.10(a), (c), (d).

區委員」²⁹⁴，意味著這兩類委員的參與，是用於代表潛在研究者的利益，以及減低IRB受到委員本身具有利益衝突的影響。然而即便有多元性及社區委員的要求，美國多項實證研究卻發現，IRB通常無法代表受試者社群：IRB成員仍以科學背景、白人、男性居多²⁹⁵；社區委員佔IRB中的少數，且通常是由一人同時兼任外部委員及非科技背景委員²⁹⁶，然而IRB成員的人數平均為13人²⁹⁷，意味著其中社區委員常只有一票到兩票；實證研究也顯示，社區委員其實與其他IRB成員具有較高的相似性，多半是白人、受高等教育、專業人士、透過機構內的關係找到的，其中僅有少數是與受試者的社群有關連性²⁹⁸。

再者，社區委員如何實質參與IRB審查，也是一項挑戰。實證研究發現，社區委員向來在審查告知同意書上有較多貢獻，因為在此事項上素人較能夠表示意見²⁹⁹；但社區委員在參與實質審查中常遭遇困難，主要是他們缺乏足夠的科學專業知識以瞭解研究計畫之核心，以及在科學專家環伺的狀況下通常難以表示意見³⁰⁰。然而，

294 Robert Klitzman, *Institutional Review Board Community Members: Who Are They, What Do They Do, and Whom Do They Represent?*, 87(7) ACAD. MED. 975, 975, 977 (2012); Robert D. Allison et al., *Non-Scientist IRB Members at the NIH*, 30(5) IRB: ETHICS & HUM. RES. 8, 8 (2008).

295 Michelle M. Meyer, *Regulating the Production of Knowledge: Research Risk-Benefit Analysis and the Heterogeneity Problem*, 65 ADMIN. L. REV. 237, 288 (2013).

296 Klitzman, *supra* note 294, at 975.

297 Meyer, *supra* note 295, at 288.

298 Klitzman, *supra* note 294, at 977-78 (發現外部委員多半是退休的科學家，非科學委員多半是訓練有素的專業人士，例如律師、社工等)；Emily E. Anderson, *A Qualitative Study of Non-Affiliated, Non-Scientist Institutional Review Board Members*, 13 ACCOUNTABILITY IN RES. 135, 137 (2006).

299 Klitzman, *supra* note 294, at 979; Allison et al., *supra* note 294, at 9; Sohini Sengupta & Bernard Lo, *The Roles and Experiences of Non-Affiliated and Non-Scientist Members of Institutional Review Boards*, 78(2) ACAD. MED. 212, 215 (2003).

300 Klitzman, *supra* note 294, at 979. (其中提到一位女性的非科學委員受訪指出：雖然在IRB審查的過程中，她並沒有感受到其他成員看扁，但她認為在會議中自己與其他穿著白袍的男性很不同，雖然沒有被有意的不受尊重，但卻時常感到害怕不敢表示意見。)

若社區委員的貢獻僅在告知同意書的審查，顯然有違規範上試圖讓社區委員能夠參與整個審查程序、參與研究風險評估的用意。同時，社區委員也被期待能夠扮演吹哨者（whistleblower）的角色，以及作為研究對公眾負責的重要媒介³⁰¹。實證研究也發現，其實科學與內部委員多半肯認社區委員在涉及易受傷害族群案件、損益評估、受試者招募倫理性等議題上的貢獻³⁰²，許多委員也認為若能夠有更好的訓練、更友善且緊密的互動環境，社區委員將能夠更有效的參與審查³⁰³。

以上美國對於IRB的批評，在我國法上亦有許多可參照之處。我國人體研究法第7條第1項規定：「審查會應置委員五人以上，包含法律專家及其他社會公正人士；研究機構以外人士應達五分之二以上；任一性別不得低於三分之一」，相較於美國法Common Rule的規定外部委員比例較高，但對於非科學背景的法律專家及其他社會公正人士，並無比例的限制，解釋上應只要有一人以上即可。而藥品優良臨床試驗準則第25條第2項³⁰⁴、醫療機構人體試驗委員會組織及作業基準第6條³⁰⁵亦有類似規定，雖在社區委員的專業、比例上要求略有不同，但可看出我國法上對於IRB的組成，普遍具相當於美國法甚或更嚴格的多元組成要求。然而即便如此，根據一項針對2013年6家臺灣中南部主要醫學中心人體試驗委員會的實證研究顯示，委員會中仍以男性醫療專業委員且具備醫師格者為大宗，女性醫療專業委員多為護理人員、藥師而非醫師；至於在非醫療委員的部分，則多為律師、社工師以及宗教人員，女性成員在此部分

301 Allison et al., *supra* note 294, at 12.

302 Sengupta & Lo, *supra* note 299, at 215-16.

303 *Id.* at 216-17; Anderson, *supra* note 298, at 152.

304 「人體試驗委員會之委員至少五人，其中至少一位為非科學背景者，且至少一位為非試驗機構成員。」

305 「委員會置委員七人至二十一人……前項委員除有關醫事專業人員外，應有三分之一以上為法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士。委員中應有二人以上為非試驗機構內之人員，並不得全部為單一性別。」

的比例較男性成員為高³⁰⁶。此項研究的研究者並指出，醫療專業與人體試驗委員會決策的權力有相當的關聯性，過半以上的研究案都是由具醫師資格者提出，多數委員也都是由醫師擔任，而非醫師背景的委員多半只能就告知同意書的明確性、受試者保護事項審查³⁰⁷。由此可見，社區委員如何更為有效參與、發揮影響力，亦是我國IRB運作上所面臨之問題。

若基於民主審議原則，或可提出以下改革建議。第一，應該要提升社區委員的比例——尤其是非科學委員的比例，使他們達到足以影響決策的一定人數。提升社區委員比例的目的，在於使社區委員的觀點能夠達到臨界多數（critical mass），使得社區委員在參與討論時能更感到自在，進而能夠有效參與，並且勇於表達外部者的觀點。在此所謂的臨界多數，是在於使社區委員的觀點能夠發揮影響力，於決策過程中得以發聲並影響決策³⁰⁸。例如由柯林頓總統任命之國家生命倫理諮詢委員會（National Bioethics Advisory Commission, NBAC），在2001年的一份報告中，即建議至少要有25%的IRB委員，是屬於以下三種類型：代表受試者觀點委員、與機構無關的外部委員、代表科學以外觀點之委員³⁰⁹。

306 林怡欣，台灣醫院人體試驗委員會組成之性別分析，元培學報，20期，頁40-41（2013年）。

307 林怡欣（註306），頁43-45。作者認為依決策權力的高低可分為四個等級：主要權力——男性醫師專業委員、次級權力——女性醫師專業委員、三級權力——非醫師專業委員、四級權力——非專業委員，並主張應該要提升女性醫師在倫理委員會中參與的比例，林怡欣（註306），頁43。

308 目前我國IRB仍是採取多數決為原則，依據人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第10條：「前條審查會會議之議決方式，以多數決為原則……」。本文此出所倡議之臨界多數，並非等同於使社區代表在多數決的表決中取得相對或絕對多數，而是確保社區委員可以因為達到一定人數而能夠有效參與。

309 NBAC, ETHICAL AND POLICY ISSUES IN RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS, SUMMARY 12 (2001), <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/nbac/human/oversumm.html>.

相較於美國法，我國人體研究法已有規定五分之二以上的外部委員，且審查會要求必須有一位以上機構外委員之非科學委員出席才可開會³¹⁰，顯見我國法已有考慮社區委員參與之必要性。然而，以一位機構外委員之非科學委員為召開審查會最低門檻，可以想見其不免會有孤立、難以暢所欲言之情況，加上人體研究法並未規定非科學背景委員需要到達一定比例，而實際上科學背景的外部委員多半與機構的科學背景委員觀點相似，難謂現行規定已達保障外部觀點的臨界多數。本文認為：人體研究法應該增定非科學委員的比例，規定至少要有三分之一以上為非科學背景委員，並且提高開會的外部委員暨非科學委員的出席門檻在二人以上。原因在於，非科學委員的參與其實對於多元性的提升有關鍵性影響，因為科學委員不論屬於機構內外仍有相通的價值觀，而非科學委員的有效參與，多半更有助於多元觀點的呈現^{311、312}。再者，提升非科學委員的比例，並不會壓縮各領域專家參與的空間，因為各領域專家事實上仍佔多數（依本文見解，仍有約三分之二），且可透過增加委員會總人數的方式，俾使足夠人數的專家能夠被納入，以確保IRB審查中能有充分之專業意見。

從民主審議的觀點，除了提升社區成員的比例，亦應該提供社區委員友善的審議環境，鼓勵其積極參與討論。政治哲學家Iris

310 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第6條第1項：「審查會召開一般程序審查會議時，其出席委員應包括機構外之非具生物醫學科學背景委員一人以上。」

311 本文也認為，現行法對於不同機構之IRB組成比例之規範，寬嚴不一，且缺乏為何比例不同之規範基礎，似應統一以求規範一致為妥。

312 再者，關於IRB中是否應該包括受試者代表一點，Common Rule中有類似的規定：在以受刑人為對象之試驗，IRB委員必須包括至少一名以上的受刑人代表，45 C.F.R. § 46.304。但本文認為，包括受試者的困難往往在於，受試者的代表往往不易特定，不僅每一項研究的受試者不相同，如何從受試者中找出具有代表性的委員易非易事。從民主審議的觀點，會認為重點並非有沒有直接的受試者代表，而是IRB審議中能夠呈現受試者的觀點，以及能否提出受試者可接受的理由，而這兩個面向，都可透過加強社區委員的代表性，以及從審議程序上落實社區委員的參與，來加以落實。

Young強調包容性（inclusion）在審議上的重要性，並且除了外部的包容性——對於參與審議的代表須具有包容性——以外，亦應重視內部的包容性（internal inclusion），亦即在理性論述以外，也應該將其他的論述方式納入審議中，藉此讓賦權（empower）邊緣化族群能夠參與審議³¹³。對於社區委員（尤其是非科學背景者）的內部包容性尤其重要，因社區委員常可能因為作為外部者、作為非科學專業者，而較怯於參與討論，或者較難以理性的方式表述其觀點。本文認為：社區委員的意見應該被特別徵詢，IRB主席或者工作人員可以直接詢問社區委員對於申請案的意見；或者讓社區委員有特別的時段可以先相互討論他們的意見及經驗³¹⁴，這樣的討論可實踐Cass Sunstein所述的「正向包圍審議」（positive enclave deliberation）——邊緣群體與同質性較高者進行審議，將有助於提升他們參與審議的能量³¹⁵。IRB可於開會期間公開表揚社區委員的貢獻，這也是Young認為應該納入審議的「致意」言說，透過此儀式可以強化社區委員與IRB之間的關係。再者，應該提供非科學背景委員足夠的教育訓練，以提升其知識及參與審查的能力。

（二）IRB審議程序的民主化

民主審議原則會關注的第二個焦點，應在於IRB的審查程序如

313 Young特別舉出三個例子：互相致意（greetings）、修飾性的言詞（rhetoric）、敘事（narrative），這些論述雖然並非審議言說中的理性的論述，但Young認為仍應該將之納入審議，YOUNG, *supra* note 262, at 53.

314 Sengupta & Lo, *supra* note 299, at 217. 值得注意的是，衛生福利部委託財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會對IRB進行查核的所依據的「105年度人體研究倫理審查委員會查核基準及評分說明」第2.13點：「審查會議針對個別研究計畫決議前，若該案討論過程中無非具生物醫學科學背景委員（非醫療委員）發言，主任委員應主動詢問非具生物醫學科學背景委員（非醫療委員）之意見」，已有具有民主審議的精神，與本文主張相同，感謝匿名審查人提點此訊息。該評鑑標準資料來源：<http://www.tjcha.org.tw/FrontStage/page.aspx?ID=4CEEE406-B9BA-4733-83EB-B004FC5B762C&PID=A7FC485A-0009-4CCF-9D35-141F17016B90>（最後瀏覽日：2017年8月31日）。

315 Sunstein, *supra* note 219, at 82.

何有效的將社群引進於決策程序中。許多批評認為，即便IRB由多元成員組成，仍不必然能夠適切的達成其保護受試者的管制目標³¹⁶。程序的重要性實不下於成員組成。

美國Common Rule對於IRB如何進行審查，其實規範密度較低。論者認為，IRB的設計乃基於地區性的專業自治，認為IRB對機構文化以及在地社群的文化較為瞭解，最適合作為監管的機構，因此Common Rule賦予IRB相當的判斷空間，不論是實體上如利益風險評估的要件，或者是程序上IRB決策所應遵守的要件，規定都相當模糊寬鬆；且審查過程，也以不公開為原則³¹⁷。再者，Common Rule中要求IRB的說理義務也相當薄弱，只有在案件不予通過時才須要附理由³¹⁸，且也沒有上訴或者先例原則可以拘束裁判的標準，因此論者形容IRB審查是根據社區價值所為的個案（idiosyncratic）審查，而非基於一致的審查標準³¹⁹。批評者認為，審查有流於恣意及偏頗的狀況³²⁰，而地區性的自治優勢也多中心研究的趨勢不相符。但從民主審議觀點，最重要的批評是受試者的程序參與不足，受試者雖然是利害關係最相近者，但在審查程序中的地位不明。由於IRB審查是前瞻的（prospective），審查時受試者常尚未能特定，使得受試者觀點在審查程序中往往隱而不顯³²¹。

論者有認為，依據正當法律程序原則，亦即國家對於人民的生命、身體、財產的剝奪，非經正當法律程序不得為之，應改革Common Rule中的IRB審查程序³²²。本文認為，在此IRB的審查程

316 MORENO, *supra* note 156, at 98; Anderson, *supra* note 298, at 151.

317 Carl H. Coleman, *Rationalizing Risk Assessment in Human Subjects Research*, 46 ARIZ. L. REV. 1, 13-14 (2004).

318 45 C.F.R. § 46.109(d).

319 Coleman, *supra* note 317, at 23 (2004); Laura Stark, *Victims in Our Own Minds? IRBs in Myth and Practice*, 41 LAW & SOC'Y REV. 777, 782 (2007).

320 Coleman, *supra* note 317, at 21-24.

321 Meyer, *supra* note 295, at 241.

322 Stoddard, *supra* note 291, at 1290-1325.

序應類推適用正當法律程序，理由有二：一為IRB對人體研究進行治理，負責行使Common Rule授予對人體研究進行審查、監督的公權力，若通過審查而容許研究進行，形同是國家公權力容許研究者對受試者之生命、身體進行侵害，且對受試者之權利影響重大；其二，經IRB審查的研究，許多受有聯邦補助，形同國家政策的延伸，故應類推適用正當法律程序³²³。

論者有依據正當法律程序，提出各種更為嚴格的程序要件，像是應該提供詳細且符合一定格式的書面審查意見、救濟制度、類似判決先例的審查先例制度、類似行政程序法上的公告並表示意見³²⁴、當事人提出證據的權利、依證據為審判原則³²⁵等。民主審議原則應會贊同前述建議，然而相較於正當法律程序著重於程序正義，民主審議更著重於審議的論理及包容性，也就是那些利害關係人應該有權表示意見，最後決策也應該提出利害關係人能夠接受的理由。

我國法與美國法的規定相似，對於IRB審查程序缺少較明確之規定。我國人體研究法第8條依風險高低而區分審查程序：「研究計畫之審查，依其風險程度，分為一般程序及簡易程序。…」，同法第7條第2項規定：「審查會開會時，得邀請研究計畫相關領域專家，或研究對象所屬特定群體之代表列席陳述意見」，並於同條第3項授權主管機關就「審查會之組織、議事、審查程序與範圍、利益迴避原則、監督、管理及其他應遵行事項之辦法」訂定辦法。而根據主管機關衛福部所定之人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法，僅有規定研究計畫應審查之項目³²⁶；以及在審查程序上，規

323 論者也有認為應直接適用正當法律程序的理由，在於許多IRB為公立機構所設立，且對於研究者的研究自由造成侵害，*id.* at 1303-08.

324 Coleman, *supra* note 317, at 27-49; Stark, *supra* note 319, at 784. 但值得注意的是，這邊論者的主張主要是出於保護研究者的研究自由。

325 Stoddard, *supra* note 291, at 1302.

326 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第9條：「研究計畫之審查，應

定審查以多數決方式為原則³²⁷，若是採取簡易審查得由一人以上委員代表行使核准之決定並提報審查會³²⁸，審查結果應以書面為之³²⁹，且委員會紀錄應予公開³³⁰。

在受試者參與上，根據人體研究法第15條第1項、原住民族基本法第21條第1項規定，以研究原住民為目的者，或者於原住民部落及其土地內從事學術研究者，應諮詢、取得各該原住民族之同意，並得與原住民部落進行利益共享。而主管機關依授權頒布之人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法，則規定若以原住民為目的之研究，應向中央原住民主管機關申請，由中央主管機關決定該研究應向各級諮詢會或部落會議行使諮詢、同意或約定商業利益及其應用事項³³¹；而諮詢會的組成，至少應由具有原住民身份者擔任召集人³³²，是為我國法上顯著關於受試者參與之機制。關於諮詢、同意或約定商業利益及應用的程序如何進行，該辦法提到「應邀請中央或地方衛生主管機關與研究計畫相關之專家學者及其他社會公正人士列席，並得邀請研究主持人或其代表列席陳述意見」³³³，試圖創造受試者代表與專家、其他社會代表、甚至研究主持人對話之機會。然而，除了以原住民族為目的之研究以外，其他研究則並無類似的規定。

至少包括下列事項：一、主持人資格。二、研究對象之條件及招募方式。三、計畫之內容及其執行方式與場所。四、本法第十四條所定告知同意事項、告知對象、同意方式及程序。五、研究對象之保護，包括諮詢及投訴管道等。」

327 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第10條前段。

328 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第11條第1項。

329 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第14條第1項。

330 人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第12條。

331 人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法第6、7條。

332 人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法第5條。

333 人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法第8條第3項。

依據民主審議原則，本文認為或可有以下改革方向：其一，應該提高共識決在審議中的運用程度，這並非指多數決應該完全被排除，但民主審議的觀點會認為，尋求共識是審議最重要的目的之一³³⁴，參與者審議者應該在歧異中循求相互可接受的共識。生命倫理學家Jonathan Moreno也認為，IRB此類的倫理委員會，其正當性來源在於能夠凝聚共識：一個具有多元性組織所凝聚的共識，使得其所達成的共識結論具有相當有力的道德基礎³³⁵。我國現行法仍以多數決為原則，但本文認為應該改採共識決為原則之方式，或者應該提高審查會表決之門檻為出席者三分之二，以保障少數（尤其是社區委員）之意見能夠被審酌。

其二，應該提升IRB審查程序中的公民參與。在遇到科學或者社會風險性較高的案件，IRB負有徵詢利害關係人列席或以書面表示意見的義務。人體研究法第7條第2項規定：「審查會開會時，得邀請研究計畫相關領域專家，或研究對象所屬特定群體之代表列席陳述意見。」本文認為此規定應予以強化，對於高風險的案件有IRB諮詢專家的義務，此時「專家」並非限於該點所列者，也包括經驗性的專家，如潛在的受試者，或者是為受試者發聲的倡議團體³³⁶。至於如何找到可諮詢的經驗專家，則是IRB應努力的事項，

334 然而，論者也有認為以共善為目標並尋求共識，可能會與多元性的意旨難以共存，因為在群體有多元性的情況下，成員間對於何為共善的想法往往差異甚大，難以形成共識；再者，多元的表意可能因為追求共識而受到限縮，尤其是弱勢成員難以發聲，會被迫因為共識而放棄自己的觀點，甚至可能因為長期的共識決而弱化少數群體身份認同的獨特性，參考：陳東升，審議民主的限制：公民會議的經驗，臺灣民主季刊，3卷1期，頁80-86（2006年）。本文同意前述對共識尋求的批評，但也認為若能透過賦權弱勢、少數觀點發聲的方式，使得共識尋求的過程中，少數觀點能夠變成具有影響共識的關鍵少數。此在IRB的脈絡下，又特別具有可行性，因為IRB的討論人數較少且較固定，弱勢或少數觀點（例如非科學成員、外部成員、受試者代表或社區代表）也容易特定。

335 MORENO, *supra* note 156, at 98.

336 Persad, *supra* note 208, at 164. Persad援引民主審議原則，解釋Common Rule裡規定IRB得諮詢特定領域專家以有助於審查（45 C.F.R. § 46.107(f)），認為此時專家應該包括經驗性的專家，像是受試者或病友。

IRB可以邀請潛在受試者來表示意見，或者是透過問卷的方式詢問潛在受試者的群體，甚或是以公告並徵求表示意見的方式為之³³⁷。

其三，應該將研究者是否進行社區諮詢（community consultation），納入IRB審查的項目之一。社區諮詢的目的，在於補足告知同意以及IRB審查的不足，因受告知同意的受試者多半是被動的選擇是否加入，並無參與倫理對話的機會，而真正的利害關係人也非必然是受試者或IRB委員，IRB委員也非必然能探知利害關係人的觀點。社區諮詢的優勢，並非僅在於工具性的使研究者及IRB能夠更為特定利害並且進行權衡，更在於透過利害關係人的程序參與，以補足決策正當性的不足；再者，社區諮詢的程序能創造共同責任感，透過參與，使社群成員認為自己有某種積極參與研究的義務，以及接受研究所產生的效應³³⁸。我國現行法規規定應進行社區諮詢（或同意）者僅限於以原住民為目的之研究，但對於其他研究則並無明確的指引。相較之下，美國法現行規定應進行社區諮詢的情況有幾種：一是Food and Drug Agency（FDA）規定在受試者告知同意免除的緊急狀況，必須進行社區諮詢³³⁹；二是在以特定族群或其成員為研究對象時，National Institutes of Health（NIH）建議進行社區諮詢³⁴⁰；論者也有認為，在涉及大規模或較具敏感性的研

337 這樣的程序其實在現行美國Common Rule裡面已有類似規定：在涉及以兒童為受試者的研究中，若IRB發現研究雖難以通過損益衡量，但預期研究結果能夠對於兒童健康或福祉重大問題的瞭解、預防或者抑制有所貢獻時，IRB得將研究計畫提交給HHS，而HHS會以公告並徵求表示意見、邀請專家學者表示意見之方式來審閱研究計畫，45 C.F.R. § 46.407(b)。雖然美國Common Rule現行規定是由HHS來進行此程序，但若由IRB來進行此程序，似也不至於有太大執行上的困難。另覆審查人之疑問：此程序是否為類似聽證程序或司法程序？本文認為此處並非聽證（應符合兩造公平陳述意見、言詞為之等要件），而是類似美國行政程序法上的公告並表示意見（notice and comment），目的在於將潛在受試者及利害關係人的觀點納入決策考量。

338 Neal Dickert & Jeremy Sugarman, *Ethical Goals of Community Consultation in Research*, 95(7) HEALTH POL'Y & ETHICS 1123, 1125-26 (2005).

339 21 C.F.R. § 50.24(a)(7).

340 *The Ethical, Legal and Social Implications Research Program*, NAT'L INST. OF HEALTH

究時，建議應進行社區諮詢³⁴¹。本文認為，除在以原住民為目的之研究法已有明文外，社區諮詢在性質上可比照目前的審查中常見的進行資料及安全性監測計畫或資訊委員會設置（DSMP/DSMB）要件，對於有較高社會風險的實驗，研究者可以自行提出社區諮詢的計畫，或者IRB可以要求其提出進行諮詢的計畫或設置諮詢委員會。

至於社區諮詢的另一個難題，在於如何特定「社區」為何，以及如何選任適合的代表，民主審議對此難以提出一般性的標準。這兩個問題在效力更直接的「社區同意」（或稱「社區否決」）更為顯著，同意權的行使，必須有賴於完整的政治系統，以確認有適切的代表為之³⁴²。相較之下，社區諮詢的優勢在於較有彈性，能夠透過多種管道使不同的聲音發聲，且縱使結果不具法律上的拘束力，仍具有事實上的影響力，並促使研究者與IRB對社區諮詢中的意見考量或提出理由回應。

以上基於民主審議觀點所為的程序建議，不免會面臨一項質疑：若是IRB已面臨工作超載、延滯研究的質疑，則強化民主審議的程序，更會增加程序的遲緩與審查成本。然而，正如主張貫徹正當法律程序者所言，為實現正當法律程序，成本增加實屬必要³⁴³。即便在正當法律程序原則下，成本考量也是考量重點之一，然而也並非唯一考量，而尚須與公共利益相權衡³⁴⁴。本文進行損益衡量，認為踐行審議且參與的程序，亦可降低許多潛在社會成本的發生，例如違反倫理的研究所造成的損害、社會對於科學信賴度的降低、

NAT'L HUMAN GENOME RESEARCH INST. (Sept. 9, 2015), <https://www.genome.gov/10002329/elsi-research-program-fact-sheet/>.

341 Dickert & Sugarman, *supra* note 338, at 1123. (該文認為在以原住民為受試者、族群基因研究、遺傳性研究、跨域研究、愛滋研究時，建議應該進行社區諮詢。)

342 *Id.* at 1124.

343 Coleman, *supra* note 317, at 49.

344 See Mathew v. Eldridge, 424 U.S. 319, 437-38 (1976).

民眾不願意擔任受試者等，且參與也會帶來公民德性提升的公共利益，即便IRB的程序成本增加，仍是利大於弊。再者，前述民主審議的程序，並非必然於每一個審查案中實施，對於低風險的免除審查、簡易審查，仍得以現行簡便的方式為之；且即便在一般審查，亦限於IRB認為高風險之狀況，方要求踐行各項更強的民主審議程序。

二、民主審議運用於司法審查

於生命倫理議題的司法審查上，民主審議也能提供指引。雖然憲法上已有正當法律程序原則等含有民主審議之內容，然而，現有生命倫理原則中也不乏目前憲法基本權中所包含之面向，但生命倫理原則仍舊在安寧緩和決定等具體個案中，成為法院引用為論理之依據³⁴⁵。是以，將民主審議增列為一原則，亦對於法院有引導之作用，促使法院於具體個案中，能特別就此原則進行審酌³⁴⁶。

民主審議原則落實於司法審查中，或可表現於兩個層面：其一為法院審查一項決策或行為之作成程序是否符合民主審議，以判斷該決定或行為的合法性及合倫理性。例如在*Quinlan*案中，該案是一名父親請求移除陷入植物人狀態的女兒的維生設施，紐澤西最高法院認為若要合法移除病人的維生設施，應該符合以下三個要件：（一）病人監護人與家屬的共同同意，（二）醫師診斷認為，病人沒

345 參見前註227所相應之本文。

346 另覆審查人之疑問：相較於IRB組成本文提出提升社區委員參與質量之建議，為何在司法審查部分，沒有同樣建議納入法院納入國民參審？實則，審議民主論者也並非主張，每個審議的論壇都一定要有公民代表，尤其法院負依法獨立審判之責，與其他政治部門的決策組織仍有所不同。如John Rawls認為美國最高法院是公共理性的示範論壇，JOHN RAWLS, *POLITICAL LIBERALISM* 235 (1996)，或者如本文援引Sunstein提出美國最高法院如何落實審議民主精神之方式，都並未以法院以引進國民參審為必要。有鑒於2017年12月我國「國民參與刑事審判法」草案公布，本文亦同意得或可考量國民參審之事項，得納入對於重大生命倫理爭議之案件，以落實民主審議原則。然而，法院審判是否/如何納入國民參與應是更為深層的問題，本文在此恐不及論述。

有合理可能性，能夠從現在的植物人狀態回覆意識，以及（三）必須諮詢過醫院的倫理委員會（HEC），委員會也同意沒有回覆可能性³⁴⁷。紐澤西州最高法院認為，由於HEC能夠提供「更多的觀點及多元的知識」而有助於醫療決定，因此HEC向來得作為審查醫學倫理困難問題的機制，並且為病人和醫療服務提供者提供保護和協助³⁴⁸。*Quinlan*法院將民主審議原則作為一項程序要件，用以判斷一個醫療決定是否合法及合倫理，形同認定透過民主審議原則所為的醫療決定，將會是符合倫理的。這樣的觀點也可見於其他例子，例如在一項關於法院如何評價IRB決定的研究中，論者發現若是IRB的進行符合法定要件，則法院多半認為IRB的決定具有規範效力，在此也可看出法院採取民主審議的觀點，亦即肯認若是經過一個審議的組織所為的決定，是符合倫理的。若將民主審議視為一個指引原則，法院應該審酌系爭決定或行為是否由具有民主審議精神的組織作成，或者曾進行具有審議精神的公眾諮詢等程序，來認定該決定是否合法及合倫理。

另一個落實民主審議原則的觀點，則是如同許多審議民主論者所提倡者：法院（特別是憲法法院）在生命倫理相關案件的判決中，應該扮演促進民主審議的角色。例如Gutmann與Thompson在分析美國最高法院過去墮胎案件時，便從審議民主的觀點出發，認為法院應該要提出以生命為重（pro-life）跟以選擇為重（pro-

347 *In re Quinlan*, 70 N.J. 10, 355 A.2d 647, 671 (1976).

348 *Id.* 其實若細究*Quinlan*案事實，或可發現：本案中的HEC其實並非具有多元成員組成的醫療倫理委員會，而是專業成員所組成、協助醫師進行醫療判斷的小組，但論者多認為此判決以後，今日多元組成的HEC的重要性方逐漸確立，see MORENO, *supra* note 156, at 99; Wolf, *supra* note 224, at 807。然而從法院強調「更多的觀點及多元的知識」這點看來，足見法院認為較為民主審議的決策程序具有較高正當性，故應予以尊重。又，本小節並非認為HEC或者法院，必然是較IRB更為符合民主審議的論壇，而不須強化民主審議的元素，而僅是立基於民主審議原則的觀點，分析法院在生命倫理案件中的論理。因此，即便當時的HEC可能仍「不夠審議」，*Quinlan*案法院的論理，至少也顯示出對較為符合民主審議原則的偏好。

choice) 雙方皆可以接受的意見，亦即具有互惠性的 (reciprocal) 意見³⁴⁹。他們認為 *Roe v. Wade*³⁵⁰ 部分與審議民主相符合，在該案中法院認定有保護潛在生命的國家利益，並且以此為禁止第三期墮胎的理由，雖看似向生命為重的光譜靠攏，但一方面又維持未承認胚胎為人的中立立場³⁵¹。然而，*Roe* 法院在第二期的論理上，卻並未提出審議民主認為具有互惠性的理由，法院採取家父長主義的觀點，認為第二期墮胎的風險高於生下小孩，故應以保護婦女健康為重而不論婦女意願為何，但這樣的觀點從未獲得任何一方的贊同。法院也未能說明為何婦女的健康高於潛在生命的利益，又或者限制墮胎的必要性為何³⁵²。Gutmann 與 Thompson 又認為 *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*³⁵³ 中所採取的不正負擔 (undue burden) 以及實質障礙 (substantial obstacle) 要件符合審議民主的精神，為歧見提供了暫時性的共識，一方面肯認婦女墮胎的權利，一方面則允許在不構成不正負擔及實質障礙的前提下，能對於婦女墮胎權利加諸某些限制³⁵⁴。

又如 Sunstein 以醫師加工自殺之爭議，作為討論在其所主張的司法極簡主義下，法院如何促進審議民主。Sunstein 認為，為了使政治部門能夠發揮其功能並負起民主責任，法院應該自制，僅就案件本身或者以較窄的方式為判決³⁵⁵。以 *Washington v. Glucksberg* 為例，該案宣告禁止醫師加工自殺的州法並不違憲，法院多數意見認為，並沒有法律上或實踐上的傳統，可以佐證在正當法律程序條款

349 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 74-87.

350 See *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

351 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 86.

352 *Id.*

353 See *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992).

354 GUTMANN & THOMPSON, *supra* note 78, at 87.

355 CASS R. SUNSTEIN, ONE CASE AT A TIME: JUDICIAL MINIMALISM ON THE SUPREME COURT 26 (1999).

下，人民有循求醫師協助自殺的基本自由權，因此州法對此加以禁止與重要且正當之國家利益相符³⁵⁶。Sunstein認為，*Glucksberg*案的多數意見符合司法極簡，也就是最高法院對於核心性的議題——究竟人民面對身體的痛苦或死亡將至時，有沒有權利請求醫生協助自殺——採取開放的態度³⁵⁷。只要理性的人可能會對此有不同看法，且民主程序無瑕疵，則此時法院就傾向不作判斷，而留予立法部門、醫學社群、家庭等其他論壇，來討論個人選擇的範疇以及國家介入的正當性³⁵⁸。而這樣對基本議題採取開放公眾討論的角度，也與生命倫理促進跨領域、多元觀點相互對話的傳統相符。

若增加民主審議原則，或許能為我國生命倫理的判決帶來不同的啟發。例如在司法院釋字第690號解釋中，大法官宣告SARS期間當時之傳染病防治法第37條第1項規定³⁵⁹曾與病人接觸者或疑似被傳染者主管機關得令強制隔離不違憲。大法官在解釋理由書中認為本法之目的為阻絕疫情蔓延、降低社會之恐懼不安等重大公共利益，手段採取之強制隔離、檢疫，係保護受隔離者生命與健康，且無其他較小侵害方法，對受拘禁者的人格權亦未遭受重大影響，故與比例原則並無不相符之處³⁶⁰。本解釋也進一步說明，在正當法律程序原則下，強制隔離不需採取法官保留之原因，其一在於強制隔離與其他防疫措施以保障人民生命與身體健康為目的，與刑事處罰之限制被告人身自由不相同，程序亦毋須比照；其二則在於，防疫與其他防疫決定由主管機關基於其專業判斷為之，在專業及效率上都較法院能達到迅速防治之功效；其三，大法官也認為行政處分之

356 *Washington v. Glucksberg*, 521 U.S. 702, 705 (1997).

357 SUNSTEIN, *supra* note 355, at 76, 115.

358 *Id.* at 116.

359 當時之傳染病防治法第37條第1項：「曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得由該管主管機關予以留驗；必要時，得令遷入指定之處所檢查，或施行預防接種等必要之處置。」

360 司法院釋字第690號解釋理由書第4段。

作成應依行政程序法及其他法律為之，受隔離者亦得請求行政救濟，故現行法由主管機關為強制隔離之處分並不違憲³⁶¹。但大法官最後也警告性的指出，強制隔離仍為人身自由遭受剝奪，故隔離期間不宜過常，而應明定最長隔離期限、決定施行強制隔離處置相關之組織、程序、受隔離者及其親屬之救濟程序、合理補償機制等³⁶²。

然而，此解釋認為強制隔離不以法官保留為必要，在不同意見書及學界皆有批評。批評的見解不外認為：憲法第8條的適用並非限於刑事程序³⁶³；就人格權的侵害程度而言，強制隔離對受隔離者的汙名化，並不亞於刑事拘禁³⁶⁴；而事後行政救濟雖有法院介入，但與法官保留下行政機關必須主動提請法官介入仍有所不同³⁶⁵，更不應該以人民本有的訴訟權保障來架空人身自由限制之法官保障³⁶⁶等。

值得注意的是，多數意見就大法官主張由行政機關而非法院作為較好決策者一點，批評者不約而同的提及決策程序透明、外部監督的重要性，隱含著民主審議原則的適用。例如許宗力大法官部分不同意見書提到：法官保留的重點在於使程序透明化，使行政機關對於人身自由的剝奪，必須提出詳盡的說理，並公開接受反方的質

361 司法院釋字第690號解釋理由書第5段。

362 司法院釋字第690號解釋理由書第6段。

363 司法院釋字第690號解釋李震山、林子儀大法官部分不同意見書，頁2；許宗力大法官部分不同意見書，頁3；許玉秀大法官不同意見書，頁13；李建良，人身自由的憲法保障與強制隔離的違憲審查——釋字第690號解釋，台灣法學雜誌，186期，頁75-76（2011年）；林超駿，非刑事預防性拘禁之法官（院）保留——兼評釋字第690號解釋，月旦法學雜誌，207期，頁180-185（2012年）。

364 李建良（註363），頁74。

365 李建良（註363），頁77；林超駿（註363），頁192-193。

366 司法院釋字第690號解釋許宗力大法官部分不同意見書，頁6；許玉秀大法官不同意見書，頁12-13。

疑與檢驗³⁶⁷。過去對於精神病患、傳染病患的汙名歷史，其共通點都在於僅憑專家決定，而使這些判斷背後所涉及的政治考量、社會歧視隱而不顯，故以法官保留以防止行政濫權，確有必要³⁶⁸。許大法官也指出，多數意見雖有要求，系爭強制隔離須經主管機關「通過嚴謹之組織程序」為之³⁶⁹，足見多數意見也認為強制隔離應該採取比一般行政程序更為嚴格的程序，但姑且不論這類程序在公平、透明性上是否可及於法官保留，當時之傳染病防治法也缺乏類似規定，故多數意見雖未宣告違憲，卻也於文末籲請就施行強制隔離相關之組織、程序等辦法加以明定³⁷⁰。許大法官前述關於法官保留或更嚴謹之組織程序的論述，雖是基於憲法上的正當法律程序³⁷¹，然其結論強調行政機關應提出說理並接受反方挑戰、公平性與透明性等，具有民主審議的精神。學者李建良也認為：正因為有專業性、正確性、效率性的要求，因而更有以中立、公正、公開的程序進行多方檢證的必要；氏指出，隔離、防疫決定的醫療專業性，並不必然等於由醫療體系作出的決定符合專業要求，且體系內之決定難免會有偏差、獨斷，故須要體系外的控制³⁷²。

民主審議原則的存在，已為司法院釋字第690號解釋理由書中提及強制隔離決定宣示應該由主管機關「通過嚴謹之組織程序」為之，以及許宗力大法官等對於僅憑主管機關專業決定的質疑，可見一斑。從民主審議的觀點，會認為多元意見的參與，以及作成強制隔離所應附之說理義務是為必要，因而認定僅由主管機關依其專業衡酌情況及參照世界衛生組織標準所為之判斷，與民主審議原則仍不相符。再者，從民主審議的觀點出發，也會認為急迫性及社會之

367 司法院釋字第690號解釋許宗力大法官部分不同意見書，頁4。

368 司法院釋字第690號解釋許宗力大法官部分不同意見書，頁4-5。

369 司法院釋字第690號解釋理由書第5段。

370 司法院釋字第690號解釋許宗力大法官部分不同意見書，頁7。

371 司法院釋字第690號解釋許宗力大法官部分不同意見書，頁1。

372 李建良（註363），頁77-78。

恐懼不安之國家目的，並非完全免除民主審議程序的事由，反而風險溝通是傳染病防治中不可或缺之一環，正如總統生命倫理議題研究委員會在針對伊波拉病毒之倫理與公共衛生議題所為之報告指出：即便在緊急之中民主審議常相當困難，但委員會仍堅持緊急時必須有一定的公眾參與，原因是公眾參與有助於政策推行所必須之公共信賴，且能體察公眾（尤其是受影響族群）的情況而進行修正³⁷³。是以，若增加民主審議原則並充分發揮生命倫理原則的規範效力，將使司法院釋字690號解釋之結論頗不相同，而趨於較為符合不同意見與學者所主張採取法官保留之更高度人權保障。

陸、結論

生命倫理試圖對一切與醫學、生命科學與技術之議題，進行跨領域及多元觀點的討論。現今生命倫理主流的分析架構，是於1970年代確立的原則主義。原則主義提出幾項最為重要、基於共同道德的倫理原則——尊重自主、不傷害、為善、正義——作為決策者思考生命倫理議題、尤其是在面臨道德衝突難題時之指引。然而，美國之總統生命倫理議題研究委員會自2010年以來多項報告，即系統性的也將「民主審議」列為指引原則。有鑒於此發展，以及民主審議在生命倫理領域長期以來的傳統，本文主張將民主審議作為一生命倫理原則，並且檢視「民主審議」的內涵為何，其作為一新興原則的適格性，以及此一新增原則所產生的效應。

「民主審議」指的是決策應透過自由平等的公民，以討論、相互證成的方式作成，究其內容，最核心的主張在於提出理由，以及鼓勵公民參與。審視在總統生命倫理議題研究委員會各項報告中的

³⁷³ PCSBI, *supra* note 124, at 8-9.

「民主審議」原則，可發現該原則的內涵不僅是倫理委員會本身的程序，也包含諸多得於政策上落實之面向，如：就爭議之兒童研究成立專家會議進行公眾諮詢；腦神經科學發展的應提早融入倫理的思考；公共衛生緊急措施進行公共溝通之必要；以強化研究者責信、社區參與之方式落實受試者保障等，此皆為目前各原則所無法涵蓋。總統生命倫理議題研究委員會各項報告中的「民主審議」原則，主要係用於檢視新興科技的倫理議題，至於民主審議是否能夠廣泛適用於生命倫理領域，本文也進一步檢視生命倫理原則的三個要件：歷史性、普世性、重要性，發現「民主審議」在生命倫理上具有悠久的傳統，廣為世界各國所實施，且能夠彌補現行原則主義架構在程序面向的不足，並且補充原則主義基於個人自由主義觀點的侷限。

相較於其他科學民主化的主張，本文認為將「民主審議」融入原則主義的架構，其重要性在於透過原則主義，進而產生規範效力。生命倫理原則與倫理委員會向來不僅是專業自治的運作，而是與國家管制緊密相連，民主審議透過生命倫理原則架構，而取得直接或間接之規範效力，尤其是法律效力。再者，若從規範分析之角度出發，民主審議是憲法所肯認的價值，應於治理層面加以落實，且生命倫理議題之決策涉及人民基本權利，亦應符合正當法律程序，亦可證「民主審議」不僅是理想的治理模式，更是法定義務。而生命倫理的原則主義架構，也提供了落實「民主審議」的適當管道。

若我們正處於生命科學的憲法時刻之中，對於那些影響人民基本性權利、足以改變生命定義，形同「更高法」的科技與政策，勢必應訴諸公共審議，以取得足夠的民主正當性。美國國家生命倫理委員會以「民主審議」為生命倫理原則之趨勢，正呼應在憲法時刻中公民審議之重要性。

參考文獻

1. 中文部分

- 李建良（2011），人身自由的憲法保障與強制隔離的違憲審查——釋字第690號解釋，台灣法學雜誌，186期，頁60-79。
- 林怡欣（2013），台灣醫院人體試驗委員會組成之性別分析，元培學報，20期，頁27-48。
- 林超駿（2012），非刑事預防性拘禁之法官（院）保留——兼評釋字第690號解釋，月旦法學雜誌，207期，頁176-200。
- 張文貞（2006），公民複決修憲在當代憲政主義上的意涵，臺灣民主季刊，3卷2期，頁87-118。
- 張兆恬（2012），民主審議作為一項生醫研究倫理原則——國際人權、美國法及台灣經驗之考察，中華國際法與超國界法評論，8卷2期，頁269-298。
- 陳東升（2006），審議民主的限制：公民會議的經驗，臺灣民主季刊，3卷1期，頁77-104。
- 曾建元（2003），病人權利的倫理難題——兼論醫療倫理委員會與倫理諮詢專員在其間的角色，應用倫理研究通訊，25期，頁31-39。
- 黃東益（2008），審議過後——從行政部門觀點探討公民會議的政策連結，東吳政治學報，26卷4期，頁59-96。
- 楊皓清（1995），憲法變遷與修憲政治——民主轉型國家的因應策略及其侷限，月旦法學雜誌，48期，頁136-146。
- 葉俊榮（2003），消散中的「憲法時刻」，收於：民主轉型與憲法變遷，頁61-110，臺北：元照。
- （2010），面對行政程序法，2版，臺北：元照。

蔡甫昌(2000), 生命倫理四原則方法, 醫學教育, 4卷2期, 頁140-154。

蔡甫昌、李明濱(2002), 當代生命倫理學, 醫學教育, 6卷4期, 頁381-395。

2. 外文部分

Ackerman, Bruce. 1991. *We the People Vol. 1: Foundations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———. 2000. *We the People Vol. 2: Transformation*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Advisory Commission on Human Radiation Experiments. 1995. *Final Report*. Washington D.C.: Joseph Henry Press.

Agarwal, Aakash Kumar, and Beth Brianna Murinson. 2010. New Dimensions in Patient-Physician Interaction: Values, Autonomy, and Medical Information in the Patient-Centered Clinical Encounter. *Rambam Maimonides Medical Journal* 3(3):1-11.

Allison, Robert D., Lura J. Abbott, and Alison Wichman. 2008. Non-scientist IRB Members at the NIH. *IRB: Ethics and Human Research* 30(5):8-13.

Anderson, Emily E. 2006. A Qualitative Study of Non-Affiliated, Non-Scientist Institutional Review Board Members. *Accountability in Research* 13:135-155.

Arras, John D. 1998. A Case Approach. Pp. 106-116 in *A Companion to Bioethics*, edited by Helga Kuhse and Peter Singer. Oxford: Blackwell Publishers.

Baker, Robert. 2013. *Before Bioethics: A History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics Revolution*. New York, NY: Oxford University Press.

- Barber, Benjamin R. 2003. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Beauchamp, Tom L. 2005. The Origins and Evolution of the Belmont Report. Pp. 12-16 in *Belmont Revisited: Ethical Principles for Research with Human Subjects*, edited by James F. Childress, Eric M. Meslin, and Harold T. Shapiro. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Beauchamp, Tom L., and James F. Childress. 2013. *Principles of Biomedical Ethics*. 7th ed. New York, NY: Oxford University Press.
- Beecher, Henry K. 1966. Ethics and Clinical Research. *The New England Journal of Medicine* 274(24):1354-1360. Reprinted in 2001. *Bulletin of the World Health Organization* 79(4):367-372.
- Bohman, James, and William Rehg. 1997. Introduction. Pp. ix-xxx in *Deliberative Democracy: Essays of Reason and Politics*, edited by James Bohman and William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press.
- Callahan, Daniel. 2007. Bioethics as a Discipline. Pp. 17-22 in *Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice*, 2d ed., edited by Nancy S. Jecker, Albert R. Jonsen, and Robert A. Pearlman. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers.
- Chambers, Simone. 2009. Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy? *Political Theory* 37(3):323-350.
- Coleman, Carl H. 2004. Rationalizing Risk Assessment in Human Subjects Research. *Arizona Law Review* 46:1-51.
- Crosthwaite, Jan. 1998. Gender and Bioethics. Pp. 32-40 in *A Companion to Bioethics*, edited by Helga Kuhse and Peter Singer. Oxford: Blackwell Publishers.
- Dickert, Neal, and Jeremy Sugarman. 2005. Ethical Goals of Community Consultation in Research. *Health Policy and Ethics*

95(7):1123-1127.

- Dodds, Susan, and Colin Thomson. 2006. Bioethics and Democracy: Competing Roles of National Bioethics Organizations. *Bioethics* 20(6):326-338.
- Donchin, Anne. 2010. The Expanding Landscape: Recent Directions in Feminist Bioethics. Pp. 11-22 in *Feminist Bioethics: At the Center, On the Margins*, edited by Jackie Leach Scully, Laurel Baldwin-Ragaven, and Petya Fitzpatrick. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Donchin, Anne, and Jackie Leach Scully. 2012. Feminist Bioethics. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/feminist-bioethics/>.
- Dresser, Rebecca. 2017. Inclusion, Access, and Civility in Public Bioethics. *The Hastings Center Report* 47(S1):S46-S49.
- Dryzek, John S. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2006. Deliberative Democracy in Different Places. Pp. 23-35 in *The Search for Deliberative Democracy in China*, edited by Ethan J. Leib and Baogang He. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Emanuel, Ezekiel J. 1995. The Beginning of the End of Principlism. *The Hastings Center Report* 25(4):37-38.
- Emanuel, Ezekiel J., and Charles Weijer. 2005. Protecting Communities in Research: From a New Principle to Rational Protections. Pp. 165-183 in *Belmont Revisited: Ethical Principles for Research with Human Subjects*, edited by James F. Childress, Eric M. Meslin, and Harold T. Shapiro. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Emanuel, Ezekiel J., and Linda L. Emanuel. 1992. Four Models of the Physician-Patient Relationship. *JAMA* 267(16):2221-2226.
- Evans, John. 2000. A Sociological Account of the Growth of Principlism.

- The Hastings Center Report* 30(5):31-38.
- Felt, Ulrike, Maximilian Fochler, Astrid Mager, and Peter Winkler. 2008. Visions and Versions of Governing Biomedicine: Narratives on Power Structures, Decision-Making and Public Participation in the Field of Biomedical Technology in the Austrian Context. *Social Studies of Science* 38(2):233-257.
- Fishkin, James S. 2009. *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. New York, NY: Oxford University Press.
- Fishkin, James S., and Robert C. Luskin. 1999. The Quest for Deliberative Democracy. *The Good Society* 9(1):1-9.
- Furrow, Barry R., Thomas Greaney, Sandra Johnson, Timothy Jost, and Robert Schwartz, eds. 2008. *Bioethics: Health Care Law and Ethics*. 6th ed. Saint Paul, MN: West Publishing Co.
- Gert, Bernard, Charles M. Culver, and K. Danner Clouser. 1997. *Bioethics: A Return to Fundamentals*. New York, NY: Oxford University Press.
- Goodin, Robert E. 2003. Democratic Deliberation Within. Pp. 54-79 in *Debating Deliberative Democracy*, edited by James S. Fishkin and Peter Laslett. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Gutmann, Amy, and Dennis Thompson. 1996. *Democracy and Disagreement*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- . 1997. Deliberating about Bioethics. *The Hastings Center Report* 27(3):38-41.
- . 2004. *Why Deliberative Democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Harris, John. 2003. In Praise of Unprincipled Ethics. *Journal of Medical Ethics* 29:303-306.

- He, Baogang, and Mark E. Warren. 2011. Authoritarian Deliberation: The Deliberative Turn in Chinese Political Development. *Perspectives on Politics* 9(2):269-289.
- Hendriks, Carolyn M. 2005. Consensus Conferences and Planning Cells. Pp. 80-110 in *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*, edited by John Gastil and Peter Levine. New York, NY: Springer.
- Holm, Soren. 1995. Not Just Autonomy: The Principles of American Biomedical Ethics. *Journal of Medical Ethics* 21(6):332-338.
- Jasanoff, Sheila. 2011. Introduction: Rewriting Life, Reframing Rights. Pp. 1-28 in *Reframing Rights: Bioconstitutionalism in the Genetic Age*, edited by Sheila Jasanoff. Cambridge, MA: MIT Press.
- Jones, Anne Hudson. 1999. Narrative in Medical Ethics. *Culture and Medicine* 171:50-52.
- Jonsen, Albert R. 1998. *The Birth of Bioethics*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 1998. The Ethics of Research with Human Subjects: A Short History. Pp. 5-10 in *Source Book in Bioethics: A Documentary History*, edited by Albert R. Jonsen, Robert M. Veatch, and LeRoy Walters. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- . 2005. On the Origins and Future of the Belmont Report. Pp. 3-11 in *Belmont Revisited: Ethical Principles for Research with Human Subjects*, edited by James F. Childress, Eric M. Meslin, and Harold T. Shapiro. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Kahneman, Daniel. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Klitzman, Robert. 2012. Institutional Review Board Community Members: Who Are They, What Do They Do, and Whom Do They Represent?. *Academic Medicine* 87(7):975-981.

- Kluver, Lars. 2000. Biotechnology-Related Consensus Conference in Denmark. Pp. 158-162 in *Biotechnology, Patents and Morality*, 2d ed., edited by Sigrid Sterckx. Brookfield, VT: Ashgate.
- Kornreich, Yoel, Ilan Vertinsky, and Pitman B. Potter. 2012. Consultation and Deliberation in China: The Making of China's Health-Care Reform. *The China Journal* 66:176-203.
- Kuhse, Helga, and Peter Singer. 1998. What Is Bioethics? A Historical Introduction. Pp. 3-14 in *A Companion to Bioethics*, edited by Helga Kuhse and Peter Singer. Oxford: Blackwell Publishers.
- Leib, Ethan J., and Baogang He. 2006. Editor's Introduction. Pp. 1-19 in *The Search for Deliberative Democracy in China*, edited by Ethan J. Leib and Baogang He. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Lin, Albert. 2011. Technology Assessment 2.0: Revamping Our Approach to Emerging Technologies. *Brooklyn Law Review* 76:1309-1370.
- Madison, James. 1787. The Federalist No. 10, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed10.asp.
- Mansbridge, Jane. 1999. Everyday Talk in the Deliberative System. Pp. 211-242 in *Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement*, edited by Stephen Macedo. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2007. "Deliberative Democracy" or "Democratic Deliberation"? Pp. 251-271 in *Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?*, edited by Shawn. W. Rosenberg. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Mansbridge, Jane, James Bohman, Simone Chambers, David Estlund, Andreas Føllesdal, Archon Fung, Cristina Lafont, Bernard Manin, and José Luis Martí. 2010. The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy. *Journal of Political Philosophy*

18(1):64-100.

Marchant, Gary E., and Andrew Askland. 2003. GM Foods: Potential Public Consultation and Participation Mechanism. *Jurimetrics* 44(1):99-137.

Meyer, Michelle M. 2013. Regulating the Production of Knowledge: Research Risk-Benefit Analysis and the Heterogeneity Problem. *Administrative Law Review* 65:237-299.

Miralles, Angela Aparisi. 2005. The Globalization of Bioethics: The Task of International Commissions. *Georgetown Journal of International Law* 37:141-152.

Moore, Alfred. 2010. Public Bioethics and Deliberative Democracy. *Political Studies* 58:715-730.

Moreno, Jonathan D. 1995. *Deciding Together: Bioethics and Moral Consensus*. New York, NY: Oxford University Press.

National Bioethics Advisory Commission. 1997. *Cloning Human Beings Vol. 1: Report and Recommendations*. Bethesda, MD: National Bioethics Advisory Commission.

———. 1999. *Ethical Issues in Human Stem Cell Research: Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission Vol. 1*. Bethesda, MD: National Bioethics Advisory Commission.

———. 1999. *Research Involving Human Biological Materials: Ethical Issues and Policy Guidance, Report and Recommendations of the NBAC Vol. 1*. Bethesda, MD: National Bioethics Advisory Commission.

———. 2001. *Ethical and Policy Issues in International Research: Clinical Trials in Developing Countries Vol. 1*. Bethesda, MD: National Bioethics Advisory Commission.

———. 2001. *Ethical and Policy Issues in Research Involving Human Participants, Summary*. Bethesda, MD: National Bioethics

- Advisory Commission.
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 1977. *Psychosurgery: Report and Recommendations*. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare.
- . 1978. *Institutional Review Boards*. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare.
- . 1978. *Ethical Guidelines for the Delivery of Health Services by DHEW*. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare.
- . 1979. *The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research*. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare.
- Parker, Michael. 2007. Deliberative Bioethics. Pp. 185-192 in *Principles of Health Care Ethics*, 2d ed., edited by Richard E. Ashcroft, Angus Dawson, Heather Draper, and John R. McMillan. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Persad, Govind. 2014. Democratic Deliberation and the Ethical Review of Human Subjects Research. Pp. 157-172 in *Human Subjects Research Regulation: Perspectives on the Future*, edited by I. Glenn Cohen and Holly Fernandez Lynch. Cambridge, MA: MIT Press.
- Poland, Susan Cartier. 1998. Scope Note 34: Bioethics Commissions: Town Meetings with a “Blue, Blue Ribbon”. *Kennedy Institute of Ethics Journal* 8(1):91-109.
- Pope, Thaddeus Mason. 2009. Multi-Institutional Healthcare Ethics Committees: The Procedurally Fair Internal Dispute Resolution Mechanism. *Campbell Law Review* 31:257-332.
- President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine

- and Biomedical and Behavioral Research. 1981. *Defining Death*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- . 1982. *Splicing Life: The Social and Ethical Issues of Genetic Engineering with Human Beings*. Washington, D.C.: Georgetown University.
- . 1983. *Deciding to Forego Life-Sustaining Treatment*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- . 1983. *Securing Access to Health Care*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- . 1983. *Screening and Counseling for Genetic Conditions: The Ethical, Social, and Legal Implications of Genetic Screening, Counseling, and Education Programs*. Washington, D.C.: Georgetown University.
- Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue. 2010. *New Directions: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2011. *Moral Science: Protecting Participants in Human Subjects Research*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2012. *Privacy and Progress in Whole Genome Sequencing*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2013. *Anticipate and Communicate: Ethical Management of Incidental and Secondary Findings in the Clinical, Research, and Direct-to-Consumer Contexts*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2013. *Safeguarding Children: Pediatric Medical Countermeasure Research*. Washington, D.C.: Presidential

- Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2014. *Gray Matters: Integrative Approaches for Neuroscience, Ethics, and Society*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2015. *Gray Matters: Topics at the Intersection of Neuroscience, Ethics, and Society*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2015. *Ethics and Ebola: Public Health Planning and Response*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- . 2016. *Bioethics for Every Generation: Deliberation and Education in Health, Science and Technology*. Washington, D.C.: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issue.
- Rawls, John. 1996. *Political Liberalism*. New York, NY: Columbia University Press.
- Rei, Wenmay, and Jiunn-Rong Yeh. 2009. Promises and Pitfalls of Using National Bioethics Commissions as an Institution to Facilitate Deliberative Democracy—Lessons from the Policy Making of Human Embryonic Stem Cell Research. *NTU Law Review* 4(2):69-106.
- Sengupta, Sohini, and Bernard Lo. 2003. The Roles and Experiences of Non-affiliated and Non-scientist Members of Institutional Review Boards. *Academic Medicine* 78(2):212-218.
- Sherwin, Susan. 1996. Feminism and Bioethics. Pp. 47-66 in *Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction*, edited by Susan M. Wolf. New York, NY: Oxford University Press.
- Snead, O. Carter. 2010. Science, Public Bioethics, and the Problem of Integration. *U.C. Davis Law Review* 43:1529-1604.
- Solomon, Mildred Z., and Bruce Jennings. 2017. Bioethics and

- Populism: How Should Our Field Respond?. *The Hastings Center Report* 47(2):11-15.
- Stark, Laura. 2007. Victims in Our Own Minds? IRBs in Myth and Practice. *Law and Society Review* 41:777-786.
- Stoddard, Daniel G. 2010. Note: Falling Short of Fundamental Fairness: Why Institutional Review Board Regulations Fail to Provide Procedural Due Process. *Creighton Law Review* 43:1275-1327.
- Sulmasy, Daniel P. 2017. Ethical Principles, Process, and the Work of Bioethics Commissions. *The Hastings Center Report* 47(S1):S50-S53.
- Sunstein, Cass R. 1993. *The Partial Constitution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . 1999. *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*. New York, NY: New York Times Co.
- . 2001. *Designing Democracy: What Constitutions Do*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2003. The Law of Group Polarization. Pp. 80-101 in *Debating Deliberative Democracy*, edited by James S. Fishkin and Peter Laslett. Malden, MA: Blackwell.
- The Center for Advanced Study. 2006. Improving the System for Protecting Human Subjects: Counteracting IRB “Mission Creep”. Working paper. University of Illinois Law and Economics Research Paper No. LE06-016. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902995.
- The President’s Council on Bioethics. 2002. *Human Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry*. Washington, D.C.: The President’s Council on Bioethics.
- Tong, Rosemarie. 1996. Feminist Approaches to Bioethics. Pp. 67-94 in *Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction*, edited by Susan M.

Wolf. New York, NY: Oxford University Press.

Veatch, Robert M. 2007. How Many Principles for Bioethics?. Pp. 43-50 in *Principles of Health Care Ethics*, 2d ed., edited by Richard E. Ashcroft, Angus Dawson, Heather Draper, and John R. McMillan. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Wolf, Susan M. 1991. Ethics Committees and Due Process: Nesting Rights in a Community of Caring. *Maryland Law Review* 50:798-858.

———. 1996. Introduction: Gender and Feminism in Bioethics. Pp. 3-43 in *Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction*, edited by Susan M. Wolf. New York, NY: Oxford University Press.

Young, Iris Marion. 2000. *Inclusion and Democracy*. New York, NY: Oxford University Press.

Democratic Deliberation as a Bioethical Principle and Its Legal Implications

Chao-Tien Chang*

Abstract

The Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues (PCSBi) has continuously and broadly used *democratic deliberation* as a principle when analyzing different issues since 2010. Supported by the reports of PCSBi, this article argues that democratic deliberation is an emerging bioethical principle and examines the new principle's contribution through examining its legal implications. This article finds that the new principle complements the current framework by providing perspectives not covered by the current four principles. From the normative perspective, treating democratic deliberation as a bioethical principle is also significant. The analytical framework of bioethical principles has been deeply incorporated into law and regulation. Considering democratic deliberation as a principle would upgrade this principle into a legal duty, rather than simply taking democratic deliberation as an idealistic process of decision-making. There are also solid normative grounds justifying the necessity of democratic deliberation. Regulations surrounding bioethical issues mostly affect a person's fundamental rights, where due process of law is required. The bioethical

* Assistant Professor, School of Law, National Chiao Tung University. Parts of this article are revised from the author's English-written SJD dissertation. The author thanks her SJD academic advisor, Dr. Anita L. Allen, for the inspiration of this topic. The author also thanks comments from Grand Justice Jau-Yuan Hwang and two anonymous reviewers. However, all faults belong to the author. Parts of the work of this article, including revising the author's dissertation into Chinese and adding discussions of Taiwan law, are also the research results of MOST 105-2410-H-009-002.

framework, with its deep integration with law, serves as a channel to fulfill the requirements of due process of law with the new principle. Finally, this article examines two examples—the institutional design of the institutional review board (IRB) and the judicial review of bioethical cases—to elaborate how democratic deliberation could be institutionally practicable.

KEYWORDS: democratic deliberation, bioethics, bioethical principles, principlism, deliberative democracy, due process of law.